

제4장 상속채무금 소송절차와 보전처분

(민사법원에서의 절차)

제1절 소의 제기

1. 서 설

가. 의 의

“상속채무금 소송”이란 채권자가 피상속인에 대하여 생전에 가지고 있던 채무를 피상속인이 사망함으로써 그 상속인에게 피상속인을 대신해서 채무를 갚으라고 법원에 권리보호를 요구하는 절차를 말한다.

(1) 한정승인의 경우

한정승인심판이 있는 경우에는 그 한정승인자를 상대로 상속재산에 대하여 소송이며, 가압류·가처분 등을 하여 집행권원을 받아 놓아야 상속재산의 배당절차에서 안분배당을 받을 수 있는 것이다.

한정승인자의 경우에는 상속포기신고만 하면 채무가 자동으로 없어지거나 채무를 면제 받는 것이 아니기 때문에 한정승인을 진행하는 중에도 채권자들로부터 소제기를 받을 경우 답변서, 준비서면을 제출하여 대응하여야 한다.

한정승인은 상속인이 상속받은 재산의 범위내에서 채무를 변제할 책임이 있고, 상속인의 고유재산으로 채무를 변제하지 않아도 되는 것이므로, 채권자로부터 소송이나 강제집행이 들어오면 상속받은 재산의 범위내에서 변제하겠다는 항변을 하여야 할 것이다.

(2) 상속재산파산의 경우

상속재산은 파산의 결정이 있기까지는 상속인을 상대로 소송이며, 가압류·가처분·강제집행 등을 할 수 있으나, 상속재산에 대하여 파산선고가 있는 때에는 이에 속하는 모든 재산을 파산재단으로 하므로(채무자회생법 제389조 제1항), 파산채권은 파산절차에 의하지 아니하고는 별도로 소송이나 강제집행 등을 행사할 수 없다(채무자회생법 제424조).

따라서 파산재단에서 변제를 받기 위하여는 파산의 결정이 있기 전까지 저당권, 질권 등이 아닌 이상 판결을 받아 놓아야 할 것이다.

2. 소의 제기

가. 개 설

소라 함은 원고가 피고를 상대로 법원에 권리보호를 요구하는 당사자의 신청을 말한다. 소는 판결을 목적으로 하는 소송절차의 개시형식이다. 소는 법원에 대하여 판결을 요구하는 행위이고 직접적으로 피고에 대하여 하는 사법상의 의사표시는 아니다. 따라서 민사조정신청, 지급명령신청, 경매신청, 가압류·가처분신청은 소가 아니다.

소의 제기는 소장을 법원에 제출함으로써 한다(민소법 제248조). 소장은 이를 지참하여 제출하는 것이 원칙이나 우송의 방법으로 제출할 수도 있다. 소를 제기하려면 적법한 소장의 요건을 갖추어야 하는 바, 소장의 적법요건은 당사자, 법정대리인과 청구의 취지, 청구의 원인(필요적 기재사항)이 기재되어 있고 상당한 인지가 첨부되어 있어야 한다.

나. 소장의 기재사항

소장에는 당사자, 법정대리인 청구의 취지, 청구의 원인을 기재하여야 하며(민소법 제249조 1항), 준비서면에 관한 규정(민소법 제274조)이 준용된다.

(1) 당사자표시의 기재

① 피고의 기재

사망한 사람을 상대로 하는 소송은 할 수 없다. 따라서 사망자를 상대로 한 소송은 부적법하여 각하한다.

판례는 “민사소송에서 소송당사자의 존재나 당사자능력은 소송요건에 해당하고, 이미 사망한 자를 상대로 한 소의 제기는 소송요건을 갖추지 않은 것으로서 부적법하며, 상고심에 이르러서는 당사자표시정정의 방법으로 그 흠결을 보정할 수 없다.⁶³²⁾”고 하고, “이미 사망한 자를 피고로 하여 제기된 소는 부적법하여 이를 간과한 채 본안 판단에 나아간 판결은 당연무효로서 그 효력이 상속인에게 미치지 않고, 채권자의 이러한 제소는 권리자의 의무자에 대한 권리행사에 해당하지 않으므로, 상속인을 피고로 하는 당사자표시정정이

632) 대법원 2012. 6. 14. 선고 2010다105310 판결

이루어진 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한, 거기에는 애초부터 시효중단 효력이 없어 민법 제170조 제2항이 적용되지 않는다고 봄이 타당하고, 법원이 이를 간과하여 본안에 나아가 판결을 내린 경우에도 마찬가지로 보아야 한다.⁶³³⁾”고 판시하였다.

그런데 피고(피상속인)가 사망한 사실을 모르고 소송을 제기한 경우에는 그 사망자에게 상속인이 있으면 그 상속인이 소송을 수계한다. 따라서 피고(피상속인)를 상속인으로 변경하는 당사자표시정정서(708면 참조)를 법원에 제출해야 한다.

그러나 채무자가 사망한 사실을 알고 있는 경우에도 상속인을 알 수 없기 때문에 당사자(피고)의 이름을 기재할 수가 없는데 이 경우에는 소장의 피고 표기를 “망 ○○○의 상속인”으로 기재하고 주소는 망인의 최후주소를 기재한다.

소장의 내용에도 “원고는 망인의 상속인들을 특정할 수 없는 관계로 추후 사실조회 등의 방법으로 각 상속인을 특정한 이후 당사자표시정정신청 및 청구취지변경을 신청할 예정입니다.”라고 기재하여 당사자표시를 보정하려는 뜻을 기재한다(691면 참조).

그 후 법원으로부터 보정명령이 나오면 피고를 상속인으로 변경하여야 한다. 후술의 소장의 보정(708면 참조)에서 다룬다.

② 상속포기자와 한정승인자

상속포기자는 상속포기와 함께 망인의 모든 재산(적극재산 및 소극재산-채무)에 관한 권리를 포기하게 되므로, 상속포기한 상속인을 상대로 상속재산에 대한 소송을 할 수가 없고, 또한 상속포기자는 그 상속재산에 대한 권리를 상속법상에서 주장할 수가 없다.

그러나 피상속인의 채권자는 1순위 상속인이 상속을 포기한 경우에는 차순위 상속인에게 채무 변제를 요구할 수 있고, 만약 그 역시 상속포기를 하였다면 또 그 다음 순위 상속인에게 채무변제를 요구할 수 있다.

한편 채권자가 상속인이 상속포기를 한 사실을 모르고 상속포기자를 상대로 상속채무금의 소를 제기한 경우에는 상속포기자는 상속포기사실을 증명하여 적극적으로 항변하여야 할 것이다(708면 참조 답변서 내용 참조).

한정승인심판이 있는 경우에는 한정승인자를 상대로 소송을 하여야 하므로 피고(피상속인)가 사망한 사실을 모르고 소송을 제기한 경우에는 한정승인자를 상속인으로 변경하는 당사자표시정정서(708면 참조)를 법원에 제출해야 한다.

③ 파산선고가 있는 경우

633) 대법원 2014. 2. 27. 선고 2013다94312 판결

법원은 상속재산에 대하여 파산선고 시 파산관재인을 선임하여 결정으로 파산을 선고하는데 파산관재인은 파산재단에 관한 소송에서 원고나 피고로서의 당사자적격을 갖게 된다. 따라서 상속재산과 관련해서 소송을 제기하려면 상속인이 아닌 파산관재인을 상대로 제기해야 한다.

파산채권자가 상속재산에 대한 파산선고 사실을 몰라서 파산관재인이 아닌 그 상속인을 상대로 소송을 제기했다면 전술하였듯이(피상속인을 상속인으로 변경) 파산관재인으로 당사자표시정정을 하여야 한다.

(2) 청구취지

청구취지란 민사소송법상 청구의 원인에 의하여 결정되는 소송물인 권리 또는 법률관계 중 어떠한 범위 또는 태양의 판결을 구하는 것인가를 명백히 표시하는 부분으로서 이는 소의 결론에 해당하는 부분이며 청구원인과 함께 소장의 필요적 기재사항이다. 청구취지에는 원고가 어떤 주문의 판결을 구하는가 그 내용(소송물), 범위 등을 간결 명확하게 하여야 한다. 청구취지를 기재함에 있어서는 청구가 인용되는 경우 이를 판결의 주문에 바로 이기(移記)할 수 있을 만큼 정확하여야 한다.

소송의 유형은 청구취지에 따라 정하여지는 것이므로 청구취지는 청구의 형태와 범위를 명확히 하여 확정할 수 있도록 구체적으로 특정하여야 하며 또한 청구취지는 강제집행의 단계까지 고려하여 그 집행이 가능하도록 구성하여야 한다. 금액인 경우에는 그 금액을 명시하여야 하고, 물건의 경우에는 그 물건이 특정되도록 구체적으로 표시하며, 법률관계인 경우에는 그 동일성을 인식할 정도로 특정하여야 한다.

“피상속인(채무자)의 이름과 그 상속인”으로만 기재하여 제기한 소는 상속인이 여럿 있을 경우에는 채무자에게 청구한 금액을 상속인들의 상속비율에 맞도록 청구취지정정 신청을 하여야 한다(후술 710면 참조).

(3) 법정이율

이행청구의 청구취지에는 법정이율과 지연이자를 기재하는데, “법정이율”이란 법률로 정해 놓은 이율을 말한다. 이는 약정이율에 대립하는 말이다. 민법상의 법정이율은 연5푼이고(민법 제379조), 상법상의 법정이율은 연6푼(상법 제54조)이다⁶³⁴. 이 법정이율은 약

634) 상법 제54조의 상사법정이율은 상행위로 인한 채무나 이와 동일성을 가진 채무에 관하여 적용되는 것이고, 상행위가 아닌 불법행위로 인한 손해배상채무에는 적용되지 아니한다(대법원 2004. 3. 26. 선고 2003다34045 판결).

정이 없는 경우 및 법정이자에 적용된다.

그리고 금전채무불이행으로 인한 이행의 소에 있어서의 이른바 지연이자(손해배상)는 종전에는 연 1할 5푼이었는데 2019년 6. 1.부터 연 1할 2푼이 적용된다(소송촉진등에 관한 특례법 제3조 제1항). 다만 장래이행의 소(민소법 제251조)에는 소촉법 제3조 1항 소정의 지연이자가 적용되지 아니한다.

「지연이자」란 금전채무의 불이행의 경우에 손해배상으로서 법률상 당연히 지급하여야 할 금전을 말한다. 채권액에 대한 일정한 비율로 지연의 기간에 비례하여 지급되기 때문에 이자라고 불리지만, 본질적으로는 이자가 아니라 채무불이행으로 인한 손해배상이다. 그 비율은 법정이율을 원칙으로 하지만, 만일 이것보다 고율의 약정이율의 약속이 있으면 이에 따른다(민법 제397조 1항).

【고율의 약정이율의 예】

피고(들)은 원고에게 금15,000,000원과 그 중 금14,000,000원에 대하여 20〇〇. 1. 10.부터 다 갚는 날까지 연 20.8%의 비율에 의한 돈을 지급하라.

(4) 입증방법

증거방법으로 위 청구원인 란에서 밝힌 법률관계의 성립원인사실을 뒷받침하기 위하여 서증으로 할 수 있는 것을 소장에 첨부 제출하여야 하는 바, 소장에 표시방식은 “입증방법” 또는 “소명서류”라고 기재한다. 소명은 즉시 조사할 수 있는 증거에 의하여야 하는데(민소법 제299조), 피상속인과 생전에 거래하였던 거래장부, 계약서, 차용증 등을 소명서류로 첨부한다.

다. 소가산정(첨부인지)

(1) 개 설

민사소송 등 인지법은 제1조에서 소장이나 신청서 또는 신청의 취지를 적은 조서에는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우가 아니면 이 법에서 정하는 인지를 붙여야 하고 그에 따른 소정의 인지를 첨부하지 아니한 것은 부적법하다고 규정하여 이를 강제하고 있으며, 단서에서는 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 인지를 붙이는 대신 그 인지액에 해당하는 금액을 현금이나 신용카드·직불카드 등으로 납부하게 할 수 있도록 하되, 신용카드·직불카드 등으로 납부하는 경우 인지납부일, 인지납부대행기관의 지정 및 운영과

납부대행 수수료 등에 필요한 사항은 대법원규칙으로 정하고, 같은 규칙에서는 인지의 납부, 반환 및 환급과 관련한 사무처리요령을 대법원예규로 정하도록 하였다. 따라서 소가에 따라 산출한 인지액은 대법원규칙·예규에서 정한 절차에 따라 현금 또는 신용카드 등으로 납부하고 그 영수필확인서를 소장에 첨부하여 법원에 제출하여야 한다.

(2) 금전청구의 소가

금전청구의 소가는 청구금액을 소가로 한다. 예컨대 1,000만원을 피상속인에게 대여하였다면 1,000만원이 소가가 된다.

(3) 부동산 소가산정의 원칙

소가는 원고가 소로서 주장하는 이익에 의하여 산정한다(민사소송법 제26조 제1항). “소로서 주장하는 이익”이란 원고가 청구취지로서 구하는 범위 내에서 원고입장에서 보아 전부승소 할 경우에 직접 받는 경제적 이익을 객관적으로 평가하여 금전으로 정함을 원칙으로 한다(민인규 제6조).

소가산정에 관하여는 민사소송 등 인지규칙 제2장이 그 기준을 정하고 있으며 물건 등의 가액을 표준으로 한다.

① 토지의 소가산정방법

토지의 가액은 「부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 의한 개별공시지가(개별공시지가가 없는 경우에는 시장·군수가 같은 법 제9조의 규정에 의하여 국토해양부장관이 제정한 토지가격비준표를 사용하여 산정한 가액)에 100분의 50을 곱하여 산정한 금액으로 한다(민인규 제9조 제1항).

○ 공식 : $\text{공시지가} \times \text{면적}(\text{m}^2) \times 50/100 = \text{소가}$

② 건물의 소가산정방법

건물의 가액은 지방세법 시행령 제4조 제1항 제1호의 방식에 의하여 산정한 시가표준액(이 경우 같은 법 시행령 제4조 제1항 제1호의 건축물은 건물로 한다)에 100분의 50을 곱한 금액으로 한다(민인규 제9조 제2항).

○ 공식 : $\text{건물기준가액} \times \text{구조지수} \times \text{용도지수} \times \text{위치지수} \times \text{경과년수잔가율} \times \text{면적}(\text{m}^2) \times \text{가감산율} = \text{시가표준액}(\text{목적물가액}) \times 50/100 \times \text{목적물의 종류에 따른 가액} = \text{소가}$

③ 부동산의 경우 소가산정에 필요한 서면

부동산의 경우 소송물의 가액을 산출하기 위하여 그 소송의 목적이 토지인 경우에는 개별공시지가가 기재된 공시지가확인원, 토지대장등본 또는 임야대장이나 토지과세대장 또는 토지등급증명서를, 건물인 경우에는 건축물과세대장 또는 가옥대장 등 과세보조대장(민인규칙 제8조)을 첨부하여야 한다(민소규칙 제63조 2항). 동산이나 기타 공시가격이 없는 경우에는 이를 인정할 자료로 계약서, 감정서 등을 제출한다.

(4) 인지액 산출 공식

금전청구의 소가 및 부동산소가를 산정하였으면 소장에 붙일 인지액을 산출하여야 하는바, 제1심 소장에는 소가를 다음의 공식에 의하여 산출한 인지를 붙여야 한다(민사소송등 인지법 제2조 제1항).

● 제1심 소장에 첨부할 인지액의 산출 공식

소가	인지액	관련법(민사소송등인지법)
1,000만원 미만	소가 $\times$ 0.005	제2조 제1항 제1호
1,000만원이상~1억원미만	5,000 + (소가 $\times$ 0.0045)	제2조 제1항 제2호
1억원 이상~10억원 미만	55,000 + (소가 $\times$ 0.004)	제2조 제1항 제3호
10억원 이상	555,000 + (소가 $\times$ 0.0035)	제2조 제1항 제4호

주) 다만, 산출된 인지액이 1,000원 미만인 때에는 이를 1,000원으로 한다. 그리고 100원 미만의 액수는 생략한다.

라. 송달료

(1) 개 설

송달료는 대법원장이 지정하는 각 법원별 해당 송달료 수납은행에 이를 납부하여야 한다. 대부분 법원 내에 있다. 수납은행에서 송달료 납부서를 기재한 후 은행에 제출한 후 법원제출용을 받아 소장과 함께 법원에 접수한다. 송달료를 추가로 납부할 때에는 송달료 추가납부통지서를 작성 제출함으로써 한다. 송달료납부서는 송달료, 납부당사자, 본인의 주소, 성명, 우편번호, 납부금액을 기재한다. 송달료는 재판이 확정될 때까지의 소송서류의 우편요금을 미리 납부하는 것이므로 소장접수창구에서는 충분한 송달료를 납부하게 하고 있다. 따라서 소송이 종료된 후 남은 송달료 금액을 돌려주기 위하여 은행예금계좌번호를 송달료납부서에 기재하도록 하고 있다. “납부자”란에는 대리인 등 실제로 송달료납부

행위를 하는 사람의 이름을 기재한다. 소장, 항소장, 상고장, 항고(준항고 포함)장, 재항고(특별항고 포함)장(이하 상소장 등이라 한다)을 제출하는 경우에는 송달료납부서를 첨부하여 원심법원에 제출하여야 한다(재일 87-4).

(2) 송달료납부기준

2022년 2월 1일 현재 송달료 1회당 납부금액은 5,200원이다.

“예” 민사소액사건(가소) : 원고와 피고 2인일 경우 $20회 \times 5,200원 = 104,000원$

○ 적용대상사건 및 당사자 1인당 송달료납부기준⁶³⁵⁾

적용대상사건 \ 송달료 및 수송달자	당사자 1인당 납부 기준	수 송 달 자
민사제1심합의사건(가합)	15회	원고, 피고 등
민사제1심단독사건(가단)	15회	〃
민사소액사건(가소)	10회	〃
화해사건(자)	4회	신청인, 상대방
독촉사건(차)	6회	채권자, 채무자

마. 법원의 판결

상속의 한정승인에 있어서 상속재산이 없거나 그 상속재산이 상속채무의 변제에 부족한 경우 상속채무 전부에 대한 이행판결을 선고하여야 하는지에 대하여 판례는 “상속의 한정승인은 채무의 존재를 한정하는 것이 아니라 단순히 그 책임의 범위를 한정하는 것에 불과하기 때문에, 상속의 한정승인이 인정되는 경우에도 상속채무가 존재하는 것으로 인정되는 이상, 법원으로서 상속재산이 없거나 그 상속재산이 상속채무의 변제에 부족하다고 하더라도 상속채무 전부에 대한 이행판결을 선고하여야 하고, 다만, 그 채무가 상속인의 고유재산에 대해서는 강제집행을 할 수 없는 성질을 가지고 있으므로, 집행력을 제한하기 위하여 이행판결의 주문에 상속재산의 한도에서만 집행할 수 있다는 취지를 명시하여야 한다(대법원 2003. 11. 14. 선고 2003다30968 판결).”고 판시하였다.

635) 송달료규칙의 시행에 따른 업무처리요령(재일 87-4) [별표 1]

바. 상속채무금 청구의 소장사례

[사례] 대출금 청구의 소

소 장

원 고 ○○ 캐피탈 주식회사
 피 고 망 김철수의 상속인⁶³⁶⁾

상속채무금(대출) 청구의 소

소 가	금○○○○원
첨부인지액	금○○○○원
송 달 료	금○○○○원

서울중앙지방법원 귀중

636) 한정승인심판을 받은자가 있는 경우에는 한정승인자를 피고로 적어야 한다.

소 장

원 고 ○○캐피탈 주식회사 (000000-000000)
 ○○시 ○○구 ○○로○길○○-○
 대표이사 ○ ○ ○

피 고 망 김철수 (000000-000000)의 상속인
 망인의 최후 주소 ○○시 ○○구 ○○로○길○○-○

상속채무금(대출) 청구의 소

청 구 취 지

1. 피고(들)은 원고에게 금15,000,000원과 그 중 금14,000,000원에 대하여 20○
 ○. 1. 10.부터 다 갚는 날까지 연 20.8%의 비율에 의한 돈을 지급하라.
 2. 소송비용은 피고(들)의 부담으로 한다.
 3. 제1항은 가집행할 수 있다.
- 라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

1. 당사자 관계
 원고는 할부금융대출, 일반대출, 리스/렌트(시설대여업) 등을 영위하는 여신
 전문종합금융법인이고, 망 김철수(000000-000000, 이하 ‘망인’이라고 약칭합
 니다)은 원고와 할부대출계약을 체결한 이후 20○○. 12. 5. 사망하게 되었
 고, 피고(들)은 망인의 상속인(들)입니다.
2. 망인의 채무불이행 및 상속인들의 채무승계
 가. 원고는 망인과 20○○. 9. 16. 원금15,000,000원, 대출기간 36개월, 대출이
 율 연 17.8%, 연체이자율 연 20.8%, 2회 이상 연체 시 기한의 이익을 상실한
 다는 내용으로 여신거래계약을 체결하고, 그 변제이행은 원리금균등분할상
 환방식에 따라 매월 500,000원씩 납입하기로 하였습니다.

나. 이후 망인은 위 약정을 위배하여 2회분의 분할금 1,000,000원을 지급하였을 뿐 나머지 원리금을 2회 이상 지급하지 아니하여 기한의 이익을 상실하였습니다. 그런데 망인은 20〇〇. 12. 5. 자에 사망하게 되어 피고 망 000의 상속인들은 위 채무를 상속받게 되었습니다.

다. 따라서 망인의 상속인 피고(들)는 망인의 상속채무를 변제할 의무가 있다고 할 것이며, 20〇〇. 1. 9. 현재 원금14,000,000원과 지연손해금1,000,000원 등 합계금15,000,000원을 지급하여야 할 것이며, 그 다음날인 20〇〇. 1. 10. 부터 원금14,000,000원에 대하여 연체이자율 연 20.8%의 지연손해금을 지급하여야 상당하다고 할 것입니다.

라. 한편, 원고는 망인의 상속인들을 특정할 수 없는 관계로 추후 사실조회 등의 방법으로 각 상속인을 특정한 이후 당사자표시정정신청 및 청구취지변경을 신청할 예정입니다.

3. 결론

따라서 망인의 상속인 피고(들)는 원고에게 20〇〇. 1. 9. 까지의 원리금 15,000,000원과 그 중 원금14,000,000원에 대하여 그 다음날인 20〇〇. 1. 10. 부터 다 갚는 날까지 약정연체이자율인 연 20.8%의 지연손해금을 지급하여야 상당하다고 할 것입니다.

입 증 방 법

1. 갑 제1호증	대출계약서
1. 갑 제2호증	대출약관
1. 갑 제3호증	여신거래기본약관
1. 갑 제4호증	통지서
1. 갑 제5호증	청구서

첨 부 서 류

- | | |
|--------------------|-----|
| 1. 소장부분 | 1 부 |
| 1. 등기사항전부증명서(법인등본) | 1 부 |
| 1. 위임장 | 1 부 |

20○○. 2. .

위 원 고 ○○캐피탈 주식회사
대표이사 ○○○

서울중앙지방법원 귀중

※ 망인의 상속인(피고)을 모르기 때문에 소장의 피고표기를 “망 김철수의 상속인”으로 하여 소를 제기하고 법원에서 보정이 나오면 그때 상속인의 가족관계증명서 등을 제출 함으로서 당사자표시와 피고의 주소를 보정한다(708면 참조).

소장의 내용에도 다음과 같이 기재한다.

“원고는 망인의 상속인들을 특정할 수 없는 관계로 추후 사실조회 등의 방법으로 각 상속인을 특정한 이후 당사자표시정정신청 및 청구취지변경을 신청할 예정입니다.”

[사례] 대여금청구의 소(수표를 차용증에 갈음하여 배서양도)

소 장

원 고 문 상 일 (주민등록번호 -)

서울 강남구 신사로123길 4

전화번호(휴대폰 포함), 팩스번호, 전자우편(e-mail)주소

피 고 망 김철수 (000000-0000000)의 상속인

망인의 최후 주소 ○○시 ○○구 ○○로○길○○-○

대여금청구의 소

청 구 취 지

1. 피고(들)는 원고에게

금30,000,000원 및 위 금원 중 금10,000,000원에 대하여는 20○○. 9. 30부터

금10,000,000원에 대하여는 20○○. 10. 5부터

금10,000,000원에 대하여는 20○○. 10. 19부터

각 금원을 이 사건 소장 부분 송달일까지는 연 5푼, 소장부분 송달 다음 날부터
완제일까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

3. 위 제1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

1. 당사자 관계

망 김철수(000000-0000000, 이하 ‘망인’이라고 약칭합니다)는 아래의 수표를
원고에게 배서양도하고 원고는 동 수표들의 최후 소지인인바, 망인은 20○○. 12.

5. 사망하게 되었고, 피고(들)은 망인의 상속인(들)입니다.

2. 소외 (주)일홍산업대표 배동철은 다음과 같이 수표를 발행하여 망인에게 교부

하였습니다.

다 음

종 류	금 액	지 급 지	지 급 일
가계수표	5,000,000원(주)	제삼은행강남지점	20〇〇. 9. 29.
가계수표	5,000,000원(주)	제삼은행강남지점	20〇〇. 9. 29.
당좌수표	10,000,000원(주)	시민은행종로지점	20〇〇. 10. 4.
당좌수표	10,000,000원(주)	시민은행종로지점	20〇〇. 10. 18.

3. 망인은 원고에게 금30,000,000원에 대한 채무가 있었는데 동 수표를 차용증에 갈음하여 원고에게 배서양도하여 원고는 동 수표들의 최후 소지인이 되었습니다.

4. 원고는 지급기일에 지급장소에 임하여 동 금원의 지급을 구하였으나 무거래라는 이유로 지급이 거절되었습니다.

5. 따라서 원고는 위 수표를 금30,000,000원에 대한 채무변제조로 망인으로부터 받은 것이므로 배서양도인인 망인에게 지급요구하려 했으나 망인은 20〇〇. 12. 5.자에 사망하게 되었고 그의 상속인들은 위 채무를 상속받게 되었습니다.

한편, 원고는 망인의 상속인들을 특정할 수 없는 관계로 추후 사실조회 등의 방법으로 각 상속인을 특정한 이후 당사자표시정정신청 및 청구취지변경을 신청할 예정입니다.

6. 따라서 망인의 상속인인 피고(들)는 망인의 상속채무를 변제할 의무가 있다고 할 것이므로 청구취지와 같은 판결을 받고자 본소 청구에 이른 것입니다.

입 증 방 법

1. 가계수표(갑제1호증의 1, 2)
1. 당좌수표(갑제2호증의 1, 2)

첨 부 서 류

1. 위 입증방법 각1통
1. 소장부분 1통

200○. 4. .

위 원 고 문 상 일 (인)

서울중앙지방법원 귀중

[사례] 물품대금청구의 소(연마자재)

소 장

원 고 삼일연마공업주식회사
 서울 강남구 삼성로123길 4
 대표이사 이 창 수
 전화번호(휴대폰 포함), 팩스번호, 전자우편(e-mail)주소

피 고 망 김철수(000000-0000000)의 상속인
 망인의 최후 주소 ○○시 ○○구 ○○로○길○○-○

물품대금청구의 소

청 구 취 지

1. 피고(들)는 원고에게 금13,476,792원 및 이에 대하여 이 소장부분 송달 익일부터 완제일까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 지급하라.
 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
 3. 위 제1항은 가집행할 수 있다.
- 라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

1. 당사자 관계

원고는 연마자재판매업을 하는 회사이고 피고 망 김철수(이하 ‘망인’이라고 약칭합니다)는 생전에 정밀주조업을 하는 회사를 운영하였고 원고는 망인의 회사에 연마자재를 매월 정기적으로 납품하여 왔고, 망인은 원고로부터 다음 표시의 기재와 같이 연마자재를 매수하고 동일자 인수하는 방법으로 물품거래가 발생하였습니다.

이후 망인은 20〇〇. 12. 5. 사망하게 되었고, 피고(들)은 망인의 상속인(들)입니다.

다 음

(1) 20〇〇. 1. 28. 공급가액 금2,510,720원 부가가치세 251,072원

합계금 2,761,792원정

(2) 20〇〇. 2. 1. 공급가액 금2,150,000원 부가가치세 215,000원

합계금 2,365,000원정

(3) 20〇〇. 2. 1. 공급가액 금2,890,000원 부가가치세 289,000원

합계금 3,179,000원정

(4) 20〇〇. 4. 4. 공급가액 금3,110,000원 부가가치세 311,000원

합계금 3,421,000원정

(5) 20〇〇. 5. 4. 공급가액 금2,500,000원 부가가치세 250,000원

합계금 2,750,000원정

2. 원고는 위 총계금 14,476,792원의 판매대금이 있어 망인의 생전에 그 변제를 촉구한 바 망인은 차일피일 미루어 오다가 20〇〇. 2. 1. 금1,000,000원만 변제하고 나머지 금13,476,792원을 지급하지 아니하였습니다. 그런데 망인은 20〇〇. 12. 5.자에 사망하게 되었고, 피고 망인의 상속인들은 위 채무를 상속받게 되었습니다.

한편, 원고는 망인의 상속인들을 특정할 수 없는 관계로 추후 사실조회 등의 방법으로 각 상속인을 특정한 이후 당사자표시정정신청 및 청구취지변경을 신청할 예정입니다.

3. 따라서 망인의 상속인인 피고(들)는 망인의 상속채무를 변제할 의무가 있다고 할 것이므로 청구취지와 같은 판결을 받고자 본소 청구에 이른 것입니다.

입 증 방 법

1. 거래명세표
1. 기타는 변론시 수시제출하겠음

첨 부 서 류

1. 법인등기부등본 1통
2. 세금계산서 1통

20〇〇. 9. 15.

원 고 삼일연마공업주식회사
대표이사 이 창 규 (인)

[사례] 임대보증금잔금반환청구의 소(점포명도후 보증금청구)

소 장

원 고 권 정 숙 (주민등록번호 -)
서울 동대문구 전농로123길 4
전화번호(휴대폰 포함), 팩스번호, 전자우편(e-mail)주소

피 고 망 김철수(000000-00000000)의 상속인
망인의 최후 주소 ○○시 ○○구 ○○로○길○○-○

임대보증금잔금반환청구의 소

청 구 취 지

1. 피고(들)는 원고에게 금1,850,000원 및 이에 대한 소장 이 송달 익일부터 완제일까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 지급하라.
 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
 3. 위 제1항은 가집행할 수 있다.
- 라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

1. 당사자 관계

피고 망 김철수(이하 ‘망인’이라고 약칭합니다)는 생전에 서울 서초구 반포동 123(반포로123길 4) 지상 점포 약 6㎡에 대한 점포의 주인이고, 원고는 위 점포에 대하여 금8,000,000원 월임대료 금200,000원 임대기간은 20○○. 4. 1부터 12개월로 정하고 망인과 임대차 계약을 체결한 임차권자입니다. 망인은 위 임대차체결이후 20○○. 12. 5. 사망하게 되었고, 피고(들)은 망인의 상속인(들)입니다.

2. 원고와 망인은 임대차 계약을 체결하면서 위 보증금 중 금3,000,000원에 대하여는 원고의 사정으로 6개월 후에 지급하기로 약정하고 그에 대한 이자금조로

월2부로 계산하여 매월 임대료와 이자금을 합하여 금260,000원씩을 지급하기로 하였습니다.

3. 그 후 원고는 장사가 안되어 더이상 영업을 계속할 수 없고 사정이 있어 20〇〇. 8. 11. 망인에게 사유를 알리고 딱한 사정을 호소한 바 있으며 망인도 이를 인정하고 합의해제를 하기로 하여 동일자로 공과금 및 그동안 임대료와 위 이자금을 변제하고 보증금 금5,000,000원을 점포가 나가는 대로 반환하여 주기로 약정한 후 원고는 이건 점포를 망인에게 명도하였습니다.

3. 그런데 망인은 약속을 어기고 동년 8. 11부터 20〇〇. 2. 15까지 6월 4일간의 임대료와 이자금 1,850,000원을 공제하고 금3,150,000원을 20〇〇. 2. 23자로 변제공탁을 하였으나 원고는 인정할 수 없습니다.

4. 원고와 망인은 계약기간이 남아 있으나 위 정산한 날짜로 계약을 해제하고 임대료와 이자금의 지급을 종결하는 조건으로 이건 점포를 명도한 것입니다.

그런데 망인은 20〇〇. 12. 5.자에 사망하게 되었고 피고 망인의 상속인들은 위 채무를 상속받게 되었습니다.

한편, 원고는 망인의 상속인들을 특정할 수 없는 관계로 추후 사실조회 등의 방법으로 각 상속인을 특정한 이후 당사자표시정정신청 및 청구취지변경을 신청할 예정입니다.

5. 따라서 망인의 상속인인 피고(들)는 망인의 상속채무를 변제할 의무가 있다고 할 것이므로 청구취지와 같은 판결을 받고자 본소 청구에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

- 1. 점포월세계약서 1통
- 1. 소장부분 1통
- 1. 납부서 1통

20〇〇. 4. .

원 고 권 정 속 (인)

서울중앙지방법원 귀중

[사례] 보증채무금청구의 소(무자력)

소 장

원 고 정 동 문 (주민등록번호 -)
서울 종로구 종로3가 131길 1
송달주소 서울 강서구 화곡로249길 15
전화번호(휴대폰 포함), 팩스번호, 전자우편(e-mail)주소

피 고 망 김철수(000000-0000000)의 상속인
망인의 최후 주소 ○○시 ○○구 ○○로○길○○-○

보증채무금청구의 소

청 구 취 지

1. 피고(들)는 원고에 대하여 금20,000,000원 및 이에 대하여 이 소장부분 송달
익일부터 완제일까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 지급하라.
 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
 3. 위 제1항에 대하여 가집행할 수 있다.
- 라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

1. 당사자 관계

소외 정만수와 정만규는 형제지간으로 원고는 소외인들에게 20○○. 1. 26. 금
20,000,000원을 변제기일은 동년 6. 26로 하여 동 금원을 대여하면서 피고 망
김철수(이하 ‘망인’이라고 약칭합니다)로 하여금 소외인들이 동 금원을 변제치
못할 시는 망인이 책임을 지겠다는 보증인이 되어 같은 날 원고에게 별첨과 같
이 인감증명서 및 재산세과증명서를 교부하여 주었습니다.

망인은 그후 20○○. 12. 5. 사망하게 되었고, 피고(들)은 망인의 상속인(들)
입니다.

2. 소외인들은 변제일이 지난 지금까지 동 금원을 변제치 아니하고 차일피일 미루고 있어 부득이 소외인들의 보증인인 망인에게 그 지급을 구하였으나 지급치 아니하였고, 그런데 망인은 20〇〇. 12. 5.자에 사망하게 되었고 피고 망인의 상속인들은 위 채무를 상속받게 되었습니다.

한편, 원고는 망인의 상속인들을 특정할 수 없는 관계로 추후 사실조회 등의 방법으로 각 상속인을 특정한 이후 당사자표시정정신청 및 청구취지변경을 신청할 예정입니다.

3. 따라서 망인의 상속인인 피고(들)는 망인의 상속채무를 변제할 의무가 있다고 할 것이므로 청구취지와 같은 판결을 받고자 본소 청구에 이른 것입니다.

입 증 방 법

1. 갑제1호증 차용증
1. 갑제2호증 인감증명서
1. 갑제3호증 재산세과세증명서

첨 부 서 류

- | | |
|-----------|-----|
| 1. 위 입증방법 | 각1통 |
| 1. 소장부분 | 1통 |
| 1. 납부서 | 1통 |

20〇〇. 8. .

원 고 정 동 문 (인)

서울중앙지방법원 귀중

[사례] 체불임금청구의 소

소 장

- 원 고 1. 장 광 수 (주민등록번호 -)
서울 종로구 창신로224길 12
전화번호(휴대폰 포함), 팩스번호, 전자우편(e-mail)주소
2. 김 성 환 (주민등록번호 -)
서울 강남구 신사로384길 52
전화번호(휴대폰 포함), 팩스번호, 전자우편(e-mail)주소

피 고 망 김철수(000000-00000000)의 상속인
망인의 최후 주소 ○○시 ○○구 ○○로○길○○-○

체불임금청구의 소

청 구 취 지

1. 피고(들)는 원고들에 대하여 금11,000,000원 및 이에 대한 이 소장부분 송달
익일부터 완제일까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 지급하라.
 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
 3. 위 제1항에 대하여 가집행할 수 있다.
- 라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

1. 당사자 관계
원고들은 피고 망 김철수(이하 ‘망인’이라고 약칭합니다)가 생전에 운영하던 회
사인 상호 “○○연마(○○시 ○○구 ○○로123길 4 대표자 망 김철수, 이하 ○
○연마라 한다)”에 소속된 근로자들입니다.
망인은 20○○. 12. 5. 사망하게 되었고, 피고(들)은 망인의 상속인(들)입니다.
2. 원고 장광수는 위 망인이 운영하는 ○○연마회사에서 20○. 9. 1부터 동년 11.

30까지 92일간의 체불임금이 금6,000,000원이 되고, 원고 김성환은 20○. 10. 1부터 동년 12. 31까지 91일간의 체불임금이 금5,000,000원이 되어 합계 11,000,000원이 원고들에게 미지급되어 수차 독촉하였으나 이에 응하지 아니하다가 그 대표자인 망인은 20○○. 12. 5.자에 사망하게 되었고 피고 망인의 상속인들은 위 채무를 상속받게 되었습니다.

한편, 원고들은 망인의 상속인들을 특정할 수 없는 관계로 추후 사실조회 등의 방법으로 각 상속인을 특정한 이후 당사자표시정정신청 및 청구취지변경을 신청할 예정입니다.

3. 따라서 망인의 상속인인 피고(들)는 망인의 상속채무를 변제할 의무가 있다고 할 것이므로 청구취지와 같은 판결을 받고자 본소 청구에 이른 것입니다.

입 증 방 법

1. 체불임금확인원
1. 평균임금산정서
1. 기타는 변론시 제출하겠습니다.

첨 부 서 류

- | | |
|------------|----|
| 1. 법인등기부등본 | 1통 |
| 1. 소장부분 | 1통 |
| 1. 납부서 | 1통 |

20 . 4. .

원 고 장 광 수 (인)

김 성 환 (인)

[사례] 약속어음금청구의 소

소 장

원 고 대산섬유주식회사 (법인등록번호 -)
 ○○시 ○○구 ○○로○길○○-○
 대표이사 최 두 식

위 소송대리인 변호사 김 문 수
 서울 서초구 서초로31
 전화번호(휴대폰 포함), 팩스번호, 전자우편(e-mail)주소

피 고 망 김철수(000000-0000000)의 상속인
 망인의 최후 주소 ○○시 ○○구 ○○로○길○○-○

약속어음금청구의 소

청 구 취 지

1. 피고(들)는 원고에게 금67,700,000원 및 이 소장 부분 송달의일부터 완제일까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 지급하라.
 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
 3. 위 제1항은 가집행할 수 있다.
- 라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

1. 당사자 관계

피고 망 김철수(이하 ‘망인’이라고 약칭합니다)는 생전에 서울 서초구 반포동 123(반포로123길 4)에서 ○○이라는 상호로 포목점을 운영하였고, 원고는 대산섬유주식회사의 대표로서 망인에게 아동복섬유원단을 납품한 자입니다. 망인은 20○○. 12. 5. 사망하게 되었고, 피고(들)은 망인의 상속인(들)입니다.

2. 원고는 20〇〇. 12. 5. 아동복섬유원단을 망인에게 납품하고 그 물품대금이 62,700,000원이 되어 망인에게 그 지급을 독촉하자 다음과 같은 약속어음 3매를 망인로부터 원단대금으로 수령하였습니다.

다 음

번 호	자가12345678	자가2345678	자가1234567890
액 면 금	15,700,000	20,000,000	27,000,000
발 행 일	20〇〇. 6. 21	20〇〇. 6. 31.	20〇〇. 6. 31.
지 급 일	20〇〇. 8. 15	20〇〇. 8. 31.	20〇〇. 9. 6.
지 급 지	서울특별시	서울특별시	서울특별시
지급장소	제삼은행 수유동지점	제삼은행 수유동지점	제삼은행 수유동지점
발 행 인	김 철 수	김 철 수	김 철 수

3. 원고는 위 약속어음 3매를 소외인들에게 각 배서양도한 바 있는데 동 어음들은 지급기일에 지급장소에 임하여 그 지급을 구하였으나 모두 무거래라는 이유로 지급이 거절되어 원고는 동 어음들을 모두 회수하였습니다.

4. 또한 원고는 소외 민철규로부터 원단대금조로 망인 발행의 금5,000,000원권 지급장소 제삼은행 수유동지점으로 된 약속어음 1매를 교부받아 소외인에게 배서양도한 바 있으나 또한 무거래라는 이유로 지급장소에서 거절당하여 동 어음을 회수하였습니다.

그런데 망인은 20〇〇. 12. 5.자에 사망하게 되었고 피고 망인의 상속인들은 위 채무를 상속받게 되었습니다.

한편, 원고는 망인의 상속인들을 특정할 수 없는 관계로 추후 사실조회 등의 방법으로 각 상속인을 특정한 이후 당사자표시정정신청 및 청구취지변경을 신청할 예정입니다.

5. 따라서 망인이 생전에 발행한 위 어음의 금액은 상속채무에 해당하므로 그 상속인인 피고(들)가 변제할 의무가 있다고 할 것이므로 청구취지와 같은 판결을

받고자 본소 청구에 이른 것입니다.

입 증 방 법

1. 강제1호증의 1 내지4 약속어음

첨 부 서 류

1. 소장부분 1통
1. 위임장 1통

20〇〇. 10. .

위 원 고 소송대리인 변호사 김 문 수 (인)

서울북부지방법원 귀중

3. 소장의 정정과 보정

(1) 개 설

피고를 “망 김철수의 상속인”으로 기재하여 제기한 소는 법원이 보정명령을 내리게 되는데 법원으로부터 보정명령이 나오면 피고(피상속인 : 망인)를 그 상속인으로 정정하여야 한다. 상속인이 여럿인 경우에는 그 모두를 피고로 하여야 한다.

그 방법은 보정명령서를 가지고 가까운 주민센터에 가서 사망한 채무자의 제적등본과 가족관계증명서를 발급받고, 채무자의 상속인(상속인이 여럿인 경우에는 각자의 주민등록초본을 발급받는다)의 주민등록초본을 발급 받아 당사자표시정정서(708면 참조)와 함께 법원에 제출한다. 상속인이 여럿인 경우에는 청구취지도 변경(710면 참조)하여야 한다.

(2) 피고표시정정

“피고표시정정”이란 원고가 소를 제기할 때 피고의 성명을 착오로 잘못 표시한 경우 이를 바로 잡는 절차를 말한다. 이는 피고경정(민소법 제260조)과는 구별되는 제도이다. 피고경정은 당사자의 교체 그 자체이나 피고표시정정은 당사자의 잘못 표시된 성명만을 고치는 제도이다.

판례는 “원고가 피고의 사망 사실을 모르고 사망자를 피고로 표시하여 소를 제기한 경우에, 청구의 내용과 원인사실, 당해 소송을 통하여 분쟁을 실질적으로 해결하려는 원고의 소제기 목적 내지는 사망 사실을 안 이후 원고의 피고표시정정신청 등 여러 사정을 종합하여 볼 때에, 실질적인 피고는 당사자능력이 없어 소송당사자가 될 수 없는 사망자가 아니라 처음부터 사망자의 상속자이고 다만 그 표시에 잘못이 있는 것에 지나지 않는다고 인정되면 사망자의 상속인으로 피고의 표시를 정정할 수 있다 할 것인바, 상속개시 이후 상속의 포기를 통한 상속채무의 순차적 승계 및 그에 따른 상속채무자 확정 of 곤란성 등 상속제도의 특성에 비추어 위의 법리는 채권자가 채무자의 사망 이후 그 1순위 상속인의 상속포기 사실을 알지 못하고 1순위 상속인을 상대로 소를 제기한 경우에도 채권자의 의도한 실질적 피고의 동일성에 관한 위 전제요건이 충족되는 한 마찬가지로 적용이 된다.”⁶³⁷⁾고 판시하였다.

만일 피고의 성명을 잘못 표기한 채로 판결을 받게 되면 판결문(또는 집행문)에도 피고의 오류된 성명이 그대로 기재되어 피고 명의로 된 부동산이 있더라도 압류할 수 없어

637) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다49964 판결 [상속채무금]

그때까지의 송사가 헛수고로 되는 경우가 있다. 변론종결전에 법인의 상호나 대표자가 바뀌었음에도 불구하고 전상호나 전대표자 명의로 판결을 받았다면 이는 무효가 된다.

[사례] 당사자표시정정 신청서(표지)

당사자표시정정 신청서

사 건 20○○가소○○○○ 상속채무금
원 고 ○○캐피탈 주식회사
피 고 망 김철수의 상속인

서울중앙지방법원 귀중

당사자표시정정 신청서

사 건 20○○가소○○○○ 상속채무금

원 고 ○○캐피탈 주식회사

피 고 망 김철수의 상속인

위 사건과 관련하여, 망 김철수의 상속인들을 확인하였으므로 아래와 같이 피고의 상속인들을 특정하여 당사자표시정정신청을 하는 바입니다.

= 아 래 =

변경 후 당사자의 표시

피고 1. 강영숙 (000000-000000)

○○시 ○○구 ○○로○길○○-○

2. 김일여 (000000-000000)

○○시 ○○구 ○○로○길○○-○

3. 김이여 (000000-000000)

○○시 ○○구 ○○로○길○○-○

4. 김삼여 (000000-000000)

○○시 ○○구 ○○로○길○○-○

20○○. 5. .

위 원고 ○○캐피탈 주식회사

대표이사 ○○○

서울중앙지방법원 귀중

※ 인지는 붙이지 아니한다.

※ 상속인이 여럿명이어서 상속분에 따른 청구취지정정신청(710면 참조)도 하여야 한다.

4. 청구취지 변경신청

가. 개 설

“피상속인(채무자)의 이름과 그 상속인”으로만 기재하여 제기한 소는 법원이 보정명령을 내리게 되는데 이때 피상속인(채무자)에게 상속인이 1인이라면 전술한 당사자표시정정서만 제출하면 되나 상속인이 여럿이 있는 경우에는 청구금액을 상속인들의 상속비율에 맞도록 변경하여야 하므로 청구취지변경신청서도 함께 제출해야 한다.

따라서 상속인이 여럿(형제, 자매, 손자 등)이 있는 경우 상속재산은 해당 공동상속인의 법정상속분비율에 의하여 분할기재하여야 한다.

원고는 청구의 기초에 변경이 없는 한도 내에서 변론의 종결에 이르기까지 청구의 취지 및 원인을 변경할 수 있다(민소법 제262조 제1항). 소의 변경은 청구자체를 변경할 것을 요한다. 청구취지를 보충하거나 정정하는 것은 청구의 변경이 아니다.

나. 신청절차

판례는 청구취지의 변경뿐만 아니라 심판의 대상이나 내용을 바꾸는 경우에도 소의 변경으로 인정하였다. 청구취지 확장의 경우에는 확장된 금액의 인지를 붙여야 한다.

다. 상속비율 등

상속인들의 상속순위 및 상속비율(163면 참조), 상속인들 중 상속포기자가 있는 경우와 대습상속이 있는 경우 상속자 및 상속비율의 변화에 대하여는 181면 참조

[사례] 청구취지 및 청구원인 변경신청서

청구취지 및 청구원인 변경신청서

사 건 20○○가소○○○○ 상속채무금

원 고 ○○캐피탈 주식회사

피 고 망 김철수의 상속인

위 사건과 관련하여, 원고는 다음과 같이 청구취지 및 청구원인 변경을 신청하는 바입니다.

변경전 청구취지

1. 피고(들)은 원고에게 금15,000,000원과 그 중 금14,000,000원에 대하여 20○○. 1. 10.부터 다 갚는 날까지 연 20.8%의 비율에 의한 돈을 지급하라.
 2. 소송비용은 피고(들)의 부담으로 한다.
 3. 제1항은 가집행할 수 있다.
- 라는 판결을 구합니다.

변경된 청구취지

1. 피고들은 원고에게 각
 - 가. 피고1. 강영숙은 금4,999,999원과 그 중 금4,666,666원에 대하여,
 - 나. 피고2. 김일여는 금3,333,333원과 그 중 금3,111,111원에 대하여,
 - 다. 피고3. 김이여는 금3,333,333원과 그 중 금3,111,111원에 대하여,
 - 라. 피고4. 김삼여는 금3,333,333원과 그 중 금3,111,111원에 대하여,
 20○○. 1. 10.부터 다 갚는 날까지 연 20.8%의 비율에 의한 돈을 지급하라.
 2. 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.
 3. 제1항은 가집행할 수 있다.
- 라는 판결을 구합니다.

변경된 청구원인

1. 원고의 기존 소장을 원용합니다.
2. 망인으로부터 상속재산을 상속받은 상속인들은 배우자 강영숙(상속지분 3/9), 자녀 김일여(상속지분 2/9), 김이여(상속지분 2/9), 김삼여(상속지분 2/9)으로써 망인의 채무에 각 상속지분에 의하여 청구취지를 변경하는 바입니다.

20○○. 5. .

위 원고 ○○캐피탈 주식회사
대표이사 ○○○

서울중앙지방법원 귀중

제2절 답변서

1. 서 설

가. 의 의

“답변서”란 피고 또는 피상소인이 원고 또는 상소인의 소장·상소장에 대응하여 그 심급에서 처음으로 제출하는 서면을 말한다. 즉 상대방(원고) 신청의 배척을 구하는 준비서면의 성질을 가진 반대신청서이다. 따라서 답변서에 관한 규정은 준비서면에 관한 규정을 준용한다.

한정승인을 받았는데 망인의 채권자가 상속채무를 변제하라는 소송을 제기한 경우 한정승인과는 별개로 반드시 해당 소송에 대하여 한정승인, 상속포기, 특별한정승인을 했다는 답변서를 꼭 제출하여야 한다.

한정승인자의 경우에는 한정승인심판만 받으면 채무가 자동으로 없어지거나 채무를 면제받는 것이 아니기 때문에 한정승인을 진행하는 중에도 채권자들로부터 소제기를 받을 경우 답변서, 준비서면을 제출하여 대응하여야 하고, 한정승인, 상속포기, 특별한정승인심판을 받은 경우에는 위 심판문 사본을 첨부하여 답변서 등을 꼭 제출하여야 한다.

한편 한정승인은 상속인이 상속받은 재산의 범위내에서 채무를 변제할 책임이 있고, 상속인의 고유재산으로 채무를 변제하지 않아도 되는 것이므로, 채권자가 소송이나 강제집행을 하면 상속받은 재산의 범위내에서 변제하겠다는 항변을 하여야 할 것이다.

나. 요 건

원고가 소를 제기하면 그 부분이 피고에게 송달되는바, 피고는 그 소장을 읽은 다음 응소할 의사가 있으면 소장부분의 송달수령일부터 30일이내에 답변서를 제출하여야 하고, 원고의 청구를 그대로 인정하는 경우에는 답변서를 제출하지 아니하여도 무방하다.

법원은 피고가 답변서를 제출하지 아니한 때, 또는 피고가 원고의 주장사실을 모두 인정하는 취지의 답변서를 제출한 때에는 그것이 직권조사사항이 아닌한 법원은 변론없이 판결할 수 있다. 이를 무변론 판결제라 한다(민소법 제257조). 다만, 직권으로 조사할 사항이 있거나 판결이 선고되기까지 피고가 원고의 청구를 다투는 취지의 답변서를 제출한 경우에는 예외다.

이 제도는 무변론판결인 종전의 제205조에 따른 소 각하 판결과 소액사건의 청구기각판결이 소제기에 대하여 변론의 기회도 주지 않고 패소판결을 하고 있는 바, 위와 같은 판결형태보다는 피고가 명백히 다투지 아니하는 경우에 변론없이 원고승소판결을 하는 것이 상대적으로 더욱 타당하다는 고려에서 도입한 것이다. 이에 따라 쟁점정리기일이나 변론기일을 열 필요도 없이 원고승소판결을 할 수 있다면 원고의 기일출석부담을 줄이고 소송의 촉진을 기하는 효과가 있을 것으로 보인다.

그러나 피고가 원고의 청구에 대하여 자백할 의사가 없음에도 법률지식의 부족등으로 인하여 답변서 제출기간을 넘기는 경우도 예상할 수 있다.

2. 답변서 작성방법

가. 개 설

답변서에는 원고의 주장에 대한 답변(민소규칙 제65조), 즉 ㉠청구의 취지에 대한 답변, ㉡청구의 원인에 대한 구체적인 진술 및 공격방어방법을 적고 ㉢그에 대한 증거방법과 입증취지도 명시하여야 한다.

답변서는 소장의 청구취지에 대한 답변과 청구원인에 대한 답변으로 구성하는데, 답변서를 제출하더라도 구체적인 내용없이 단순히 부인한다 또는 모른다고만 기재한 채 변론기일에 출석하지 아니할 때에는 진정으로 원고의 제소를 방어할 의사가 없다고 인정되어 불이익을 받게 될 수도 있다.

답변 할 의사가 있는 경우 답변서를 제출할 기한이 촉박한 때에는 구체적인 내용없이 단순히 “원고의 청구를 부인한다”는 식의 형식적 내용으로 답변서를 작성하여 제출하게 되면 법원사무관 등은 방식에 맞는 답변서를 제출할 것을 촉구하게 되고 이때 구체적인 준비서면을 제출하면 될 것이다.

나. 답변의 내용

(1) 청구의 취지에 대한 답변 :

관할위반의 경우 소송의 이송을 구하는 주장, 소 각하를 구하는 주장, 청구기각의 주장 또는 포기·인낙, 소송비용부담의 신청, 가집행면제의 선고신청이 있다.

(2) 청구의 원인에 대한 구체적인 진술 및 공격방어방법

원고의 청구원인을 면밀히 분석하여 인정할 부분과 부인할 부분을 구분, 부인할 부분에

대하여 이유를 밝히고, 인정할 부분에 대하여도 항변사유가 있으면 항변과 동시에 이유를 밝혀야 한다.

가) 자백

피고가 원고의 주장사실을 다투지 않고 시인하는 진술이다. 자백한 사실에 대하여는 증거가 필요 없고(민소법 제288조), 법원으로서도 이에 반하여 사실을 인정할 수 없다.

나) 부인

상대방이 주장하는 사실에 대하여 그런 사실이 존재하지 않았다거나 진실에 반하는 것이라고 주장하는 것이다. 원고가 권리 또는 법률관계의 존재를 주장한 경우 피고가 그 주장 사실을 부인하면 원고가 요건사실을 입증하여야 한다. 실무에서는 「원고 주장 사실을 다룬다(또는 부인한다)」라고 하거나 「원고 주장 사실과 다르다」고 쓴다.

부인을 함에는 상대방이 주장하는 사실이 진실이 아니라고 말하는 것에 그치는 경우(직접부인, 소극부인 또는 단순부인)와, 상대방이 주장하는 사실과 양립할 수 없는 별개의 사실을 주장함으로써 간접적으로 상대방의 주장을 부인하는 경우(간접부인, 적극부인 또는 이유부부인)가 있다.

상대방의 주장에 대하여 단순히 부인할 뿐 적극적으로 진실에 관한 주장을 하지 아니하면 부인에 대한 심증을 약화시킬 수 있으므로, 상대방의 주장이 허위이고 나아가 진실은 무엇이라고 주장을 할 필요가 있다. 이 경우에는 상대방의 주장을 부인하는 기재와 항을 달리하여 진실에 관한 기재를 함으로써 피고의 주장이 항변으로 오해되지 않도록 할 필요가 있으며, 원고가 요건사실에 관한 입증은 하지 아니하고 피고의 주장 사실에 관하여 시비를 할 수도 있으므로 주의하여야 한다.

다) 부지

피고가 원고의 주장 사실이 진실인지 아닌지 모르겠다고 하는 진술은 부인으로 추정된다(민소법 제150조 제2항).

자기가 관여하지 아니한 제3자의 행위에 대하여는 부지라고 진술할 수 있으나, 자기의 행위나 자기 명의의 문서 등에 대하여 부지라고 진술함은 적합하지 않다. 자기의 행위에 대한 것이라고 시일의 경과 등으로 명확히 기억을 할 수 없는 경우가 있는 바, 이 경우에는 그 사유를 설명하고 기억할 수 없다 또는 모르겠다고 대답할 수도 있다.

라) 침묵

변론에서 상대방이 주장한 사실을 명백히 다투지 아니한 때에는 변론의 전취지에 의하여 이를 다투는 것으로 인정되지 아니하는 한, 그 사실을 자백한 것으로 보게 되고(민소법 제150조 제1항), 피고가 공시송달에 의하지 아니한 적법한 소환을 받고서도 변론기일에

출석하지 아니하고 답변서 기타 준비서면도 제출하지 아니하여 원고의 주장 사실을 명백히 다투지 아니하면 청구원인 사실 전부를 자백한 것으로 처리된다.

상대방의 주장에 대하여 그 인부를 명백히 하지 아니하는 침묵은 바른 인부 태도가 아니며, 상대방의 새로운 주장이 나오면 이에 대한 인부를 명백히 하여야 할 것이다. 실무상으로는 상대방이 새로운 준비서면을 진술하고 미처 검토할 시간적 여유가 없는 경우에는 종전 주장에 반하는 부분은 부인한다는 취지의 진술을 하여 두는 것이 보통이다.

(3) 인부(認否)기재의 방법

(가) 개 설

원고가 청구원인으로 주장한 순서에 따라 「제1항은 인정하고, 제2항은 부인한다」는 식으로 정리하거나, 「제1항 중 ...의 사실은 인정하고 그 나머지 사실은 모두 부인한다」고 하거나, 반대로 「...의 사실은 부인하고 그 나머지 사실은 인정한다」는 식으로 쓴다.

청구원인사실 중 인정하는 부분만을 추려서 적시하고 기타의 사실은 부인한다고 하거나 반대로 부인할 부분만을 추려서 적시하고 기타의 사실은 인정한다는 식으로 정리하기도 한다. 어느 경우이든 원고의 청구원인 중 어느 부분과 관련한 내용임을 알 수 있게 함으로써 족하고 원고의 주장을 되풀이하여 기재하는 것은 피한다.

법관이나 상대방이 쟁점을 정리하기 쉽게 쓴다. 따라서 원고주장 사실을 전면적으로 부인하는 것인지 또는 일부는 인정하고 나머지는 부인하는 것인지 아니면 전부 인정하고 항변을 주장하는 것인지를 명백히 알 수 있게 하여야 한다.

(나) 인부에 관하여 유의할 사항

원고의 주장 사실에 대한 인부는 중대한 의미를 가지는 것이므로 신중하게 정리하여야 한다. 일단 자백하였다가 이를 부인으로 바꾸는 것은 자백의 취소가 되어 상대방의 동의가 있거나 또는 그 자백이 진실에 반하고 착오에 기인한 것임을 증명한 때에 한하여 할 수 있고(민소법 제288조), 자백취소의 시기를 놓치면 실기한 공격방어방법이라 하여 각하될 염려가 있으며(민소법 제149조), 일단 부인하였다가 후에 자백하는 것은 어렵지 않으나 법관의 심증형성에 나쁜 영향을 미칠 염려가 있으므로, 처음부터 자백과 부인을 명백히 하는 것이 좋다.

소장의 청구원인에서 요건사실 외에 예상되는 항변에 대한 적극부인이나 항변 사실을 선행 자백하고 재항변 사실이 기재된 경우에는 이러한 사실에 관하여도 인부를 하여야 하고, 특히 선행 자백에 대하여는 이익으로 원용한다는 취지를 명백히 하여 둔다.

(다) 피고의 주장(항변 등)

① 개 설

답변서의 내용은 청구의 취지에 대한 답변과 청구의 원인에 대한 인부에 그치지 아니하고 원고의 청구를 이유 없게 할 모든 사실상 및 법률상의 주장을 포함한다. 원고의 주장 사실과 양립하지 아니하는 사실(적극부인, 예컨대 매매대금청구 사건에서 증여의 주장), 원고의 주장 사실이 존재하는 것을 전제로 하면서 원고의 청구를 배척하기에 족한 사실(항변), 원고의 주장 사실과 양립하면서 원고 주장의 법률요건의 존재를 부정하기에 족한 특별한 사정에 해당하는 사실, 원고의 주장 사실로부터 원고의 주장의 권리가 발생하지 아니하거나 피고 주장 사실로부터 원고의 청구가 배척되어야 한다는 법률적 견해에 관한 주장 등이 포함된다.

② 항 변

어느 사실이 항변에 해당하는지 부인에 해당하는지는 실체법의 해석에 따라 달라질 것이나, (㉠)법률효과의 발생에 장애가 되는 예외적 사유(행위능력의 흠결, 의사표시의 하자 등), (㉡) 발생한 법률효과를 소멸시키는 사유(변제, 시효소멸, 해제 등), (㉢) 발생한 법률효과의 행사를 저지하는 사유(기한 미도래, 동시이행관계 등)가 항변의 주된 내용이 된다.

채권자가 상속인이 상속포기를 한 사실을 모르고 상속포기자를 상대로 상속채무금의 소를 제기한 경우에는 상속포기자는 상속포기사실을 증명하여 적극적으로 항변하여야 할 것이다.

한정승인은 상속인이 상속받은 재산의 범위내에서 채무를 변제할 책임이 있고, 상속인의 고유재산으로 채무를 변제하지 않아도 되는 것으로, 상속받은 재산의 범위내에서 변제하겠다는 항변을 할 수 있다.

③ 항변의 기재방법

항변 사실은 일자를 특정하여 구체적으로 기재하여야 한다. 그러나 증거의 검토나 사실관계의 면밀한 조사의 시간적 여유가 없는 상황에서 입증에 관한 확신이 없는 경우에는 항변의 요지만을 기재하였다가 증거를 확보하거나 증거조사를 마친 후 상세한 내용을 준비서면으로 제출할 것이다.

결론 부분에 있어서는 소장의 결론에 대응하여 「원고의 청구는 이유가 없으므로 기각되어야 할 것입니다」라는 기재를 한다.

④ 유의사항

변제·면제 등과 같이 그 사실의 존재만으로 법률효과가 생기는 경우는 사실의 진술로 족하나, 취소, 해제, 상계 등과 같이 그 권리의 존재뿐 아니라 이를 행사할 것이 요구되는 경우에는 권리의 발생 요건 사실과 아울러 이를 행사한 사실까지 주장 입증하여야 함은 물론이다.

다. 답변서 제출방법

① 법원은 소장부분 등의 송달과 함께 후술하는 소송절차안내서를 피고에게 보내고 있는바, 피고가 원고의 청구를 다투는 경우에는 소장의 부분을 송달받은 날부터 30일내에 답변서를 제출하여야 한다.

② 답변서는 원고 수만큼의 부분을 함께 제출하여야 한다. 다만, 상대방인 원고가 수인이 라도 그 대리인이 1인이면 부분이면 1통으로 족하다. 그러나 대리인이 개별적으로 있는 경우에는 당사자수 만큼의 부분을 첨부하여야 한다.

③ 증거로 제출할 서류는 반드시 원본과 함께 미리 사본(상대방수+1통)을 준비하고, 증인은 그 주소, 성명을 알아두었다가, 가능한 가장 빠른 시기에 필요한 증거를 일괄하여 제출 또는 신청하여야 한다.

실무에서는 원고가 소장부분에 제출한 서증의 사본을 붙여 보내는 수가 있고 그에 대하여 피고가 그 서증의 인부를 답변서에 기재하는 예가 더러 있다. 그러나 서증의 사본을 소장이나 준비서면에 첨부하였다 해도 그것은 서증의 제출로 볼 수 없고 서증의 원본을 법관에게 제출하는 것이 서증의 제출로 되는 것이므로(민소법 제355조) 아직 그 단계에서는 서증이 제출되었다 할 수 없다. 그리고 서증에 대한 인부를 실수없이 하려면 서증의 원본을 실제로 보고 필적, 인영, 지질 기타의 정황을 충분히 검토하고 사본이 정확한가의 여부까지 확인한 후에 하는 것이 좋다.

④ 인지는 붙이지 아니한다. 소송의 계속법원에 제출한다.

[사례] 답변서⁶³⁸⁾

답 변 서

사 건 20〇〇가소〇〇〇〇 상속채무금
원 고 〇〇캐피탈 주식회사
피 고 망 김철수의 상속인 강영숙 외 3명

서울중앙지방법원 귀중

638) 채권자의 소장에 대한 답변서(한정승인을 받고 상속재산파산신청을 한자의 답변서임)

답 변 서

사 건 20〇〇가소〇〇〇〇 상속채무금

원 고 〇〇캐피탈 주식회사

피 고 망 김철수의 상속인 강영숙 외 3명

위 사건에 관하여 피고 강영숙, 김일여, 김이여, 김삼여는 아래와 같이 답변합니다.

청구 취지에 대한 답변

1. 원고의 피고 강영숙, 김이여, 김삼여에 대한 청구를 각하한다.
 2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
- 라는 판결을 구합니다.

청구 원인에 대한 답변

1. 원고의 주장은 『20〇〇. 9. 16. 원금15,000,000원에 대하여 망 김철수(이하 ‘망인’이라고 약칭합니다)에게 대출을 하였으나, 망인은 이 돈을 변제하지 못하였으므로 망인의 상속인 피고 강영숙(배우자), 김일여(자녀), 김이여(자녀), 김삼여(자녀)은 각 상속비율로 위 원리금을 지급하라』는 취지의 주장을 하고 있습니다.
2. 그런데 망인이 20〇〇. 12. 5. 사망한 이후 피고 강영숙, 김이여, 김삼여는 서울가정법원 20〇〇노단000 상속재산포기의 신청을 하였으므로 원고의 피고 강영숙, 김이여, 김삼여에 대한 청구는 각하되어야 상당합니다[을 제1호증 상속재산포기].
3. 한편, 피고 김일여는 서울가정법원 20〇〇노단000 상속한정승인을 득한 후 곧 바로 상속한정승인에 대한 신문 공고를 완료하였고[을 제2호증 상속한정승인, 을 제3호증 신문공고], 아울러 망인의 상속재산에 대하여 서울회생법원 20〇〇하단000 상속재산파산신청을 하였습니다[을 제4호증 나의사건검색].

4. 그런데 상속한정승인의 효과는 민법 제1028조에 의하여 『상속인은 상속으로 인하여 취득할 재산의 한도에서 피상속인의 채무와 유증을 변제할 것을 조건으로 상속을 승인』 하는 것을 말하므로, 피고 김일여는 망인으로부터 취득한 재산(적극재산)의 범위 내에서 상속채권자들에게 그 상속채무를 변제할 의무가 있는 것입니다.
5. 따라서 원고의 피고 김일여에 대한 이권 청구는 “망 김철수로부터 상속받은 재산의 한도 내”에서 판결이 선고되어야 할 것인바, 그런데 피고 김일여는 현재 서울회생법원 20○○하단000 상속재산파산신청을 제기하였으므로 원고의 피고 김일여에 대한 이권 청구는 위 상속재산 파산절차에 의하여 적절한 배당금을 수령함으로써 원고의 피고 김일여에 대한 상속채무관계는 종결되어야 할 것입니다.

입 증 방 법

- | | |
|-----------|--------|
| 1. 을 제1호증 | 상속재산포기 |
| 1. 을 제2호증 | 상속한정승인 |
| 1. 을 제3호증 | 신문공고 |
| 1. 을 제4호증 | 나의사건검색 |

20○○. 5. .

- 위 피고 1. 강영숙
2. 김일여
3. 김이여
4. 김삼여

제3절 준비서면

1. 서 설

가. 의 의

준비서면이란 당사자가 변론기일에서 진술하려는 사실을 기재하여 법원에 제출하는 서면을 말한다. 이 제도는 소송의 심리에 있어서 변론의 기본원칙인 구술주의를 적용하여 심리한다면 변론에서 구술로 진술할 경우 그 상대방은 그 진술에 대응하여 응답을 하기 어려울 경우가 있을 것이다. 따라서 이로 인하여 소송관계의 번잡과 소송의 지연을 가져오게 할 염려가 있는 경우 당사자에게 그 공격·방어방법을 서면으로 작성하여 변론기일전 서면에 의한 쟁점정리절차에서 제출케 하여 소송의 촉진과 심리의 적정을 기하기 위함에 있다. 따라서 지방법원합의부와 상급심에서는 반드시 준비서면을 제출하여 변론의 준비를 하여야 한다(민소법 제272조). 지방법원단독부사건에서는 상대방이 준비를 하지 않으면 진술을 하지 못하리라고 인정되는 사항에 대해서만 준비서면을 제출하게 하고 있다.

민사소송법은 서면에 의한 쟁점정리절차에서 서면의 공방이라 하여 다투는 내용의 답변서가 제출되면, 원고에게 발송일로부터 3주 정도로 기한을 정하여 피고의 답변에 대한 반박 준비서면 및 입증자료를 제출하도록 최고 한다. 따라서 정해진 기한 내에 준비서면을 제출하지 않으면 원칙적으로 더 이상 주장·입증할 사항이 없는 것으로 보아 재판장이 기록을 하게 된다.

나. 준비서면의 기재사항

(1) 개 설

준비서면에는 아래의 사항을 기재하고 당사자 또는 대리인이 이에 기명날인 또는 서명하여야 한다(민소법 제274조). 기명날인이 없더라도 무효는 아니다.

- ① 당사자의 성명, 명칭 또는 상호와 주소 ② 대리인의 성명과 주소 ③ 사건의 표시
- ④ 공격 또는 방어의 방법 ⑤ 상대방의 청구와 공격 또는 방어의 방법에 대한 진술 ⑥ 덧붙인 서류의 표시 ⑦ 년 월 일 ⑧ 법원의 표시

위 ④, ⑤는 실질적기재 사항이고 그밖에 것은 형식적 기재사항이다.

(2) 공격 또는 방어의 방법

(가) 개 설

공격 또는 방어방법에 대한 진술은 상대방이 주장하는 개개의 공격 또는 방어방법, 즉 청구를 뒷받침하는 요건사실, 항변·재항변 등으로 주장된 사실에 대한 인정, 부인, 부지의 진술을 말한다. 흔히“원고(또는 피고)의 종래의 주장에 반하는 사실은 모두 부인한다”는 진술이 있으나 이러한 진술로는 쟁점의 부각에 도움을 줄 수 없으므로 반드시 개개의 사실마다 명확한 인부를 하여 두어야 한다.

공격방어방법에 관하여 소장이나 답변서 또는 이미 제출한 준비서면에 그 기재가 있다 하더라도 소송의 진행에 따라 입증자료의 부족, 반대 사실의 출현 등에 의하여 처음 예상한 바와 달라지는 경우에는 이에 따라 주장을 보충, 추가 또는 변경할 필요가 있고, 그것이 소송 목적물을 변경하는 경우에는 소 변경신청서로 청구를 변경한다. 청구취지의 변경이 수반되지 아니하는 경우에는 준비서면에서 소 변경의 내용을 기재할 수도 있다. 청구의 변경에 따라 소송물의 가액이 증가되는 경우에는 인지를 더 첨부하여야 함은 물론이다. 이와 같이 주장을 변경함에 있어 종전 주장이 잘못된 것임이 명백한 경우에는 교환적으로 주장을 변경하게 되나, 그렇지 아니한 경우에는 예비적으로 주장을 추가하는 방법을 사용한다.

(나) 사실에 관한 주장

㉠ 요건사실과 주장

준비서면에 사실에 관하여 주장을 기재하는 경우에는 될 수 있는 한 청구를 이유있게 하는 사실, 항변사실, 또는 재항변 사실에 관한 주장과 관련된 사실에 관한 주장을 구분하여 기재하고, 간접사실이나 보조사실에 관하여는 어느 요건사실과 관련된 것인지, 이를 주장하는 목적이 무엇인지를 명확하게 함으로써 법원으로 하여금 주장을 이해 정리하기 쉽게 하여야 한다.

㉡ 사실주장의 방법

요건사실의 주장은 구체적으로 어느 정도의 사실을 주장하여야 하는가 하는 것은 일률적으로 말하기 어려우나, 당해 실체법규가 정하는 법률요건을 분석하여 그에 해당하는 사실은 빠짐없이 주장하여야 할 것이다. 사실에 관한 주장을 함에 있어서는 행위의 주체, 일시, 상대방, 행위의 내용을 기재하는 방법으로 이를 묘사하면 되고, 행위의 장소는 사고의 내용, 전후 경위 등을 설명함에 꼭 필요한 경우이거나 준거법의 결정 등의 문제가 되는 경우에만

기재하는 것이 보통이다.

(다) 법률에 관한 주장

소의 요건으로서는 일정한 권리의 주장이 필요하고, 특히 상고, 재항고 등 법률심에 대한 불복 신청이거나, 법률적 견해가 대립되어 판례 변경의 필요가 있거나 법률의 적용에 관한 법원의 주의를 환기시킬 필요가 있는 경우에는 법률에 관한 주장도 필요하다.

(라) 증거에 관한 주장

㉠ 증거설명서

당사자는 준비서면으로 증거의 신청, 제출된 증거자료에 대한 설명, 상대방 증거의 증명력을 다투는 취지의 진술을 할 수 있다. 특히 서증의 경우에는 증거설명서를 작성하여 문서의 성립에서부터 그 내용에 이르기까지 상세한 설명을 하는 것이 좋고, 증인의 증언도 소송의 결과에 중대한 영향을 미치는 것이므로 증언한 내용을 잘 검토하여 증거설명을 하여야 할 것이다.

㉡ 증거항변서

증거 항변은 상대방이 제출한 증거나 자기에 불리한 증언, 진술 등에 대하여 그 증거능력을 다투거나 증명력을 탄핵하는 것이다. 예컨대 상대방 제출의 문서가 위조 문서라고 주장한다거나 혹은 그 기재된 일자와 다른 날에 작성되었다거나 작성자가 객관적인 사실을 기재할 위치에 있지 않았다는 내용 등을 주장하는 경우이다. 증인의 증언에 관해서도 그것이 사실과 다르다는 것을 다른 증거자료와 대조해 가면서 설명하고, 혹은 그 증언의 내용 자체가 경험칙에 반하고 논리에 맞지 않음을 지적하여 그것을 믿을 수 없다고 주장할 필요가 있다.

2. 준비서면의 제출

가. 개 설

준비서면은 상대방에게 송달할 부분과 함께 원본을 제출하여야 한다. 상대방이 수인하는 때에는 그 수에 상응하는 수의 부분을 제출하여야 한다. 준비서면은 그 기재한 사항에 대한 상대방의 준비기간을 두고 제출하여야 하며 법원은 이를 상대방에 송달하여야 한다(민소법 제273조).

나. 인지 등

인지는 붙이지 아니한다. 다만 그 준비서면에 신청사항이 포함되어 있으면 민소인지법 제10조에 의하여 인지를 붙인다. 송달료는 소송계속중의 중간적, 부수적 신청에는 따로 납부하지 아니한다.

[사례] 준비서면(원고의 준비서면, 사망일로부터 3개월이 경과한 이후에야 한정승인신고를 하여 무효라는 주장)

준비서면

사 건 20〇〇가소〇〇〇〇 상속채무금

원 고 〇〇신용보증기금

피 고 망 김〇〇의 한정상속인 이〇희

위 당사자 간의 사건에 관하여 피고들의 소송대리인은 다음과 같이 준비서면을 제출합니다.

다 음

1. 기초사실

가. 망 소외 〇〇〇은 소외 〇〇은행 주식회사로부터 20〇〇. 12. 8. 700만 원, 20〇〇. 4. 15. 2,600만 원을 대출받았습니다. 원고는 이 대출들과 관련하여 각 신용보증서를 발급하였습니다.

나. 망 소외 〇〇〇은 위 대출금에 대한 이자를 연체함으로써 기한의 이익을 상실하였고, 원고는 보증인으로서 위 대출금에 대하여 소외 〇〇은행 주식회사에 20〇〇. 9. 17. 합계 39,174,601원을 대위변제하였습니다.

다. 망 소외 〇〇〇은 20〇〇. 9. 5. 사망하였는데, 망 소외 〇〇〇의 상속인 중 상속인 피고를 제외한 나머지 상속인들은 모두 상속을 포기하였고 위 피고는 한정승인 신고를 하여 수리되었습니다(〇〇가정법원 20〇〇느단674호).

라. 원고는 피고를 상대로 구상금 청구의 소를 제기하였는데 법원으로부터 ‘피고는 망 소외 〇〇〇로부터 상속받은 재산의 범위 내에서 원고에게 81,138,332원 및 그 중 31,544,723원에 대하여 20〇〇. 4. 25.부터 20〇〇. 3. 29.까지는 연 12%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급한다’는 취지의 판결을 받아 확정되었습니다.

2. 가정법원에서 위 한정승인신고를 수리하는 심판을 하였다 하더라도 이는 상속인이 일응 한정승인의 요건을 구비한 것으로 하여 그 신고를 수리하는 것으로서의 효력이 있을 뿐 상속인에 대한 한정승인을 확정하는 효력을 가지는 것은 아니고 한정승인의 효력이 있는지 여부는 구체적인 사건에서 실체법에 따라 해결될 문제라 할 것입니다.

그런데 한정승인신고는 민법 제1030조와 제1019조 제1항에 의하여 상속인이 상속개시 있음을 안 날로부터 3개월 내에 하여야 하고, 이와 같이 ‘상속개시 있음을 안 날’이라고 함은 상속개시의 원인이 되는 사실의 발생을 앞으로써 자기가 상속인이 되었음을 안 날을 말하는 것인바, 피고는 망 소외 ○○○의 처로서 위 망인이 사망한 20○○. 1. 9. 당시 그 사망사실을 알게 되었다 할 것이고 피고는 그로부터 3개월이 경과한 이후에야 한정승인신고를 하였음을 알 수 있습니다. 따라서 위 한정승인신고는 기간을 도과한 후에 한 것으로서 한정승인의 효력이 없다고 할 것입니다.

입증방법 및 첨부서류

- | | |
|-----------------|----|
| 1. 피상속인의 제적등본 | 1통 |
| 1. 피고의 한정승인심판등본 | 1통 |

20 . 10. .

위 원고

[사례] 준비서면(피고는 한정승인을 받고 상속재산파산신청을 하였다는 항변)

준비서면

사 건 20○○가소○○○○ 상속채무금
원 고 ○○캐피탈 주식회사
피 고 망 김철수의 상속인 강영숙 외 3명

서울중앙지방법원 귀중

※ 준비서면 표지임

준비서면

사 건 20〇〇가소〇〇〇〇 상속채무금

원 고 〇〇캐피탈 주식회사

피 고 망 김철수의 상속인 김일여 외 3명

위 당사자 간의 사건에 관하여 피고들의 소송대리인은 다음과 같이 준비서면을 제출합니다.

- 다 음 -

1. 원고의 주장은 『20〇〇. 9. 16. 원금15,000,000원에 대하여 망 김철수(이하 ‘망인’이라고 약칭합니다)에게 대출을 하였으나, 망인은 이 돈을 변제하지 못 하였으므로 망인의 상속인 피고 강영숙(배우자), 김일여(자녀), 김이여(자녀), 김삼여(자녀)은 각 상속비율로 위 원리금을 지급하라』는 취지의 주장을 하고 있습니다.
2. 그런데 망인이 20〇〇. 12. 5. 사망한 이후 피고 강영숙, 김이여, 김삼여는 서울가정법원 20〇〇느단000 상속재산포기의 신청을 하였으므로 원고의 피고 강영숙, 김이여, 김삼여에 대한 청구는 각하되어야 상당합니다[을 제1호 중 상속재산포기].
3. 한편, 피고 김일여는 서울가정법원 20〇〇느단000 상속한정승인을 득한 후 곧 바로 상속한정승인에 대한 신문 공고를 완료하였고[을 제2호 중 상속한정승인, 을 제3호 중 신문공고], 아울러 망인의 상속재산에 대하여 서울회생법원 20〇〇하단000 상속재산파산신청을 하였습니다[을 제4호 중 나의사건검색].
4. 그런데 상속한정승인의 효과는 민법 제1028조에 의하여 『상속인은 상속으로 인하여 취득할 재산의 한도에서 피상속인의 채무와 유증을 변제할 것을 조건으로 상속을 승인』 하는 것을 말하므로, 피고 김일여는 망인으로부터 취득한 재산(적극재산)의 범위 내에서 상속채권자들에게 그 상속채무를 변제할 의무

가 있는 것입니다.

5. 따라서 원고의 피고 김일여에 대한 이권 청구는 “망 김철수로부터 상속받은 재산의 한도 내”에서 판결이 선고되어야 할 것인바, 그런데 피고 김일여는 현재 서울회생법원 20○○하단000 상속재산파산신청을 제기하였으므로 원고의 피고 김일여에 대한 이권 청구는 위 상속재산 파산절차에 의하여 적절한 배당금을 수령함으로써 원고의 피고 김일여에 대한 상속채무관계는 종결되어야 할 것입니다.

입 증 방 법

- | | |
|-----------|--------|
| 1. 을 제1호증 | 상속재산포기 |
| 1. 을 제2호증 | 상속한정승인 |
| 1. 을 제3호증 | 신문공고 |
| 1. 을 제4호증 | 나의사건검색 |

20○○. 5. .

- 위 피고 1. 강영숙
2. 김일여
3. 김이여
4. 김삼여

제4절 상속재산(부동산) 가압류

1. 서 설

상속인은 아직 상속 승인, 포기 등으로 상속관계가 확정되지 않은 동안에도 잠정적으로나마 피상속인의 재산을 당면 취득하고 상속재산을 관리할 의무가 있으므로, 상속채권자는 그 기간 동안 상속인을 상대로 상속재산에 관한 가압류결정을 받아 이를 집행할 수 있다. 그 후 상속인이 상속포기로 인하여 상속인의 지위를 소급하여 상실한다고 하더라도 이미 발생한 가압류의 효력에 영향을 미치지 않는다. 따라서 위 상속채권자는 종국적으로 상속인이 된 사람 또는 민법 제1053조에 따라 선임된 상속재산관리인을 채무자로 한 상속재산에 대한 경매절차에서 가압류채권자로서 적법하게 배당을 받을 수 있다(대법원 2021. 9. 15. 선고 2021다224446 판결).

그러나 상속재산에 관하여 담보권을 취득하였다는 등 사정이 없는 이상, 한정승인자의 고유채권자는 상속채권자가 상속재산으로부터 채권의 만족을 받지 못한 상태에서 상속재산을 고유채권에 대한 책임재산으로 삼아 이에 대하여 강제집행을 할 수 없다고 보는 것이 형평의 원칙이나 한정승인제도의 취지에 부합하며, 이는 한정승인자의 고유채무가 조세채무인 경우에도 그것이 상속재산 자체에 대하여 부과된 조세나 가산금, 즉 당해세에 관한 것이 아니라면 마찬가지이다(대법원 2016. 5. 24. 선고 2015다250574 판결)

“부동산 가압류”는 금전이나 금전과 관련이 된 채권을 가진 채권자가 그 보전을 목적으로 채무자의 부동산을 동결시켜서 처분을 하지 못하도록 부동산 압류를 하는 절차를 말한다. 미등기 부동산도 보존등기가 가능한 경우에 가압류 할 수 있다.

2. 신청절차

가. 개 설

부동산가압류의 신청은 보전절차의 성질에 반하지 않는 한 소에 관한 규정이 준용된다. 보전소송절차는 명령절차와 집행절차로 구별된다. 신청은 통상 본안소송을 제기하기 전에 신청하고 있으나 본안소송의 계속 중에도 신청할 수 있다.

부동산가압류 신청은 청구채권의 내용·가압류할 부동산의 표시·신청취지·신청이유 등을 적은 부동산가압류신청서 및 가압류신청 진술서를 관할법원에 제출하여야 한다.

가압류의 신청은 동일한 당사자 간의 동일한 피보전권리의 보전을 위하여는 할 수 없다. 다만, 피보전권리가 동일하다 하더라도 보전의 필요가 있고 또 보전처분의 내용이 서로 저촉되지 않는 범위내에서 수개의 보전처분을 구할 수 있다. 가압류신청은 주관적, 객관적으로 병합하여 신청할 수 있고, 신청후 이를 변경할 수도 있다.

가압류의 신청은 시효의 중단 등 실체법상의 효과가 있다(민법 제168조 2호). 시효중단의 효력발생시기에 대하여는 견해에 대립이 있으나 보전처분의 신청을 한 때부터 발생한다고 본다.⁶³⁹⁾

상속재산이 부동산인 경우에는 상속인 앞으로 대위에 의한 상속등기를 신청(747면 참조)함과 동시에 가압류신청을 하여야 한다.

나. 신청서의 제출 및 기재사항

가압류의 신청은 서면 또는 구술로 할 수 있으나 실무에서는 서면으로 하고 있다. 신청서는 소장 또는 준비서면에 준하여 작성하고 진술서를 작성하여 첨부하여야 한다. 다음에서 보기로 한다.

(1) 사 건 명

가압류할 물건이나 권리의 종류나 처분내용에 따라 부동산가압류·채권가압류·유체동산가압류 등 사건명을 표시한다.

(2) 당사자의 표시

(가) 개 설

사망한 사람을 상대로 하는 가압류는 할 수 없다. 따라서 사망자를 상대로 한 가압류는 부적법하여 각하한다.

판례는 “이미 사망한 자를 채무자로 한 처분금지가처분신청은 부적법하고 그 신청에 따른 처분금지가처분결정이 있었다고 하여도 그 결정은 당연무효로서 그 효력이 상속인에게 미치지 않는다고 할 것이므로, 채무자의 상속인은 일반승계인으로서 무효인 그 가처분결정에 의하여 생긴 외관을 제거하기 위한 방편으로 가처분결정에 대한 이의신청으로써 그 취소를 구할 수 있다⁶⁴⁰⁾.”고 판시하였다.

그런데 채무자(피상속인 : 망인)가 사망한 사실을 모르고 가압류신청을 한 경우에는

639) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다18622 판결

640) 대법원 2002. 4. 26. 선고 2000다30578 판결

그 사망자에게 상속인이 있으면 그 상속인이 소송을 수계한다. 따라서 피상속인(망인)을 상속인으로 변경하는 당사자표시정정서(708면 참조)를 법원에 제출해야 한다.

그러나 채무자가 사망한 사실을 알고 있는 경우에도 상속인을 알 수 없기 때문에 당사자(채무자)의 이름을 기재할 수가 없는데 이 경우에는 채무자 표기를 “망 ○○○의 상속인”으로 기재하고 주소는 망인의 최후주소를 기재한다.

신청서의 내용에도 “채무자는 망인의 상속인들을 특정할 수 없는 관계로 추후 사실조회 등의 방법으로 각 상속인을 특정한 이후 당사자표시정정신청 및 청구취지변경을 신청할 예정입니다.”라고 기재하여 당사자표시를 보정하려는 뜻을 기재한다.

그 후 법원으로부터 보정명령이 나오면 채무자를 상속인으로 변경하여야 한다. 후술의 가압류신청의 보정(744면 참조)에서 다룬다.

신청서에는 당사자의 성명 또는 상호, 주소(채무자 주소 부분에서 약정상 주소나 증서상 주소는 필요없고 송달 가능한 주소와 등기(등록)부상 주소를 구분하여 정확히 기재하여야 한다. 송달장소와 등기(등록)부상 주소가 일치하면 그 주소만 기재하면 됨)를 기재하고 당사자가 무능력자인 경우에는 그 법정대리인을 기재하여야 하며 법인인 경우에는 그 대표자를 기재한다. 소송대리인이 있으면 그의 성명·주소를 기재한다.

(나) 상속포기자 한정승인자

상속포기자는 상속포기와 함께 망인의 모든 재산(적극재산 및 소극재산-채무)에 관한 권리를 포기하게 되므로, 상속포기한 상속인을 상대로 상속재산에 대한 가압류를 할 수가 없고, 또한 상속포기자는 그 상속재산에 대한 권리를 상속법상에서 주장할 수가 없다.

그러나 피상속인의 채권자는 1순위 상속인이 상속을 포기한 경우에는 차순위 상속인에게 채무 변제를 요구할 수 있고, 만약 그 역시 상속포기를 하였다면 또 그 다음 순위 상속인에게 채무변제를 요구할 수 있다.

한편 채권자가 상속인이 상속포기를 한 사실을 모르고 상속포기자를 상대로 상속채무금에 대한 가압류신청을 한 경우에는 상속포기자는 상속포기사실을 증명하여 적극적으로 항변하여야 할 것이다(713면 참조).

(3) 피보전권리의 표시

가압류신청에는 신청취지 바로 위에 그 피보전청구권을 표시하고 그 금액을 기재한다. 그 청구권이 금전채권이 아닌 경우에는 금전으로 환산한 가액을 기재한다(민집법 제279조 1항). 이와 같이 피보전채권액을 기재하도록 함은 담보액이나 해방공탁금, 가압류집행의

한도를 정하는데 필요하기 때문이다. 피보전권리는 예비적·선택적으로 기재하여도 된다.

(4) 신청취지

신청의 취지는 가압류신청에 의하여 구하고자 하는 보전처분신청의 목적과 한도를 나타내는 표준이 된다. 그러므로 어떠한 보전명령을 구하는지를 명백히 기재하여야 한다(민집법 제249조 227조).

신청취지는 소장의 청구취지에 상응하는 것으로 가압류에 의해 구하려는 보전처분의 내용을 말하며, 권리의 보전을 위해 필요한 내용을 적고, 신청취지를 구하는 근거로 신청이유인 피보전권리의 존재와 보전의 필요성을 구체적으로 적어야 한다.

(5) 신청이유(보전의 필요성)

신청의 이유는 신청취지를 구하는 근거가 되는 사유를 말한다. 따라서 피보전권리의 존재와 보전의 필요성을 구체적이고 간결하게 기재하여야 한다(민집법 제279조 1항).

예시 : 매매인 경우에는 "○년 ○월 ○일 매매에 의한 소유권이전등기청구권", 대여금채권인 경우에는 "○년 ○월 ○일 소비대차의 대여금반환청구권"등

(6) 소명방법 및 표시

신청서에는 보전처분의 이유가 되는 사실의 소명방법을 기재하여야 한다(민집법 제279조 2항). 그 소명방법이 서류일 때는 그 사본 등을 첨부하여야 한다. 소명은 「즉시 조사할 수 있는 증거」에 의하여야 하므로 변론기일에 법정에서 제출할 수 있는 것으로써 서증이나 검증물 또는 당사자 본인신문 등이 이에 해당한다. 증거조사에 오랜 시일을 요하는 소명은 적당치 아니하다. 소명은 보전의 필요성에 그치지 않고 피보전권리도 그 대상이 된다.

그러나 채권자가 청구 및 보전처분의 이유를 소명하지 아니한 경우에도 보전처분으로 인하여 채무자가 입을 수 있는 손해에 관하여 법원이 정한 담보를 제공한 때에는 보전명령을 발할 수 있다(민집법 제280조 2항), 이는 소명에 갈음하는 담보로서 채권자에 대한 소명의 부담을 덜어 주려는데 있다.

(7) 가압류할 청구채권의 표시

가압류할 채권의 종류 및 수액을 명시하여야 한다(민집법 제225조). 가압류채권의 구체적인 범위는 가압류 등 결정의 '가압류할 채권의 표시'에 기재된 문언의 해석에 따라 결정되는 것이 원칙이다. 따라서 '가압류할 채권의 표시'에 기재된 문언은 그 문언 자체의 내용에

따라 객관적으로 엄격하게 해석하여야 하고, 그 문언의 의미가 불명확한 경우 그로 인한 불이익은 압류 등 신청채권자에게 부담시키는 것이 타당하다.⁶⁴¹⁾

가압류할 채권의 내용이 특정되지 아니하였으면 압류명령이 무효가 되고 뒤에 보완하더라도 소급하여 유효로 되는 것이 아니다. 가압류채권의 수액은 총액까지를 특정할 필요 없고 ‘○○○채권중 위 청구채권액’ 정도로 표시하면 된다. 가압류채권의 표시는 [사례]에서 보듯이 신청취지 바로 위에 표시하여야 하고 내용이 길어 복잡한 때에는 별지목록을 만들어 첨부한다.

(8) 인지 및 송달료

부동산가압류 신청서에는 10,000원의 인지를 붙여야 하고, 3회분의 송달료(5,200원 × 당사자수 × 3회분)를 납부하여야 한다(재판예규 제1522호).

인지액과 송달료 납부는 법원구내 은행에 송달료예납납부서를 작성하여 납부한다. 신한은행 인터넷뱅킹으로도 납부할 수 있고, 현금지급기 등을 이용하여 납부할 수도 있다. 인터넷뱅킹으로 납부할 경우 납부서를 출력하여 법원제출용은 가압류신청서 표지 뒷면에 붙여 제출하면 된다.

(9) 등록면허세

부동산 가압류 신청시에는 등록면허세와 지방교육세를 내야 한다. 부동산가압류의 등록면허세는 가압류채권금액의 1,000분의2를(지방세법 제23조 제1항 제1호 마.), 지방교육세는 등록면허세액에 100분의 20을 곱하여 산출한 금액이다. 산출된 등록면허세가 6,000원 미만인 경우 6,000원을 납부한다(지방세법 제28조제1항제1호가목 및 라목).

등록면허세는 부동산가압류신청서를 작성하여 부동산소재지 시, 군, 구청의 세무과를 방문하여 등록에 대한 등록면허세신고서(서식, 민원실에 비치)를 작성하여 신고하고 고지서를 발급 받아 은행에 납부한 후 등록면허세영수필확인서를 가압류신청서 표지 뒷면에 풀로 떨어지지 않도록 만 살짝 붙인다.

등록면허세는 가압류신청시에 납부하거나 가압류신청 후 법원으로부터 가압류신청이 인용된 후 보증금공탁서와 함께 납부할 수도 있다.

등록면허세 등은 가압류신청이 취하나 각하, 기각 또는 가압류집행이 미집행되거나 집행불능된 경우에는 법원으로부터 등록면허세영수필확인서를 환부받아 등록면허세신고서를 발급한 시, 군, 구청에서 납부한 등록면허세를 환불을 받을 수 있다.

641) 대법원 2011. 2. 10. 선고 2008다9952 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다26296 판결

(10) 부동산가압류등기촉탁 수수료

부동산·자동차·선박·항공기의 가압류는 법원이 집행처분의 명령과 동시에 소관 행정관서에 등기·등록을 촉탁하여야 함으로 촉탁수수료를 납부하여야 한다.

가압류촉탁수수료는 가압류결정 후 그 결정을 등기부에 기록하는 경우에, 즉 등기촉탁시 촉탁서에 첨부하는 경우에 필요한 것이므로 가압류결정을 채무자에게 송달하는 방법에 의하여 집행하는 경우에는 필요로 하지 아니하다.

부동산의 경우 하나의 촉탁서로써 3개의 부동산에 관한 가압류촉탁을 하는 경우 : 3천 원(가압류촉탁수수료) $\times$ 3(부동산 개수) = 9천 원이다(등기예규 제1487호).

토지와 건물을 가압류하는 경우에는 수수료는 6,000원이나 아파트와 연립의 경우에는 3,000원이다(등기예규 제1487호 별표). 등기수입증지 폐지에 따라 대한민국법원 인터넷 등기소(<http://www.iros.go.kr/>)를 이용하여 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 선불형지급수단)으로 납부하고 출력한 영수필확인서를 첨부하거나, 법원행정처장이 지정하는 수납 금융기관 또는 무인발급기에 현금으로 납부한 후 발급받은 영수필확인서를 첨부하여야 한다(등기예규 제1487호).

(11) 진술서

진술서라 함은 법원이 가압류발령요건에 대한 심사를 용이하게 하고 남용적인 보전처분 신청을 억제하기 위하여 가압류신청시 보전의 필요성과 피보전권리 등을 묻고 예, 아니오로 답하도록 한 서면을 말한다. 법원은 이에 관하여 재판예규를 제정하여 운용하고 있다.

따라서 가압류를 신청하는 경우에 가압류신청 진술서를 첨부하지 아니하거나, 고의로 진술 사항을 누락하거나 허위로 진술한 내용이 발견된 경우에는 특별한 사정이 없는 한 보정명령 없이 신청을 기각할 수 있도록 하였다(보전처분 신청사건의 사무처리요령, 재민 2003-4).

(12) 첨부서류

권리가 특정채권인 때에는 당해 권리의 발생원인인 법률관계의 존재를 증명하는 서면(예: 매매계약서 등)을, 금전채권인 때에는 당해 금전채권증서(예: 금전소비대차계약서 등)를 첨부하여야 한다. 이때의 매매계약서 등은 공정증서가 아닌 사서증서라도 무방하다(등기예규 제1432호제3조).

이 밖에 대리인 또는 대표자의 자격을 증명하는 서면(예컨대 위임장, 가족관계증명서, 법인이나 회사일 경우에는 대표자 등·초본과 지배인등·초본 등) 및 목적물을 나타내는 사항

을 첨부서류라 표시하고 목적물의 목록은 따로 작성하여 신청서 말미에 첨부한다. 실무상 가압류사건에 있어서는 동산가압류를 제외하고는 가압류목적물을 특정하지 아니하면 안 된다.

등기등의 촉탁이 필요한 경우에는 그 수만큼 목록부분을 제출한다.

(13) 담보의 제공

(가) 개 설

가압류신청의 경우 담보를 제공하여야 한다. 가압류는 피보전권리의 존부에 관한 확정적인 판단 없이 소명으로 사실을 인정하고 채무자의 재산을 동결하는 것이기 때문에 채무자는 때에 따라서 아무런 의무 없이 손해를 입게 되는 수가 있다. 따라서 비교적 간단한 절차에 따라 채권자에게 채권보전수단을 마련해 주는 대신 나중에 그 가압류가 잘못된 것으로 밝혀질 경우 채무자가 그 손해를 쉽게 회복할 수 있도록 담보를 마련해 두는 것이다.

(나) 후담보의 경우

통상 가압류신청을 하면서 신청서 말미에 “본건 가압류의 손해담보로 제공할 공탁금은 민사집행법 제19조 제3항, 민사소송법 제122조에 의하여 지급보증위탁계약을 체결한 문서를 제출하는 방법에 의하여 담보를 제공할 것을 허가하여 주시기 바랍니다.”라고 기재한다.

가압류신청서를 법원에 제출하면 사건번호를 부여받게 되고, 채권자는 각 법원 사이트나 의사건검색을 통하여 사건번호를 입력하면, 사건의 진행상황을 알 수 있다.

위 기재에 의하여 법원은 통상 가압류 명령에 앞서 보통 3일에서 5일 사이의 일정한 기간을 정하여 담보제공명령을 발하는데 담보제공명령을 받은 채권자가 그 결정에 정하여진 기일(보통 7일) 내에 담보를 제공하지 않으면 법원은 신청을 각하하게 되며 담보제공이 되면 가압류 명령을 발한다(민집법 제280조제3항 및 민사소송법 제219조).

(다) 선담보제공

원칙적으로 가압류를 신청하면 법원에서 청구채권금액을 기준으로 담보제공명령을 하면 그때 보증보험가입 및 증권을 발부받아 제출하거나 현금공탁을 하지만 가압류의 긴급성을 위하여 부동산·자동차·건설기계·소형선박 또는 금전채권에 대한 가압류의 경우 예외적으로 선담보제공을 허가하고 있다.

가압류에서 선담보 허용은 부동산·자동차·건설기계·소형선박 또는 금전채권에 대한 가압류 신청시 허용하고 급여채권·영업자예금채권 가압류의 경우는 선담보를 허용하지

아니한다.

가압류 신청 시 법원으로부터 선담보제공 허가를 받으려는 자는 가압류 신청서 접수 전에 법원인근의 보증보험회사의 공탁보증보험에 가입하여야 하여야 하는데 부동산에 대한 가압류신청의 경우는 청구금액의 1/10을 보증금액으로 하는 보증서원본을 제출하는 방법(공탁보증보험 가입)으로 담보제공의 허가신청을 할 수 있다(재판예규 제1231호).

선담보제공은 가압류신청서 말미에 다음과 같은 의사표시를 기재하여 법원의 허가를 받아야 한다.

“이건 가압류신청에 대한 담보의 제공을 공탁보증보험증권(○○보증보험주식회사 증권 번호 제000호)을 제출하는 방법으로 할 수 있도록 허가하여 주시기 바랍니다.”라고 기재한다.

(라) 보전처분신청시 담보액 산정기준표

구 분	부동산 가압류, 가처분 (자동차·건설기계포함)	부동산 점유이전금지	채 권	유체동산
담보 제공액	청구금액×1/10(10%)	목적물가액× 1/20(5%)	청구금액×2/5(40%)	청 구 금 액 ×4/5(80%)
담보 제 공 방법	현금공탁 또는 보증보 험증권 현금공탁비율10%	현금공탁 또는 보 증보험증권 현금공탁비율 5%	현금공탁 또는 보증보험 증권. 현금공탁비율50%	현금공탁 또는 보증보험증권. 현 금 공 탁 비 율 80%
채권자 구분	공공기관, 금융기관, 개인구분을 없앴. 다 만 대한민국은 현행과 같이 무공탁	공공기관, 금융기 관, 개인구분을 없앴.	공공기관, 금융기관, 개 인구분을 없앴.	공공기관, 금융 기관, 개인구분 을 없앴.
선담보	가압류의 경우 가능	가능	가능(임금·영업자에금제 외)	불가능

주) 위 담보액 산정기준은 서울중앙지방법원에서 기준을 정하여 사용하고 있는 것이고, 각 지방법원마다 다르므로 참고로 하여야 함. 부동산·자동차·건설기계에 대한 가압류의 담보산출액은 원금만을 기준으로 하고 이차·지연손해금 등은 포함하지 않는다.

(14) 관할법원

부동산가압류 사건은 원칙적으로 가압류할 부동산의 소재지를 관할하는 법원이나 본안

의 관할법원이 관할한다(민집법 제278조 및 제21조).

다. 부동산 가압류의 집행

가압류집행을 함에 있어서는 집행문의 부여가 필요없고(단, 승계가 있는 경우에는 예외) 가압류명령정본을 채무자에게 송달하기 전에도 집행할 수 있다. 그러나 가압류의 집행력은 선고 또는 채권자가 송달을 받은 날로부터 2주일이 경과한 때에는 소멸된다(민집법 제292조 2항).

가압류의 집행은 그 집행을 보전하기 위한 조치이므로 목적물을 환가하여 만족을 얻을 수는 없다. 환가는 본안의 확정판결에 의하여 본집행으로의 전이에 의하여 이루어진다.

부동산에 대한 가압류의 집행은 가압류 재판에 관한 사항을 등기부에 기입함으로서 한다(민집법 제293조제1항). 법원은 가압류 결정을 한 후 채권자에게 결정 정본을 송달하면서 부동산 소재지 관할 등기소에 가압류 사실을 기입하라는 등기촉탁서를 함께 송달함으로써 등기소공무원에 의하여 등기부에 기입하게 된다(민집법 제293조제2항 및 제3항).

[사례] 부동산가압류신청서(물품대금청구)

부동산가압류신청서	
수입인지 10,000원	
채권자	삼일연마공업주식회사
채무자	망 김철수(000000-0000000)의 상속인
청구금액 : 금13,476,792원	
첨부인지액	금10,000 원
송 달 료	금31,200 원
서울중앙지방법원 귀중	

※ 표지를 위와 같이 만든다.

부동산가압류신청서

채권자 삼일연마공업주식회사
서울 강남구 삼성로123길 4
대표이사 이 창 수
전화번호(휴대폰 포함), 팩스번호, 전자우편(e-mail)주소

채무자 망 김철수(000000-0000000)의 상속인
망인의 최후 주소 ○○시 ○○구 ○○로○길○○-○

청구채권의 표시 및 피보전권리
금 13,476,792원
20○○. 1. 10.자 물품공급계약에 기한 물품대금

가압류할 부동산의 표시
별지 목록 기재와 같음

신 청 취 지

채권자가 채무자에 대하여 가지는 위 청구채권의 집행보전을 위하여 채무자 소유의 별지목록 기재부동산을 가압류한다.
라는 재판을 구합니다.

신 청 원 인

1. 당사자 관계

채권자는 연마자재판매업을 하는 회사이고 채무자 망 김철수(이하 ‘망인’이라고 약칭합니다)는 생전에 정밀주조업을 하는 회사를 운영하였고 채권자는 망인의 회사에 연마자재를 매월 정기적으로 납품하여 왔고, 망인은 채권자로부터 다음 표시의 기재와 같이 연마자재를 매수하고 동일자 인수하는 방법으로 물품거래가 발생하였습니다.

이후 망인은 20○○. 12. 5. 사망하게 되었고, 채무자(들)는 망인의 상속인(들)

입니다.

다 음

- (1) 20○○. 1. 28. 공급가액 금2,510,720원 부가가치세 251,072원
합계금 2,761,792원정
 - (2) 20○○. 2. 1. 공급가액 금2,150,000원 부가가치세 215,000원
합계금 2,365,000원정
 - (3) 20○○. 2. 1. 공급가액 금2,890,000원 부가가치세 289,000원
합계금 3,179,000원정
 - (4) 20○○. 4. 4. 공급가액 금3,110,000원 부가가치세 311,000원
합계금 3,421,000원정
 - (5) 20○○. 5. 4. 공급가액 금2,500,000원 부가가치세 250,000원
합계금 2,750,000원정
2. 채권자는 위 총계금 14,476,792원의 판매대금이 있어 망인의 생전에 그 변제를 촉구한 바 망인은 차일피일 미루어 오다가 20○○. 2. 1. 금1,000,000원만 변제하고 나머지 금13,476,792원을 지급하지 아니하였습니다. 그런데 망인은 20○○. 12. 5.자에 사망하게 되었고, 망인의 상속인들은 위 채무를 상속받게 되었습니다.
- 한편, 채권자는 망인의 상속인들을 특정할 수 없는 관계로 추후 사실조회 등의 방법으로 각 상속인을 특정한 이후 당사자표시정정을 신청할 예정입니다.
3. 따라서 채무자(들)를 상대로 물품대금 반환청구의 소를 준비 중에 있는바, 망인의 상속인인 채무자(들)는 망인의 상속채무를 변제할 의무가 있다고 할 것이므로 위 청구채권의 집행보전을 위하여 본 신청에 이르렀습니다.
4. 한편 피상속인(망인)에게는 이 사건 부동산만이 유일한 재산이었는데, 위 부동산에 대하여는 이미 채권최고액 합계 ○○○원의 근저당권(2건)이 설정되어 있는데 그 상속인이 추가로 근저당권을 설정하게 된다면, 채권자로서는 후일 본안소송에서 승소하더라도 그 때에는 이미 집행이 사실상 불가능해 질 가능성이 농후합니다.

5. 본건 가압류의 손해담보로 제공할 공탁금은 민사집행법 제19조 제3항, 민사소송법 제122조에 의하여 지급보증위탁계약을 체결한 문서를 제출하는 방법에 의하여 담보를 제공할 것을 허가하여 주시기 바랍니다.

입 증 방 법

1. 거래명세표
1. 기타는 변론시 수시제출하겠음

첨 부 서 류

1. 부동산등기부등본 1통
1. 세금계산서 1통

20〇〇. 9. 15.

채권자 삼일연마공업주식회사
대표이사 이 창 규 (인)

서울중앙지방법원 귀중

3. 가압류신청서의 정정과 보정

가. 개 설

채무자를 “망 김철수의 상속인”으로 기재하여 신청한 가압류는 법원이 보정명령을 내리게 되는데 법원으로부터 보정명령이 나오면 채무자(피상속인)를 그 상속인으로 정정하여야 한다.

그 방법은 보정명령서를 가지고 가까운 주민자치센터에 가서 사망한 채무자의 제적등본과 가족관계증명서를 발급받고, 채무자의 상속인(상속인이 여럿인 경우에는 각 주민등록초본을 발급받는다)의 주민등록초본을 발급 받아 당사자표시정정서(745면 참조)와 함께 법원에 제출한다.

나. 채무자표시 정정

“채무자표시정정”이란 채권자가 가압류신청서에 채무자의 성명을 착오로 잘못 표시한 경우에 이를 바로 잡는 절차를 말한다.

판례는 “원고가 피고의 사망 사실을 모르고 사망자를 피고로 표시하여 소를 제기한 경우에, 청구의 내용과 원인사실, 당해 소송을 통하여 분쟁을 실질적으로 해결하려는 원고의 소제기 목적 내지는 사망 사실을 안 이후 원고의 피고표시정정신청 등 여러 사정을 종합하여 볼 때에, 실질적인 피고는 당사자능력이 없어 소송당사자가 될 수 없는 사망자가 아니라 처음부터 사망자의 상속자이고 다만 그 표시에 잘못이 있는 것에 지나지 않는다고 인정되면 사망자의 상속인으로 피고의 표시를 정정할 수 있다 할 것인바, 상속개시 이후 상속의 포기를 통한 상속채무의 순차적 승계 및 그에 따른 상속채무자 확정의 곤란성 등 상속제도의 특성에 비추어 위의 법리는 채권자가 채무자의 사망 이후 그 1순위 상속인의 상속포기 사실을 알지 못하고 1순위 상속인을 상대로 소를 제기한 경우에도 채권자가 의도한 실질적 피고의 동일성에 관한 위 전제요건이 충족되는 한 마찬가지로 적용이 된다.”⁶⁴²⁾고 판시하였다.

642) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다49964 판결 [상속채무금]

[사례] 당사자표시정정 신청서

당사자표시정정 신청서

사 건 20○○카합○○○○ 상속채무금
채권자 ○○캐피탈 주식회사
채무자 망 김철수의 상속인

서울중앙지방법원 귀중

당사자표시정정 신청서

사 건 20○○카합○○○○ 상속채무금

채권자 ○○캐피탈 주식회사

채무자 망 김철수의 상속인

위 사건과 관련하여, 망 김철수의 상속인들을 확인하였으므로 아래와 같이 채무자의 상속인들을 특정하여 당사자표시정정신청을 하는 바입니다.

= 아 래 =

변경 후 당사자의 표시

채무자 1. 강영숙 (000000-000000)

○○시 ○○구 ○○로○길○○-○

2. 김일여 (000000-000000)

○○시 ○○구 ○○로○길○○-○

3. 김이여 (000000-000000)

○○시 ○○구 ○○로○길○○-○

4. 김삼여 (000000-000000)

○○시 ○○구 ○○로○길○○-○

20○○. 5. .

위 채권자 ○○캐피탈 주식회사

대표이사 ○○○

서울중앙지방법원 귀중

제5절 상속등기(등기소에서의 절차)

1. 가압류채권자의 대위에 의한 상속등기

가. 서 설

상속등기를 하지 아니한 부동산에 대하여 가압류결정이 있을 때 가압류채권자는 그 기입등기촉탁 이전에 먼저 대위에 의하여 상속등기를 함으로써 등기의무자의 표시가 등기 기록과 부합하도록 하여야 한다(등기예규 제1432호제5조).

따라서 채권자가 피상속인명의의 상속재산에 대하여 가압류하는 경우 상속인 앞으로 대위에 의한 상속등기를 동시에 신청하여야 하나, 동시에 신청하지 않더라도 등기관은 이를 수리하여야 한다(등기예규 제1432호제4조).

채권자대위에 의한 등기신청이 있는 경우에 등기를 함에는 사항란에 채권자의 성명 또는 명칭, 주소 또는 사무소 소재지와 대위원인을 기재하여야 한다(부동산등기법 제28조 제2항).

나. 신청절차

(1) 대위원인

대위원인을 “200○년 ○월 ○일 ○○지방법원의 가압류 결정”이라고 기재하고, 대위원인 증서로 가압류결정의 정본 또는 그 등본을 첨부한다(등기예규 제1432호).

채권자가 민법 제404조의 규정에 의하여 채무자에 대위하여 상속으로 인한 소유권이전 등기를 신청할 때에는 공동상속인중 일부인 채무자겸 상속인의 상속지분만에 대하여 상속으로 인한 소유권이전등기를 신청할 수는 없고 공동상속인 전원에 대하여 상속으로 인한 소유권이전등기를 신청하여야 한다(등기선례 제4-274호, 1994. 11. 5. 등기 3402-1295 질 의회답).

상속인이 한정승인 또는 포기를 할 수 있는 기간내라도 채권자는 상속인을 대위하여 상속등기를 할 수 있다(등기예규 제54호, 대법원 1964. 4. 3. 선고 63마54 판결)

(2) 기록의 첨부

(가) 등기원인이 상속인 때에는 신청서에 상속의 원인을 증명하는 시·구·읍·면의 장의 서

면 또는 이를 증명함에 족한 서면을 첨부하여야 하는바, 이 서면은 개인의 신분에 관한 기본 공부인 호적등·초본과 제적등·초본을 말하고 주민등록표는 이에 해당하는 서면이라고 볼 수 없다. 그러므로 비록 주민등록표에 사망으로 등기부에 기재되어 있다 하더라도 호적등본에 사망으로 등재되어 있지 않으면 그 주민등록표를 상속을 증명하는 서면으로 하여 상속등기를 할 수 없다. 따라서 피상속인의 채권자가 그 채권의 집행을 보전하기 위해 피상속인 명의로 되어 있는 부동산에 대하여 그 상속인을 채무자로 한 가압류명령을 받은 경우, 비록 주민등록표에는 피상속인이 사망으로 등기부에 기재되어 있다 하더라도 호적부에 사망신고가 되어 있지 않으면 그러한 주민등록표는 상속을 증명하는 서면으로 볼 수 없으므로, 그 가압류채권자가 위와 같은 주민등록표등본과 호적등본 등에 의해 상속인인 채무자를 대위하여 그 가압류등기를 위한 상속등기를 신청할 수는 없다(등기선례5-213, 1998.

8. 24. 등기 3402-806 질의회답).

(나) 채권자가 상속포기 사실을 알지 못하여 상속으로 인한 소유권이전의 대위등기를 한 후 재차 같은 채권자가 상속등기의 말소등기를 대위신청할 수 있는지 여부(적극) 등

근저당설정자인 갑이 사망한 후 제1순위 상속인 A, B, C, D, E 전원이 상속을 포기하였으나 당해 부동산의 근저당권자인 을이 그 사실을 알지 못하고 공동상속인 A, B, C, D, E 명의의 상속등기를 대위신청하여 공동상속등기가 경료된 후 제1순위 상속인 전원의 상속포기 사실을 안 경우, 을은 단독으로 제1순위 상속인을 대위하여 제1순위 상속인 전원의 상속포기를 증명하는 서면(상속포기신고수리 심판서 등본 등)과 대위원인 증서로 당해 부동산의 등기부를 원용하여 착오를 등기원인으로 하여 위 상속등기를 말소함과 동시에 상속을 증명하는 서면을 첨부하여 재차 차순위 상속인 명의의 상속등기를 대위신청할 수 있다. (등기선례 제7-132호, 2002. 11. 29. 등기 3402-676 질의회답)

(다) 피상속인의 주소를 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 하는지 여부 등

상속인의 채권자가 채무자(상속인)의 부동산에 대한 압류(경매개시결정)등기를 하기 위하여 대위에 의한 상속등기를 신청하는 경우, 상속인 중 일부가 제적부상 주민등록번호가 기재되어 있지 않고 달리 주소를 확인할 수 없어 주민등록등·초본을 제출할 수 없는 경우에는 이러한 사유를 소명하여 제적부상의 본적지(또는 가족관계등록부상 등록기준지)를 주소지로 하여 상속등기를 대위신청할 수 있다. (등기선례 제201307-3호, 2013. 7. 10. 부동산등기과-1620 질의회답)

(3) 취득세 납부

대위등기 신청 시 등기신청인은 상속인의 취득세까지 대신 납부하고, 납부확인서를 첨부

부하여야 한다(등기선례 제201105-2호, 2011. 5. 3. 부동산등기과-872 질의회답).

판례는 “채무자가 다른 상속인과 공동으로 부동산을 상속받은 경우에는 채무자의 상속 지분에 관하여서만 상속등기를 하는 것이 허용되지 아니하고 공동상속인 전원에 대하여 상속으로 인한 소유권이전등기를 신청하여야 한다(부동산등기규칙 제52조 제7호, 대위상속등기에 관한 1994. 11. 5.자 등기선례 제4-274호). 그리고 채권자가 자신의 채권을 보전하기 위하여 채무자가 다른 상속인과 공동으로 상속받은 부동산에 관하여 위와 같이 공동상속등기를 대위신청하여 그 등기가 행하여지는 것과 같이 채권자에 의한 채무자 권리의 대위행사의 직접적인 내용이 제3자의 법적 지위를 보전·유지하는 것이 되는 경우에는, 채권자는 자신의 채무자가 아닌 제3자에 대하여도 다른 특별한 사정이 없는 한 사무관리(643)에 기하여 그 등기에 소요된 비용의 상환을 청구할 수 있다고 할 것이다(대법원 2013. 8. 22. 선고 2013다30882 판결 [등기비용등]).”라고 판시하였다.

(4) 수수료 등

수수료 및 주택채권 등에 관하여는 신청서 말미에서 다루기로 한다.

643) 사무관리가 성립하기 위하여는 우선 그 사무가 타인의 사무이고 타인을 위하여 사무를 처리하는 의사, 즉 관리의 사실상의 이익을 타인에게 귀속시키려는 의사가 있어야 하며, 나아가 그 사무의 처리가 본인에게 불리하거나 본인의 의사에 반한다는 것이 명백하지 아니할 것을 요한다. 여기에서 ‘타인을 위하여 사무를 처리하는 의사’는 관리자 자신의 이익을 위한 의사와 병존할 수 있고, 반드시 외부적으로 표시될 필요가 없으며, 사무를 관리할 당시에 확정되어 있을 필요가 없다(대법원 2013. 8. 22. 선고 2013다30882 판결).

[사례] 소유권이전등기신청(가압류채권자의 대위에 의한 상속등기)

토지소유권이전대위등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
서울특별시 서초구 서초동 100 대 350㎡ 이 상				
등기원인과 그 연월일		200 년 0 월 0 일 상속		
등 기 의 목 적		소유권이전		
대 위 원 인		200 년 0 월 0 일 서울중앙지방법원의 가압류 결정		
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등 기 의 무 자	망) 김 철 수	000000-00000000	최종주소:서울 서초구 서초로 100길 20	
등 기 권 리 자	별지1기재와 같음 대위신청인 김 수 길	000000-00000000	서울 서초구 서초로25길 30	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토지	별지2 기재와 같은	금 00,000원
2.	금 원	금 원
3.	금 원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		
취득세(등록면허세) 금 000,000원		지방교육세 금 000,000원
		농어촌특별세 금 000,000원
세 액 합 계		금 000,000,000원
등 기 신 청 수 수 료		금 000,000원
		납부번호 :
		일괄납부 : 건 원
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	Q77C-L07I-35J5	40-4636
첨 부 서 면		
1. 가압류결정 정보 또는 등본 1통	1. 가족관계증명서 1통	
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통	1. 주민등록표등(초)본 1통	
1. 토지대장등본 1통	1. 위임장 1통	
1. 제적등본 1통	<기 타>	
200 년 월 일		
위 신청인 대위신청인 김수길 (인) (전 화:)		
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수 (인) (전 화:)		
서울 서초구 서초로52길 30		
○○지방법원 등기과(소) 귀중		

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
 2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 사례는 채권자가 피상속인명의의 상속재산에 대하여 가압류하면서 상속인 앞으로 대위에 의한 상속등기를 신청하는 사례이다.

- "인터넷등기전자신청(<http://www.iros.go.kr>)"시 신청정보와 첨부정보를 등기소에 제공하여야 한다.

※ 신청정보의 제공

- 신청정보의 입력 : 신청정보는 "인터넷등기전자신청" 시스템이 안내하는 순서에 따라 입력하여야 한다. 신청서에는 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 목적물을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재한다. 토지는 종전 지번방식의 주소를 그대로 쓴다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 등 : “○년 ○월 ○일 상속”이라 기재한다. 연월일은 피상속인의 사망일자를 기재하여야 한다.
- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.
 - (예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’
 - ㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’
 - ㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’
 - ㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’
- 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.
 - (예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재
- 대위원인 : “○년 ○월 ○일 ○○지방법원의 가압류 결정”이라 기재한다(등기선례5-671, 등기예규 제1432호).

- 등기의무자란 : 피상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재하고, 법인아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재한다.
- 등기권리자란 : 상속인과 대위신청인을 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.
- 신청인란 : 소유자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 소유자가 수인인 경우에는 공유자별로 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하고, 각자의 지분을 표시한다.
- 대장상의 소유자 주소가 주소를 증명하는 서면과 부합하지 아니한 경우에 그 첨부한 주소를 증명하는 서면에 의하여 대장상의 소유자 주소가 변경되었음을 증명할 수 있을 때에는, 신청서에는 주소를 증명하는 서면과 일치되게 소유자 주소를 기재한다(선례 5-236).

※ 첨부정보의 제공

- 전자신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소(<http://www.iros.go.kr/>)에 접속한 후 "인터넷등기전자신청"을 선택하여 모든 문서를 전자문서로 작성하여야 한다. 다만, 신청인이 자격자대리인인 경우 등기소에 제공하는 서면에 대하여는 이를 전자적 이미지 정보로 변환(스캐닝)하여 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인공인인증서(이하 "공인인증서"라 한다)정보를 덧붙여 등기소에 송신하는 것으로 이를 갈음할 수 있다.
- 신청서에는 부동산등기규칙 제46조의 첨부정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 첨부정보로 등기소에 제공하여야 한다.
- 상속인의 채권자가 채무자(상속인)의 부동산에 대한 압류(경매개시결정)등기를 하기 위하여 대위에 의한 상속등기를 신청하는 경우, 상속인 중 일부가 제적부상 주민등록번호가 기재되어 있지 않고 달리 주소를 확인할 수 없어 주민등록등·초본을 제출할 수 없는 경우에는 이러한 사유를 소명하여 제적부상의 본적지(또는 가족관계등록부상 등록기준지)를 주소지로 하여 상속등기를 대위신청할 수 있다(등기선례 제201307-3호, 2013. 7. 10.).
- 단독신청에 의한 등기, 예를 들어 부동산표시변경등기나 등기명의인표시변경등기 또는 판결에 의한 등기를 신청할 때에는 등기필정보를 등기소에 제공할 필요가 없다. 다만 단독신청에 의한 등기라도 승소한 등기의무자가 단독으로 권리에 관한 등기를 신청하는 경우에는 자신의 등기필정보를 제공하여야 한다.
- 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략 할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정

보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환하여 자신의 공인인 증서를 이용하여 전자서명을 하여야 전자적 첨부이 가능하다.
- 대위원인을 증명하는 서면의 첨부 : 가압류결정의 정본 또는 그 등본을 첨부한다
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제46조 제1항 제4호).

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입 즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세·농어촌특별세란

- 취득세(등록세) : 취득세를 납부하여야 한다.
- 등록면허세 : 상속으로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의8, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.
- 국가가 대위신청에 의하여 소유권이전등기의 말소 및 소유권이전등기를 신청하는 경우 본래의 신청인이 신청하는 경우와 다를 바 없다 할 것이므로 일반원칙에 따라 소정의 등록면허세를 납부하고 국민주택채권을 매입하여야 한다(등기선례 200712-2, 2007. 12. 17. 부동산등기과-3968 질의회답. 등기선례 7-133, 2004. 8. 10. 부등 3402-394 질의회답).

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자신청의 경우 부동산 1개당 10,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우 (승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이제, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[별지 1] 상속인의 표시

상속인의 표시	
강 영 숙 9분의3 (배우자) 000000-00000000 서울 서초구 서초로120길 10	
김 일 여 9분의2 (자 녀) 000000-00000000 서울 서초구 서초로100길 20	
김 이 여 9분의2 (자 녀) 000000-00000000 서울 서초구 서초로100길 20	
김 삼 여 9분의2 (자 녀) 000000-00000000 서울 서초구 서초로100길 20	

[별지 2] 상속인별 시가표준액 및 국민주택채권매입금액

상속인별 시가표준액 및 국민주택채권매입금액			
강 영 숙	9분의3 (배우자)	금000원	금000원
김 일 여	9분의2 (자 녀)	금000원	금000원
김 이 여	9분의2 (자 녀)	금000원	금000원
김 삼 여	9분의2 (자 녀)	금000원	금000원

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	서울특별시 서초구 서초동 100 대 350㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	200 년 0 월 0 일 상속
등 기 의 목 적	소유권이전
대 위 원 인	200 년 0 월 0 일 서울중앙지방법원의 가압류 결정
위 임 인	대 리 인
신청인 대위신청인 김 수 길 (인) 서울 서초구 서초로25길 30	법무사 김 민 수 서울 서초구 서초로52길 30 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위 임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 200 년 0 월 0 일

2. 근저당권설정자가 사망한 경우 대위에 의한 상속등기

가. 개 설

근저당권설정권자가 사망하였으나 근저당권의 목적인 부동산에 관하여 그 상속인 앞으로의 상속등기가 경료되지 아니한 경우 그 부동산에 대한 임의경매신청을 하기 위하여는 상속등기가 선행되어야 한다.

근저당자인 채권자가 사망한 채무자 명의의 부동산에 대하여 상속등기를 대위로 신청하여 공동상속인 전원의 명의로 그 등기를 마쳤으나, 이후 공동상속인 중 일부가 상속을 포기한 사실을 알게 되었다면 이 상속등기를 신청한 채권자는 이러한 사실을 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여 그 상속등기에 대한 경정등기 또한 단독으로 대위신청할 수 있다(부동산등기선례 제201907-10호, 2019. 7. 30. 부동산등기과-1993 질의회답).

대위에 의한 소유권이전의 등기신청은 전자신청, 전자표준신청 및 방문신청에 의하여 할 수 있으며, 등기소에 신청정보와 등기원인을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제43조, 제46조).

나. 신청절차

(1) 경매개시신청을 하기 위한 절차

갑 소유의 부동산에 대하여 을을 근저당권자, 갑을 채무자로 하는 근저당권설정등기를 한 후 경매신청을 하기 전에 갑이 사망하였으나 그 상속인 앞으로의 상속등기가 경료되지 아니한 상태에서, 을이 그 부동산에 대한 임의경매신청을 하여 경매개시결정기입등기를 하기 위하여는,

- 1) 을은 경매신청서에 갑의 상속인을 채무자겸 소유자로 표시하고 상속을 증명하는 서류를 첨부하여 경매신청을 먼저 하거나, 갑의 상속인을 대위하여 상속등기를 먼저 한 후에 그 상속인을 소유자로 표시하여 경매신청을 할 수 있을 것이다.
- 2) 경매법원이 갑의 상속인 앞으로 상속등기가 경료되기 전에 갑의 상속인을 소유자겸 채무자로 표시하여 경매개시결정을 한 경우, 경매법원이 경매개시결정의 기입등기촉탁과 함께 갑의 상속인 앞으로의 상속등기를 촉탁할 수 있다는 민사소송법상의 규정이나 등기관이 직권으로 그 상속등기를 한 후에 경매개시결정 기입등기를 하여야 한다는 부동산등기법상의 근거규정은 없으므로, 경매법원이 상속으로 인한 소유권이전등기를 촉탁하거나, 경매기입등기의 촉탁시 등기관이 직권으로 상속으로 인한 소유권이전등기를 경료할 수는 없다. 따라서, 이러한 경우에는 을이 갑의 상속인을 대위하여 상속등기를 먼저 한 후에 경매기입등

기의 촉탁을 하여야 할 것이다.

- 3) 을이 갑의 상속인 앞으로 대위 상속등기를 하는 경우, 그 대위원인은 '○년 ○월 ○일 설정된 근저당권 실행을 위한 경매에 필요함'이라 기재하고, 대위원인을 증명하는 서면으로는 경매신청을 대위 상속등기보다 먼저 한 경우에는 그 경매개시결정정보 또는 경매신청의 수리증명서를, 대위 상속등기를 경매신청보다 먼저 신청하는 경우에는 당해 부동산의 등기부등본(다만, 등기신청서 첨부서류란에 「대위원인을 증명하는 서면은 ○년 ○월 ○일 접수번호 제○○호로 본 부동산에 근저당권설정등기가 경료되었기에 생략」이라 기재하고 첨부하지 않아도 될 것임)을 첨부하면 족할 것이다.
- 4) 이 경우, 근저당권에 기한 경매신청을 하기 위한 전제로 채무자를 상속을 원인으로 채무자의 상속인으로 변경하기 위한 근저당권변경등기는 할 필요가 없을 것이다(등기선례5-671, 1998. 12. 11. 등기 3402-1232 질의회답)

(2) 대위원인

"○년 ○월 ○일 설정된 근저당권의 실행을 위한 경매에 필요함"이라고 기재한다(등기예규 제1432호제5조나목).

(3) 상속포기 사실을 알지 못한 경우

근저당설정자인 갑이 사망한 후 제1순위 상속인 A, B, C, D, E 전원이 상속을 포기하였으나 당해 부동산의 근저당권자인 을이 그 사실을 알지 못하고 공동상속인 A, B, C, D, E 명의의 상속등기를 대위신청하여 공동상속등기가 경료된 후 제1순위 상속인 전원의 상속포기사실을 안 경우, 을은 단독으로 제1순위 상속인을 대위하여 제1순위 상속인 전원의 상속포기를 증명하는 서면(상속포기신고수리 심판서 등본 등)과 대위원인 증서로 당해 부동산의 등기부를 원용하여 착오를 등기원인으로 하여 위 상속등기를 말소함과 동시에 상속을 증명하는 서면을 첨부하여 재차 차순위 상속인 명의의 상속등기를 대위신청할 수 있다(등기선례 제7-132호, 2002. 11. 29. 등기 3402-676 질의회답).

(4) 첨부정보의 제공

(가) 대위원인을 증명하는 서면

대위원인을 증명하는 서면을 첨부하여야 하는바, 당해 부동산의 등기사항증명서를 첨부한다. 다만, 등기신청서 첨부서류란에 "대위원인을 증명하는 서면은 ○년 ○월 ○일 접수번호 제○○호로 본 부동산에 근저당권설정등기가 경료되었기에 생략"이라고 기재하고 첨부하지 않아도 된다(등기예규 제1432호제5조나목).

(나) 상속인의 상속을 증명하는 서면

등기원인이 상속인 경우에는 신청서에 상속을 증명하는 시·구·읍·면의 장의 서면 또는 이를 증명할 수 있는 서면을 첨부하여야 하는바, 시·구·읍·면의 장의 서면으로 “피상속인의 사망한 사실 및 상속권자와 상속인을 확인할 수 있는 제적등초본, 가족관계증명서, 기본증명서, 친양자입양관계증명서 등(발행일로부터 3월 이내)”을 첨부한다. 피상속인의 등기부상 표시가 가족등록부상의 표시와 상이한 경우(주소가 다른 경우)와 같이 가족관계증명서와 제적등본만으로 등기부상의 등기명의인과 피상속인이 동일인임이 인정된다고 볼 수 없는 경우에는 그 확인을 위하여 피상속인의 주소를 증명하는 서면을 첨부하거나, 서로 동일인임을 인정할 수 있는 시·구·읍·면의 장의 서면 또는 이를 증명함에 족한 서면을 첨부하여야 한다(등기선례 7-182).

(다) 주소를 증명하는 서면

상속으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 신청인의 주소를 증명하는 서면으로 주민등록등(초)본을 제출하여야 한다. 상속포기자는 주소를 증명하는 서면인 주민등록표등초본을 제출할 필요는 없다(등기선례 2-90, 87. 3. 6 등기 제121호).

(라) 취득세 납부

748면 참조

(마) 수수료 등

수수료 및 주택채권 등에 관하여는 신청서 말미에서 다루기로 한다.

[사례] 소유권이전등기신청(근저당권자의 대위에 의한 상속등기)

토지소유권이전대위등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
서울특별시 서초구 서초동 100 대 350㎡ 이 상				
등기원인과 그 연월일		200 년 0 월 0 일 상속		
등 기 의 목 적		소유권이전		
대 위 원 인		200 년 0 월 0 일 설정된 근저당권 실행을 위한 경매에 필요함		
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등 기 의 무 자	망) 김동구	000000-00000000	최종주소:서울 서초구 서초로 100길 20	
등 기 권 리 자	별지1기재와 같음 대위신청인 김 수 길	000000-00000000	서울 서초구 서초로25길 30	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토지	별지2 기재와 같은	금 00,000원
2.	금 원	금 원
3.	금 원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		
취득세(등록면허세) 금 000,000원		지방교육세 금 000,000원
		농어촌특별세 금 000,000원
세 액 합 계		금 000,000,000원
등 기 신 청 수 수 료		금 000,000원
		납부번호 :
		일괄납부 : 건 원
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	Q77C-L07I-35J5	40-4636
첨 부 서 면		
1. 근저당권설정계약서 1통	1. 가족관계증명서 1통	
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통	1. 주민등록표등(초)본 1통	
1. 토지대장등본 1통	1. 위임장 1통	
1. 제적등본 1통	<기 타>	
200 년 월 일		
위 신청인 대위신청인 김수길 (인) (전 화:)		
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수 (인) (전 화:)		
서울 서초구 서초로52길 30		
○○지방법원 등기과(소) 귀중		

- 신청서 작성요령 -

- ★ 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
 2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 사례는 근저당권설정권자가 사망하였으나 근저당권의 목적인 부동산에 관하여 그 상속

인 앞으로의 상속등기가 경료되지 아니한 경우 그 부동산에 대한 임의경매신청을 하기 위하여 상속인 앞으로 상속등기를 신청하는 경우이다.

- "인터넷등기전자신청([http : // www. iros. go. kr](http://www.iros.go.kr))"시 신청정보와 첨부정보를 등기소에 제공하여야 한다.

※ 신청정보의 제공

- 신청정보의 입력 : 신청정보는 "인터넷등기전자신청" 시스템이 안내하는 순서에 따라 입력하여야 한다. 신청서에는 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 목적물을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재한다. 토지는 종전 지번방식의 주소를 그대로 쓴다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 등 : “○년 ○월 ○일 상속”이라 기재한다. 연월일은 피상속인의 사망일자를 기재하여야 한다. 상속으로 인한 등기의 원인은 민법의 개정에 따라 기재하여야 한다.
- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

- 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의

○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

- 대위원인 : “○년 ○월 ○일 설정된 근저당권 실행을 위한 경매에 필요함”이라 기재한다(등기 선례5-671).
- 등기의무자란 : 피상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재하고, 법인아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재한다.
- 등기권리자란 : 권리자와 대위신청인을 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.
- 신청인란 : 소유자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 소유자가 수인인 경우에는 공유자별로 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하고, 각자의 지분을 표시한다.
- 대장상의 소유자 주소가 주소를 증명하는 서면과 부합하지 아니한 경우에 그 첨부한 주소를 증명하는 서면에 의하여 대장상의 소유자 주소가 변경되었음을 증명할 수 있을 때에는, 신청서에는 주소를 증명하는 서면과 일치되게 소유자 주소를 기재한다(선례 5-236).

※ 첨부정보의 제공

- 신청서에는 부동산등기규칙 제46조의 첨부정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 첨부정보로 등기소에 제공하여야 한다.
- 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략 할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다. 또한 당사자 모두 자신의 공인인증서를 이용하여 전자서명을 하여야 전자적 첨부이 가능하다.
- 대위원인을 증명하는 서면의 첨부 : 대위원인을 증명하는 서면으로는 경매신청을 대위 상속 등기보다 먼저 한 경우에는 그 경매개시결정정보 또는 경매신청의 수리증명서를, 대위 상속 등기를 경매신청보다 먼저 신청하는 경우에는 당해 부동산의 등기부등본(다만, 등기신청서 첨부서류란에 「대위원인을 증명하는 서면은 ○년 ○월 ○일 접수번호 제○○호로 본 부동산에 근저당권설정등기가 경료되었기에 생략」이라 기재하고 첨부하지 않아도 될 것임)을 첨부하면 족할 것이다(등기선례5-671, 등기예규 제1432호).
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다.

따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.

- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 대리인에 의한 신청의 경우 : 대리인에 의한 신청인 경우에는 대리인이 위임에 관한 정보를 입력하고 당사자가 공인인증서정보(당사자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 첨부하여 승인하여야 한다.
- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제46조 제1항 제4호).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명서나 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증 : 방문신청의 경우 등기의무자의 인감증명서(발행일로부터 3월 이내)를 첨부하거나, 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청 발급) 등을 첨부하여야 한다(부등규칙 제46조 제1항 제2호). 토지거래계약허가증을 등기신청서에 첨부한 때에는, 등기원인증서에 검인을 받을 필요가 없으며 농지취득자격증명 또한 제출할 필요가 없다(등기예규 제1634호).

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세·농어촌특별세란

- 취득세(등록세) : 취득세설명 748면 참조

- 등록면허세 : 상속으로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의8, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.
- 서면제출의 경우 : 시장, 구청장, 군수 등으로부터 등록면허세납부서(OCR용지)를 발급받아 납세지를 관할하는 해당금융기관에 세금을 납부한 후 등록면허세영수필확인서와 영수증을 교부받아 영수증은 본인이 보관하고 '등록면허세영수필확인서' 만 신청서의 등록면허세액 표시란의 좌측상단 여백에 첨부한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이제, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 등기신청수수료 과·오납에 따른 결제방법 : 등기신청수수료를 과·오납한 경우 신청인은 등기신청사건 처리완료 전에 기존 결제를 전액 취소한 후 다시 결제를 하여야 한다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1565호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[별지 1] 상속인의 표시

상속인의 표시

박 인 수 10분의3

000000-00000000

서울 서초구 서초로120길 10

김 경 철 10분의3

000000-00000000

서울 서초구 서초로100길 20

김 영 순 10분의2

000000-00000000

서울 서초구 서초로100길 20

김 영 희 10분의2

000000-00000000

서울 서초구 서초로100길 20

[별지 2] 상속인별 시가표준액 및 국민주택채권매입금액

상속인별 시가표준액 및 국민주택채권매입금액

박 인 수	10분의3	금000원	금000원
김 경 철	10분의3	금000원	금000원
김 영 순	10분의2	금000원	금000원
김 영 희	10분의2	금000원	금000원

[사례] 위임장

위임장	
부동산의 표시	서울특별시 서초구 서초동 100 대 350㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	200 년 0 월 0 일 상속
등 기 의 목 적	소유권이전
대 위 원 인	200 년 0 월 0 일 설정된 근저당권 실행을 위한 경매에 필요함
위임인	대리인
신청인 대위신청인 김 수 길 (인) 서울 서초구 서초로25길 30	법무사 김 민 수 서울 서초구 서초로52길 30 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 200 년 0 월 0 일



제5장 상속관련 후속절차

제5장 상속관련 후속절차

제1절 감정인의 선임

[가사소송법 제2조 제1항 2.가.33), 라류 가사비송사건]

1. 의 의

한정승인자는 조건 있는 채권이나 존속기간의 불확정채권은 법원이 선임한 감정인의 평가에 의하여 변제하여야 한다(민법 제1035조 제2항).

민법 제1040조 제3항(공동상속재산의 관리인이 변제하려는 경우)의 규정도 포함한다.

2. 심판청구절차

가. 청구권자

다음과 같다.

- ① 상속의 한정승인자가 변제하려는 경우(민법 제1035조 제2항)는 한정승인자
- ② 공동상속재산의 관리인이 변제하려는 경우(민법 제1040조 제3항)는 상속재산관리인
- ③ 상속인이 배당변제하려는 경우(민법 제1051조 제3항)는 상속인
- ④ 상속인 없는 재산의 관리인이 이를 청산하려는 경우(민법 제1056조 제2항)는 상속재산관리인
- ⑤ 유류분 산정에 있어 상속재산 중에 조건부채권이나 존속기간이 불확정한 채권이 있는 경우(민법 제1113조 제2항)는 유류분 권리자

그러나 이해관계인도 감정인 선임을 청구할 수 있는지에 관하여 견해가 나뉠 수 있다.⁶⁴⁴⁾

644) 법원행정처, 법원실무제요[가사(Ⅱ)], 389면.

나. 심판청구서 작성방법

(1) 청구방법

심판청구는 서면 또는 구술로 할 수 있다(가사소송법 제36조 제1항).
서면으로 할 경우 작성방법은 아래의 [서식]을 참조한다.

(2) 청구취지 기재례

별지 목록 기재 상속재산을 평가할 감정인으로 서울 ○○구 ○○대로 123, 김○○를 선임한다.
라는 심판을 구합니다.

별지 목록 기재 상속재산을 평가에 관하여 서울 ○○구 ○○대로 123, 이○○를 감정인으로 선임한다.
라는 심판을 구합니다.

다. 첨부서류

가족관계증명서 1통, 기본증명서 1통, 한정승인심판 사본 1통, 기타서류 등이 필요하다.

라. 청구비용

라류 가사비송사건이므로 인지는 사건본인 1인당 5,000원의 인지를 붙여야 한다. 피상속인마다 1개의 청구로 본다. 따라서 피상속인이 2명이면 10,000원의 인지를 첨부하여야 한다. 인지는 법원 구내우체국에서 구입한다.

라류 가사비송사건의 송달료는 당사자의 수×5,200원×8회분이다. 송달료는 법원 구내 은행에서 송달료예납납부서를 작성하여 납부하면 된다.

마. 청구서 제출(관할법원)

상속개시시의 가정법원에 청구서를 제출한다. 즉, 피상속인의 마지막 주소지를 관할하는 가정법원에 제출한다. 그 마지막 주소지가 외국인 경우에는 대법원 소재지의 가정법원에 제출한다. 가정법원 단독판사의 사물관할에 속한다. 심판청구서 원본(법원용) 1통을 준비하여 직접 관할 가정법원에 제출하거나, 대리인에 의하여 제출할 수 있고 대리인에

의하여 제출할 경우 위임장 1통을 준비한다. 또한 우편 접수도 가능하다.

[서식] 상속재산의 감정인 선임청구서

상속재산의 감정인 선임청구

청구인(상속인) 1. 이 ○ 회 (☎)

주민등록번호

주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

2. 이 ○ 해 (☎)

주민등록번호

주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

사 건 본 인(망) 이 ○ 화

주민등록번호

최후주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

상속재산의 표시

별지 목록 기재와 같습니다.

청 구 취 지

별지 목록 기재 상속재산을 평가할 감정인으로서 서울 ○○구 ○○대로 10, 김○
○를 상속재산감정인으로 선임한다.

라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

1. 청구인 1은 피상속인 망 이○화의 처이고, 청구인 2는 그의 자입니다.

2. 피상속인이 20〇〇. 10. 30. 경부고속도로에서 교통사고로 사망하고 상속이 개시 되었으나 피상속인은 생존시 채무가 너무 과다하여 청구인들은 피상속인 망 이○화의 채무를 변제할 능력이 없어 별지목록 기재내용의 상속으로 인하여 얻은 상속재산의 한도 내에서 피상속인의 채무를 변제할 것을 조건으로 귀원에 20〇〇. 11. 25.자 한정승인을 신청하여 동년 12. 25.자 수리된 바 있습니다.
3. 따라서 청구인들은 상속으로 인하여 얻은 재산의 한도에서 피상속인의 채무를 변제하고자 별지 목록 기재 상속재산을 평가하기 위한 감정인의 선임을 위하여 청구취지와 같은 이 건 청구에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

1. 청구인의 주민등록등(초)본 1통
1. 피상속인의 기본증명서, 가족관계증명서(또는 2007. 12. 31. 전 사망한 경우 제적등본), 말소된 주민등록등(초)본 각 1통
1. 상속한정승인심판결정문 1통
1. 부동산등기사항저부증명서 1통
1. 별지목록 1통
1. 납부서 1통

20〇〇. 1. .

위 청구인 1. 이 ○ 회 (인)
2. 이 ○ 해 (인)

서울가정법원 귀중

바. 심리절차

가정법원은 감정인을 선임할 경우인지, 누구를 감정인으로 할 것인지 여부 등을 심리하여 감정인을 선임한다. 감정인의 자격에 특별한 제한은 없으므로 누구라도 감정인으로 선임할 수 있지만, 제도의 취지에 비추어 공인감정사 등 전문가를 감정인으로 선임하여야 할 것이다.

라류 가사비송사건에서는 사건관계인의 심문이 필요한 것이 아니고(가사소송법 제45조), 서면심리에 의하는 것이 보통이다.

사. 심 판

감정인선임심판은 성질상 청구인 외에 그 선임된 감정인에게도 고지하여야 한다. 심판은 이를 받은 자가 고지받음으로써 효력을 발생한다(가사소송법 제40조). 심판은 형성력이 있고, 기판력은 없다.

아. 심판종료 후의 절차(즉시항고)

청구를 기각한 심판에 대하여는 청구인이 즉시항고를 할 수 있으나, 청구를 인용한 심판에 대하여는 즉시항고를 할 수 없다.

제2절 공동상속재산을 위한 관리인의 선임

[가사소송법 제2조 제1항 2.가.34), 라류 가사비송사건]

1. 의 의

한정상속인이 수인인 경우에는 법원은 각 상속인, 그 밖의 이해관계인의 청구에 의하여 공동상속인 중에서 상속재산관리인을 선임할 수 있다(민법 제1040조 제1항).

법원이 공동상속 재산에 관한 관리인을 선임할 경우에는 반드시 그 공동상속인 중에서 관리인을 선임하여야 하므로 공동상속인 아닌 다른 사람을 선임한 결정은 위법하다.⁶⁴⁵⁾

2. 심판청구절차

가. 청구권자

한정승인을 한 공동상속인 또는 이해관계인이 청구할 수 있다.

나. 심판청구서 작성방법

(1) 청구방법

심판청구는 서면 또는 구술로 할 수 있다(가사소송법 제36조 제1항). 서면으로 할 경우 작성방법은 아래의 [서식]을 참조한다.

(2) 청구취지 기재례

사건본인 망 ○○○의 상속재산관리인으로 [성명 : ○○○, 주민등록번호 : 610320-1234567, 주소 : 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)]를 선임한다.
라는 심판을 구합니다.

다. 첨부서류

가족관계증명서 1통, 기본증명서 1통, 한정승인(포기)심판 사본 1통, 기타 서류 등이 필요하다.

645) 대법원 1979. 12. 27.자 76그2 결정.

라. 청구비용

라류 가사비송사건이므로 인지는 사건본인 1인당 5,000원의 인지를 붙여야 한다. 피상속인마다 1개의 청구로 본다. 따라서 피상속인이 2명이면 10,000원의 인지를 첨부하여야 한다. 인지는 법원 구내우체국에서 구입한다. 송달료는 당사자의 수×5,200원×10회분이다. 송달료는 법원 구내은행에서 송달료예납납부서를 작성하여 납부하면 된다.

마. 청구서 제출(관할법원)

상속개시 시의 가정법원에 청구서를 제출한다. 즉, 피상속인의 마지막 주소지를 관할하는 가정법원에 제출한다. 그 마지막 주소지가 외국인 경우에는 대법원 소재지의 가정법원에 제출한다.

가정법원 단독판사의 사물관할에 속한다. 심판청구서 원본(법원용) 1통을 준비하여 직접 관할 가정법원에 제출하거나 대리인에 의하여 제출할 수 있고, 대리인에 의하여 제출할 경우 위임장1통을 준비한다. 또한, 우편 접수도 가능하다.

바. 사전처분

공동상속재산을 위한 관리인의 선임청구는 자체가 사전처분적 성격을 가지므로 별도로 사전처분을 인정할 여지가 없다.⁶⁴⁶⁾

[서식] 공동상속재산을 위한 관리인 선임청구서

공동상속재산을 위한 관리인 선임청구

청구인(상속인) 1. 장 ○ 회 (☎)
 주민등록번호
 주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)
 등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

2. 이 ○ 해 (☎)
 주민등록번호

646) 법원행정처, 법원실무제요[가사(Ⅰ)], 268면.

주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

사 건 본 인(망) 이 ○ 화

주민등록번호

최후주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

상속재산의 표시

별지 목록 기재와 같습니다.

청 구 취 지

피상속인 망 이○화의 공동상속재산의 관리인으로 ○○○(주민등록번호 :
, 주소 : 서울 ○○구 ○○로 500)선임한다.

라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

1. 청구인1은 피상속인 망 이○화의 처이고, 청구인2는 그의 자입니다.
2. 피상속인이 20○○. 10. 30. 경부고속도로에서 교통사고로 사망하고 상속이 개시 되었으나, 피상속인은 생존 시 채무가 너무 과다하여 청구인들은 피상속인 망 이○화의 채무를 변제할 능력이 없어 별지 목록 기재내용의 상속으로 인하여 얻은 상속재산의 한도 내에서 피상속인의 채무를 변제할 것을 조건으로 귀원에 20○○. 11. 25.자 한정승인을 신청하여 동년 12. 25.자 수리된 바 있습니다.
3. 따라서 청구인2는 현재 외국 유학 중이고 청구인1과 공동상속재산을 관리할 수 없으므로 청구취지와 같은 심판을 구하고자 이 건 청구에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

1. 청구인의 주민등록등(초)본 1통
1. 피상속인의 기본증명서, 가족관계증명서(또는 2007. 12. 31. 전 사망한 경우 제적등본), 말소된 주민등록등(초)본 각 1통
1. 상속한정승인심판결정문 1통

- 1. 부동산등기사항저부증명서 1통
- 1. 재학증명서 1통
- 1. 기타(소명자료)
- 1. 납부서 1통

20〇〇. 1. .

위 청구인 1. 장 ○ 회
2. 이 ○ 해

서울가정법원 귀중

사. 심리절차

가정법원은 공동상속인지, 그중 수인이 한정승인을 한 경우인지, 누구를 상속재산관리인으로 선임할 것인지의 여부를 심리하여 공동상속재산관리인을 선임한다.

라류 가사비송사건에서는 사건관계인의 심문이 필요한 것이 아니고(가사소송법 제45조), 서면심리에 의하는 것이 보통이다.

아. 심 판

명문의 규정이 없으나 공동상속재산관리인선임심판은 청구인 외에, 선임된 재산관리인과 다른 공동상속인 전원에게 고지하여야 할 것이다.

심판은 이를 받은 자가 고지받음으로써 효력을 발생한다(가사소송법 제40조).

가정법원이 선임한 관리인은 공동상속인을 대표하여 상속재산의 관리와 채무의 변제에 관한 모든 행위를 할 권리의무가 있다(민법 제1040조 제2항). 따라서 선임된 재산관리인은 다른 공동상속인의 법정대리인과 같은 지위에 서게 된다. 심판은 형성력이 있고, 기판력은 없다.

자. 심판종료 후의 절차(즉시항고)

청구를 기각한 심판에 대하여는 청구인이 즉시항고를 할 수 있으나, 청구를 인용한 심판에 대하여는 즉시항고를 할 수 없다.

제3절 상속재산보존을 위한 처분

1. 의 의

상속인은 상속의 승인이나 포기를 하기 전까지는 그 상속재산은 고유재산에 대하는 것과 동일한 주의로 관리하여야 한다(민법 제1022조). 상속을 포기한 자는 그 포기로 인하여 상속인이 된 자가 상속재산을 관리할 수 있을 때까지 그 재산의 관리를 계속하여야 한다(민법 제1044조 제1항). 법원은 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 상속재산의 보존에 필요한 처분을 명할 수 있다(민법 제1023조 제1항).

보존에 필요한 처분에는 상속재산에 관한 봉인, 환가나 처분금지, 점유이전금지, 재산목록의 작성·제출, 경매명령 등도 있지만, 가장 중요한 것은 재산관리인의 선임이다.

2. 심판청구절차

가. 청구권자

이해관계인(공동상속인, 상속채권자, 상속인의 채권자, 차순위상속인 등 법률상의 이해관계를 가지는 자이다) 또는 검사이다.

나. 심판청구서 작성방법

(1) 청구방법

심판청구는 서면 또는 구술로 할 수 있다(가사소송법 제36조 제1항).

(2) 청구취지 기재례

1. 피상속인 망○○○의 별지 목록 기재 상속재산에 관한 재산관리인으로 변호사△△△(주민등록번호, 주소)를 선임한다.
2. 재산관리인은 3개월마다 위 상속재산에 관한 재산관리상황을 보고하여야 한다.

상속재산관리인이 사건본인 소유의 별지 목록 기재 부동산을 매각처분하는 행위를 허가한다.

다. 첨부서류

가족관계증명서 1통, 기본증명서 1통, 이해관계가 있는 증명서 1통, 기타서류 등이 필요하다.

라. 청구비용

라류 가사비송사건이므로 인지는 사건본인 1인당 5,000원의 인지를 붙여야 한다. 사건 본인마다 1개의 청구로 본다. 따라서 사건본인이 2명이면 10,000원의 인지를 첨부하여야 한다. 인지는 법원구내 우체국에서 구입한다.

송달료는 당사자의 수×5,200원×10회분이다. 송달료는 법원구내은행에서 송달료예납 납부서를 작성하여 납부하면 된다.

마. 청구서 제출(관할법원)

(1) 관할법원 및 제출기간

상속개시 시의 가정법원에 청구서를 제출한다. 즉, 피상속인의 마지막 주소지를 관할하는 가정법원에 제출한다. 그 마지막 주소지가 외국인 경우에는 대법원 소재지의 가정법원에 제출한다.

숙려기간 중에 하는 상속재산관리에 관한 처분은 상속개시 후 그 숙려기간이 경과되기 전에 한하여 청구할 수 있고, 상속포기의 경우에는 다른 상속인이 그 상속재산을 관리할 수 있을 때까지에 한하여 청구할 수 있다.

민법 제1023조 소정의 상속재산보존에 필요한 처분을 청구할 수 있는 기한 및 그 처분의 효력 존속 기한에 대하여 판례⁶⁴⁷⁾는 “민법 제1023조는, 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 상속재산의 보존에 필요한 처분을 명할 수 있도록 규정하고 있는바, 이 규정은 상속의 승인이나 포기를 위한 이른바 고려기간 중에는 그 고유재산에 대하는 것과 동일한 주의로 상속재산을 관리하여야 하고(민법 제1022조), 상속을 포기하더라도 그 포기로 인하여 상속인이 된 자가 상속재산을 관리할 수 있을 때까지 그 재산의 관리를 계속하도록 규정한 것(민법 제1044조 제1항)과 관련되어 상속인이나 상속을 포기한 자의 관리가 부적절하거나 불가능한 경우에는 다른 공동상속인이나 이해관계인의 입장에서는 상속재산의 보존을 위한 조치를 취할 필요가 있게 된다는 취지이므로 상속포기나 한정승인을 할 수 있는 고려기간 중에 하는 상속재산관리에 관한 처분은 상속개시 후 그 고려기간이 경과되

647) 대법원 1999. 06. 10. 자 99오1 결정.

기 전에 한하여 청구할 수 있고, 그 심판에서 정한 처분의 효력은 심판청구를 할 수 있는 시점한계 시까지만 존속한다”라고 판시하고 있다.

관할은 가정법원 단독판사의 사물관할에 속한다.

(2) 청구서 접수방법

심판청구서 원본(법원용) 1통을 준비하여 직접 관할 가정법원에 제출하거나, 대리인에 의하여 제출할 수 있고 대리인에 의하여 제출할 경우 위임장 1통을 준비한다. 또한, 우편 접수도 가능하다.

(3) 사전처분

상속재산보존을 위한 처분은 자체가 사전처분적인 성질을 가지므로 별도로 사전처분을 인정할 여지가 없다.⁶⁴⁸⁾

648) 법원행정처, 법원실무제요[가사(Ⅰ)], 268면.

[서식] 상속재산보존을 위한 처분청구서

상속재산보존을 위한 처분청구

청 구 인 박 ○ 호(피상속인의 자) (☎)

주민등록번호

주 소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)

등 록 기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

피상속인 망 박 ○ 수

주민등록번호

주 소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)

등 록 기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

청 구 취 지

청구인이 피상속인 망 ○○○의 유산보존에 필요한 처분을 명한다.
라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

1. 청구인은 피청구인(상속인) 이○해에게 200○. 5. 30. 자 금 100,000,000원, 월 2%로 하여 돈을 빌려 준 채권자인 이해관계가 있는 자입니다.
2. 피상속인 망 이○화는 슬하에 자녀도 없이 회사 출장시 교통사고로 200○. 5. 25. 자 사망하였고, 처에게 상속이 개시되었습니다.
3. 그러나 상속인은 아직 그 승인 또는 포기를 하지 않고 있으므로 그 재산을 그대로 방치하고 보존에 필요한 처분을 하지 않으면 상속재산이 없어질 염려가 있고 채권자인 청구인에게도 회복할 수 없는 손해가 발생할 우려가 있으므로, 청구취지와 같이 심판을 구하고자 이진 청구에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

1. 청구인의 주민등록등(초)본 1통

1. 피상속인의 기본증명서, 가족관계증명서(또는 2007. 12. 31. 전 사망한 경우 제적등본), 말소된 주민등록등(초)본 각 1통
1. 차용증 및 입금증 1통
1. 기타(소명자료)
1. 납부서 1통

200○. 1. .

위 청구인 박 ○ 호

서울가정법원 귀중

바. 심리절차

가정법원은 현재의 재산관리가 적당한지의 여부, 재산관리인 선임의 필요성 유무, 그 재산관리인의 적격성 여부 등을 심리하여 결정을 한다. 상속재산의 관리에 관한 처분에는 부재자의 재산관리에 관한 처분의 규정이 그대로 준용된다(민법 제1023조 제2항, 가사소송규칙 제78조).

라류 가사비송사건에서는 사건관계인의 심문이 필요한 것이 아니고(가사소송법 제45조), 서면심리에 의하는 것이 보통이다.

사. 심 판

심판은 청구인, 절차에 참가한 이해관계인, 선임된 재산관리인 등 이를 고지 받을 자에게 고지함으로써 효력이 발생한다. 심판은 이를 받은 자가 고지 받음으로써 효력을 발생한다(가사소송법 제40조).

기간연장을 허가한 심판의 효력은 당해 상속인에 대해서만 미친다. 심판은 형성력이 있고, 기판력은 없다.

아. 심판종료 후의 절차

(1) 즉시항고

불복한 심판에 대하여는 청구인이 즉시항고를 할 수 있으나, 청구를 인용한 심판에 대하여는 즉시항고를 할 수 없다.

(2) 상속재산관리에 관한 처분으로서 재산관리인을 선임한 경우, 상속인의 재산관리권이 상실되는가 여부

이에 대하여 견해의 대립이 있다. 즉, 재산관리인만이 상속재산을 관리할 수 있다는 견해, 상속인도 재산관리권을 가진다는 견해, 상속인이 재산관리권을 상실하는 것은 아니지만 재산관리인의 관리행위와 저촉되지 않는 범위 내에서만 관리행위를 할 수 있을 뿐이라는 견해 등이 있으나 최후의 견해가 타당하다 할 수 있다.⁶⁴⁹⁾

(3) 재산관리인 선임공고의 요부

민법 제1053조에 따른 상속재산관리인의 선임은 공고하도록 되어 있으나, 민법 제1023조에 따른 재산관리인의 선임에 관하여는 공고에 관한 규정이 없으므로 선임공고는 필요하지 않다.

649) 법원행정처, 법원실무제요[가사(Ⅱ)], 371면.

제4절 상속재산의 분리

제1관 고유재산의 분리 청구

1. 서 설

“상속재산의 분리”란 상속이 개시된 이후에 상속채권자, 유증을 받은 사람 또는 상속인의 채권자의 청구에 의해 상속재산과 상속인의 고유재산을 분리하는 것을 말한다(민법 제1045조제1항). 법원의 명령에 의하여 그 분리가 있으면 상속채권자와 유증을 받은 자는 상속재산에서, 상속인의 채권자는 상속인의 고유재산에서 채권을 변제받을 수 있다.

상속이 있게 되면 상속재산은 상속인의 고유의 재산과 혼합된다. 따라서 상속재산과 상속인의 고유재산이 섞이지 않도록 나누는 절차가 상속재산의 분리이다. 즉, 상속이 있게 되어 상속인의 고유재산과 혼합이 생기는 경우에 상속재산보다 채무가 더 많은 것이면 상속인의 채권자는 불이익을 입게 된다. 또한 상속인의 채무가 상속인의 고유재산을 넘게 되면 재산상속으로 인하여 상속채권자가 불이익을 입게 된다. 따라서 이러한 불이익을 막으려고 상속인의 고유재산을 상속재산과 분리하여 재산관계를 명확히 하고 모든 채권자에게 본래의 지위를 확보해 주는 취지이다. 예컨대, A는 甲에게 이자 없이 2천만 원을 3개월로 하여 빌려주었는데 변제기가 지나도 갚지 않자 甲에게 연락을 취한바, 甲의 아버지(乙)가 사망하여 장례 때문에 지방에 갔다는 소식을 들었다. 그 후 다른 사람에게 들은 바, 甲의 아버지(乙)는 사업을 하다 많은 빚을 남겼다고 한다. 乙이 남긴 채무도 상속인(甲)이 한정승인이거나 포기하지 않는 한 상속이 되므로 甲이 소유하고 있는 아파트와 섞이게 되면 A는 채권 회수를 하는데 불이익을 입게 될지 모르므로 甲의 고유재산과 甲의 아버지(乙) 재산이 혼합되지 않도록 하려면 A는 甲의 고유재산과 피상속인의 재산이 혼합되지 않도록 재산분리심판을 청구할 수 있다.

2. 청구절차

가. 심판청구서 작성방법

(1) 청구방법

심판청구는 서면 또는 구술로 할 수 있다(가사소송법 제36조 제1항). 서면으로 할 경우 작성방법은 아래의 [서식]을 참조한다.

(2) 청구취지 기재례

피상속인 망 ○○○의 상속재산과 상속인 ○○○(주민등록번호0000000-0000000, 주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동))의 고유재산을 분리한다.
라는 심판을 구합니다.

(3) 청구권자

상속재산보다 상속인 자신의 채무가 많은 경우 상속채권자나 유증을 받은 사람 또는 상속인의 채권자는 상속개시지의 가정법원에 재산분리를 청구할 수 있다(민법 제1045조 제1항 및 가사소송법 제44조제1항제6호).

상속재산분리 청구 상대방은 상속인이고, 상속인을 알 수 없을 때에는 상속재산관리인이 상대방이 된다. 상속인이 여러 명인 경우에는 전원을 상대방으로 하여야 한다.

(4) 청구기간

청구는 상속이 개시된 날, 즉 피상속인이 사망한 날부터 3개월 내에 하여야 한다(민법 제1045조제1항). 상속인이 상속의 승인이나 포기를 하지 않은 동안은 피상속인이 사망한 날부터 3개월이 경과된 후에도 재산의 분리를 법원에 청구할 수 있다(민법 제1045조제2항).

(5) 송달료

송달료는 당사자 수×5,200원×4회분이다. 송달료는 법원구내 은행에서 송달료예납납부서를 작성하여 납부하면 된다.

(6) 첨부서류

가족관계증명서 1통, 기본증명서 1통, 부동산등기부등본 1통, 기타서류 등이 필요하다.

(7) 청구비용

라류 가사비송사건이므로 인지는 사건본인 1인당 5,000원의 인지를 붙여야 한다. 피상속인마다 1개의 청구로 본다. 따라서 피상속인이 2명이면 10,000원의 인지를 첨부하여야 한다. 인지는 법원 구내우체국에서 구입한다. 라류 가사비송사건의 송달료는 당사자의 수 $\times 5,200\text{원} \times 10\text{회}$ 분이다. 송달료는 법원 구내은행에서 송달료예납납부서를 작성하여 납부하면 된다.

(8) 청구서 제출(관할법원)

가정법원 단독판사의 사물관할에 속한다. 청구서는 상속개시시의 가정법원에 청구서를 제출한다. 즉, 피상속인의 마지막 주소지를 관할하는 가정법원에 제출한다. 그 마지막 주소지가 외국인 경우에는 대법원 소재지의 가정법원에 제출한다. 심판청구서 원본(법원용) 1통, 부분(상대방용) 1통을 준비하여 직접 관할 가정법원에 제출하거나, 대리인에 의하여 제출할 수 있고 대리인에 의하여 제출할 경우 위임장 1통을 준비한다. 또한 우편 접수도 가능하다. 상속재산분리의 청구는 상속개시 된 날로부터 3월내에 청구하여야 한다. 다만, 상속인이 상속의 승인이나 포기를 하지 아니한 동안은 3개월이 경과하여도 재산의 분리를 청구할 수 있다.

[서식] 상속재산 분리심판청구서

상속재산 분리심판청구

청구인(상속인의 채권자)

장 ○ 회 (☎)

주민등록번호

주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

피청구인(상속인) 이 ○ 해 (☎)

주민등록번호

주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

사 건 본 인(망) 이 ○ 화

주민등록번호

최후주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

피청구인의 고유재산의 표시

별지 목록 기재와 같습니다.

청 구 취 지

피상속인 망 이○해의 상속재산과 피청구인(상속인) 이○해(주민등록번호 000000-0000000, 주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)의 고유재산을 분리한다.

라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

1. 청구인은 피청구인(상속인) 이○해에게 20○○. 5. 30.자 금 100,000,000원, 월 2%로 하여 돈을 빌려 준 채권자이고, 피청구인은 망 이○화의 처입니다.
2. 피상속인 망 이○화는 슬하에 자녀도 없이 회사 출장 시 교통사고로 20○○. 5. 25.자 사망하였고, 피청구인(상속인)에게 상속이 개시되었습니다.
3. 그러나 위 피상속인은 상속재산 보다 채무가 더 많아 상속인이 채무를 전부 상속하는 경우에는 재산상속으로 인하여 불이익이 생길 염려가 있고, 또한 채권자인 청구인에게도 회복할 수 없는 손해가 발생할 우려가 있습니다.
4. 따라서 피청구인의 고유재산으로는 별지 목록 기재 부동산만이 있을 뿐이므로 상속인인 피청구인의 고유재산과 피상속인인 망 이○화의 상속재산의 분리를 위하여, 아직 상속의 승인이나 포기를 하지 아니하고 있는 상속인인 피청구인을 상대로 이 건 청구에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

1. 청구인의 주민등록등(초)본 1통
1. 피상속인의 기본증명서, 가족관계증명서(또는 2007. 12. 31. 전 사망한 경우 제적등본), 말소된 주민등록등(초)본 각 1통

1. 차용증 및 입금증 1통
1. 부동산등기사항전부증명서 1통
1. 기타(소명자료)
1. 납부서 1통

20○○. 6. .

위 청구인 장 ○ 회 (인)

서울가정법원 귀중

[서식] 상속재산의 분리청구

상속재산의 분리청구

청 구 인(상속인의 채권자) ○ ○ ○(000000-0000000)

○○시○○구 ○○로00길0

전화 000-0000-0000

피 상속인 망 □ □ □(000000-0000000)

최후주소 ○○시○○구 ○○로00길0

상 속 인 ○ ○ ○(000000-0000000)

○○시○○구 ○○로00길0

전화 000-0000-0000

청구취지

상속인 ○○○의 고유재산과 피상속인 망 □□□의 상속재산을 분리한다.
라는 심판을 구함.

청구원인

1. 피상속인 망 □□□은 20○○년 9월 10일 사망하였습니다.
2. 상속인 ○○○은 피상속인의 자로서 상속인이고, 동인 외에 상속인이 될 자는 아무도 없습니다.
3. 청구인은 상속인 ○○○에 대하여 금5천만원의 대여금채권을 갖고 있으며 또한 그 변제기가 도래하였습니다.
4. 피상속인의 상속재산은 채무초과상태이며 상속인 ○○○의 고유재산과 상속재산을 분리하지 아니하면 청구인은 불측의 손해를 입을 우려가 있습니다. 그러므로 청구취지와 같이 심판을 구하는 바입니다.

첨 부 서 류

1. 가족관계등록증명서(청구인, 상속인) 1통
1. 제적등본(피상속인) 1통
1. 주민등록등본 1통
1. 채권증서 1통
1. 재산목록 1통
1. 납부서 1통

20 년 월 일

위 청구인 ○ ○ ○ (인)

○○가정법원 귀중

나. 심리절차

통설은 가정법원이 상속재산이나 상속인의 고유재산이 채무초과 상태에 있는지의 여부를 심리하여 그 모두가 채무초과 상태에 있지 아니하다고 인정하는 때에는 청구를 기각할 수 있다. 라류 가사비송사건에서는 사건관계인의 심문이 필요한 것이 아니고(가사소송법 제45조), 서면심리에 의하는 것이 보통이다.

다. 심 판

심판의 고지에 대하여 명문의 규정이 없으나 심판은 청구인 외에 당해 상속인에게 고지하여야 할 것이다. 심판은 이를 받은 자가 고지받음으로써 효력을 발생한다(가사소송법

제40조). 상속재산이 분리되면 상속인의 고유재산과 혼입이 금지되고 상속인의 피상속인에 대한 재산상의 권리의무는 소멸하지 않으며(민법 제1050조), 상속인은 단순승인을 한 후에도 상속재산에 대하여 자기의 고유재산과 동일한 주의로서 관리하여야 하고, 그 관리에는 위임에 관한 규정이 준용된다(민법 제1048조). 심판은 형성력이 있고, 기판력은 없다.

라. 심판종료 후의 절차(즉시항고)

청구를 기각한 심판에 대하여는 청구인이 즉시항고를 할 수 있고, 청구를 인용한 심판에 대해서도 불복이 있는 자(상속채권자, 유증을 받은 자, 상속인의 채권자)는 즉시항고를 할 수 있다.

마. 채권자 등에 대한 공고·최고

가정법원이 상속재산의 분리청구에 따라 재산의 분리를 명한 때에는 그 청구자는 5일 이내에 일반상속채권자와 유증받은 사람에 대하여 재산분리의 명령있는 사실과 일정한 기간 내에 그 채권 또는 수증을 신고할 것을 공고해야 한다. 그 기간은 2개월 이상이어야 한다(민법 제1046조제1항).

채권신고의 공고에는 채권자가 기간 내에 신고하지 않으면 청산으로부터 제외될 것을 표시해야 한다(민법 제1046조제2항 및 제88조제2항). 채권신고의 공고는 법원의 등기사항의 공고와 동일한 방법으로 해야 한다(민법 제1046조제2항 및 제88조제3항).

상속재산관리인은 알고 있는 채권자에게 대해서 각각 그 채권신고를 최고(催告)해야 한다. 알고 있는 채권자는 청산으로부터 제외하지 못한다(민법 제1046조제2항 및 제89조).

바. 상속재산관리에 관한 처분명령

가정법원이 재산의 분리를 명한 때에는 상속재산의 관리에 관하여 필요한 처분을 명할 수 있다(민법 제1047조제1항). 대개의 경우 가정법원은 재산관리인을 선임한다. 이러한 재산관리인에게는 부채자의 재산관리에 관한 규정이 준용된다.

상속인이 단순승인을 한 후에도 재산분리의 명령이 있는 때에는 상속재산에 대하여 자기의 고유재산과 동일한 주의로 관리해야 한다(민법 제1048조제1항).

상속인은 상속채권자, 상속인의 채권자 또는 수증자의 청구가 있는 때에는 재산관리의 처리상황을 보고하고 재산관리가 종료한 때에는 지체 없이 그 전말을 보고해야 한다(민법

제1048조제1항 및 제683조).

상속인이 상속재산관리의 처리에 관하여 필요비를 지출한 때에는 상속채권자, 상속인의 채권자 또는 수증자에 대하여 지출한 날 이후의 이자를 청구할 수 있다(민법 제1048조제1항 및 제688조제1항).

상속인이 재산관리의 처리에 필요한 채무를 부담한 때에는 상속채권자, 상속인의 채권자 또는 수증자에게 자기에 같음하여 이를 변제하게 할 수 있고 그 채무가 변제기에 있지 않은 때에는 상당한 담보를 제공하게 할 수 있다(민법 제1048조제1항 및 제688조제2항).

사. 상속재산분리의 효과

재산분리의 명령이 있는 때에는 피상속인에 대한 상속인의 재산상 권리의무는 소멸하지 아니한다(민법 제1050조). 다만, 상속재산인 부동산에 관해서는 재산의 분리를 등기하지 않으면 제3자에게 대항하지 못한다(민법 제1049조).

제2관 상속재산분리후의 상속재산의 관리에 관한 처분

[가사소송법 제2조 제1항 2.가.36), 라류 가사비송사건]

1. 의 의

상속재산이 분리되면 상속인은 상속재산에 대하여 자기의 고유재산과 동일한 주의로 관리할 의무가 있지만, 그 상속인에게 상속재산의 관리를 맡기는 것이 적당하지 않거나 상속인의 상속재산관리가 상당하지 않을 때에는 가정법원이 분리된 상속재산의 관리에 관하여 필요한 처분을 명할 수 있도록 하고 있다(민법 제1047조 제1항). 가정법원이 재산관리인을 선임한 경우에는 민법 제24조 내지 제26조(부재자재산관리에 관한 규정)의 규정을 준용한다(민법 제1047조 제2항).

2. 심판청구절차

가. 청구권자

이해관계인 또는 검사가 청구할 수 있다. 이해관계인은 상속채권자, 유증을 받은 자, 상속인의 채권자 등이다.

나. 심판청구서 작성방법

(1) 청구방법

심판청구는 서면 또는 구술로 할 수 있다(가사소송법 제36조 제1항). 서면으로 할 경우 작성방법은 아래의 [서식]을 참조한다.

(2) 청구취지 기재례

피상속인 망 이○화의 상속재산관리인으로 박○호(주민등록번호 : 610823-1234567, 주소 : 서울 ○○구 ○○대로 100)를 선임한다.
라는 심판을 구합니다.

(3) 첨부서류

상속재산분리명령심판 사본 1통, 재산목록 1통, 기타서류 등이 필요하다.

(4) 청구비용

라류 가사비송사건이므로 인지는 사건본인 1인당 5,000원의 인지를 붙여야 한다. 피상속인마다 1개의 청구로 본다. 따라서 피상속인이 2명이면 10,000원의 인지를 첨부하여야 한다. 인지는 법원 구내우체국에서 구입한다. 송달료는 당사자의 수×5,200원×10회분이다. 송달료는 법원 구내은행에서 송달료예납납부서를 작성하여 납부하면 된다.

(5) 청구서 제출(관할법원)

가정법원 단독판사의 사물관할에 속한다. 청구서는 상속개시 시의 가정법원에 청구서를 제출한다. 즉, 피상속인의 마지막 주소지를 관할하는 가정법원에 제출한다. 그 마지막 주소지가 외국인 경우에는 대법원 소재지의 가정법원에 제출한다. 심판청구서 원본(법원용) 1통, 부분(상대방용) 1통을 준비하여 직접 관할 가정법원에 제출하거나, 대리인에 의하여 제출할 수 있고 대리인에 의하여 제출할 경우 위임장 1통을 준비한다. 또한 우편 접수도 가능하다.

(6) 사전처분

위 청구는 자체가 사전처분적 성격을 가지므로 별도로 사전처분을 인정할 여지가 없다.⁶⁵⁰⁾

650) 법원행정처, 법원실무제요[가사(Ⅰ)], 268면.

[서식] 상속재산관리인선임심판청구서(상속재산분리후의 상속재산관리에 관한 처분)

상속재산관리인선임심판청구

청구인(상속인의 채권자)

장 ○ 회 (☎)

주민등록번호

주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

피청구인(상속인) 이 ○ 해 (☎)

주민등록번호

주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

사 건 본 인(망) 이 ○ 화

주민등록번호

최후주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

청 구 취 지

피상속인 망 이○화의 상속재산관리인으로 박○호(주민등록번호 : 000000-0000000, 주소 서울 ○○구 ○○대로 10)를 선임한다.
라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

1. 청구인은 피청구인(상속인) 이○해에게 20○○. 5. 30.자 금 100,000,000원, 월 2%로 하여 돈을 빌려 준 채권자이고, 피청구인은 망 이○화의 처이며, 상속재산관리인으로 선임되고자 하는 자는 망 이○화의 동생입니다.

2. 피상속인 망 이○화는 슬하에 자녀도 없이 회사 출장 시 교통사고로 20○○. 5. 25.자 사망하였고, 피청구인(상속인)에게 상속이 개시되었으나 위 피상속인은 상속재산보다 채무가 더 많아 상속인이 채무를 전부 상속하는 경우에는 재산상속으로 인하여 불이익이 생길 염려가 있고, 또한 채권자인 청구인에게도 회복할 수 없는 손해가 발생할 우려가 있어 상속인인 피청구인의 고유재산과 피상속인인 망 이○화의 상속재산의 분리를 위하여 귀원 20○○. 7. 15.자 상속재산분리의 결정을 받은 바 있습니다.
3. 따라서 상속재산이 분리되면 상속인은 상속재산에 대하여 자기 고유의 재산과 동일한 주의로 관리할 의무가 있지만 피청구인도 채무가 많은 상태이므로 피청구인에게 상속재산의 관리를 맡기는 것은 적당하지 않으므로 이건 청구취지와 같은 이 건 청구에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

1. 청구인의 주민등록등(초)본 1통
1. 기본증명서, 가족관계증명서 각 1통
1. 제적등본 1통
1. 상속재산의 분리심판등본 1통
1. 부동산등기사항전부증명서 1통
1. 별지목록 1통
1. 납부서 1통

20○○. 6. .

위 청구인 장 ○ 회 (인)

서울가정법원 귀중

다. 심리절차

상속재산분리후의 상속재산관리에 관한 처분에는 부재자재산관리에 관한 규정이 그대로 준용된다. 라류 가사비송사건에서는 사건관계인의 심문이 필요한 것이 아니고(가사소송법 제45조), 서면심리에 의하는 것이 보통이다.

라. 심 판

심판은 이를 받은 자가 고지받음으로써 효력을 발생한다(가사소송법 제40조). 심판은 형성력이 있고, 기판력은 없다.

마. 심판종료 후의 절차

심판에 대하여는 불복이 허용되지 않는다.

제5절 상속인의 부존재

제1관 상속관리인의 선임 및 그 공고와 재산관리에 관한 처분

[가사소송법 제2조 제1항 2.가.37), 라류 가사비송사건]

1. 의 의

상속인의 부존재라 함은 상속인의 존부가 분명하지 아니한 경우를 말한다. 예컨대 어떤 자가 사망한 때에 그의 상속인으로 될 배우자, 자식, 부모, 형제자매 등이 존재하는지가 분명하지 않는 것을 말한다. 이 경우에는 민법이 정하는 일정한 절차에 따라 상속재산을 관리·청산하게 된다. 예컨대 甲은 처와 자식이 없고 형제자매도 없다. 혼자 살면서 약간의 재산을 모았지만 오랫동안 앓았던 지병이 악화되어 주변정리를 하려고 현재 소유하고 있는 아파트를 A에게 매매하려고 한다. 그리고 헌신적으로 丙을 간호하고 식사, 빨래 등 곳은 집안일까지 도맡아 주었던 乙에게 현금으로 약 3천만 원을 주려고 생각하였다. A는 甲에게 부동산매수대금조로 계약금과 중도금을 이미 지불하였고 잔금은 중도금 주는 날로부터 한 달 이내에 주기로 하고 그때 소유권이전에 필요한 모든 서류를 넘겨받기로 하였다. 그런데 甲이 잔금 받기로 한 10일 전에 갑자기 사망하여 乙이 상주가 되어 장례까지 치러주었다. 이 경우에 A는 그 부동산을 매수할 수 없는가? 또한 乙은 甲의 재산을 분여 받을 수 없는가?

위 사례에서처럼 甲에게는 상속인의 존부가 분명하지 않아 A 또는 乙은 상속인이 나타날 때까지 상속재산을 관리하기 위하여 민법이 정한 그 첫 단계로서 상속재산의 관리와 상속인의 수색을 위한 조치를 하여야 한다. 그리고 A는 잔금을 법원에 공탁하고 상속재산관리인의 상대로 부동산 소유권이전등기청구의 소를 제기하면 될 것이다.

2. 상속재산의 관리

가. 민법 제1053조

상속인의 존부가 분명하지 아니한 때에는 “법원은 제777조의 규정에 의한 피상속인의 친족 기타 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 상속재산관리인을 선임하고 지체 없이 이를 공고하여야 한다.”라고 민법 제1053조에서 규정하고 있다. 여기서 이해관계인이란

상속재산의 귀속에 관하여 법률상의 이해관계를 갖는 자이다. 즉, 상속채권자, 유증을 받은 자, 상속채무자, 상속재산상의 담보권자 등을 말한다. 위 사례에서 A는 이해관계인이므로 상속재산관리인의 선임과 그 선임사실의 공고 및 관리인에 대하여 하는 재산관리에 관한 처분을 법원에 청구할 수 있다. 이는 라류 가사비송사건으로 규정하고 있다.

상속재산관리인은 상속인의 존부가 분명하지 않은 경우라야 하고, 사건본인의 4촌 이내의 혈족이 모두 사망하였거나 상속포기를 하였다는 점이 소명된 때에 한하여 선임할 수 있는바, 상속인의 행방불명은 상속재산관리인 선임의 요건에 해당하지 않는다. 따라서 가족관계등록부의 기록상으로도 피상속인의 사망 당시 상속인으로는 최선순위자로서 그의 딸인 甲 및 차순위 상속인인 乙이 있으므로, 청구인의 주장은 이유 없다고 하였고 이 경우에는 상속인에 대하여 부재자재산관리인을 선임하거나 실종선고를 청구하여야 할 것이다.⁶⁵¹⁾

망인의 직계비속인 딸이 이복에 있어 생사 불명이라는 이유만으로는 재산상속인에서 제외될 수 없으므로,⁶⁵²⁾ 위와 같은 방법으로 청구하여야 한다. 다만, 이미 경매가 개시된 후에 채무자가 사망한 다음 상속인을 찾지 못한 경우에는 집행법원이 특별대리인을 선임하여 절차를 진행하게 된다(민사집행법 제52조 제2항, 제275조).

나. 심판청구절차

(1) 청구권자

청구권자는 민법 제777조의 규정에 의한 피상속인의 친족, 그 밖의 이해관계인 또는 검사가 청구할 수 있다. 이해관계인은 상속재산의 관리, 청산에 법률상의 이해관계를 가지는 자, 즉 특정유증을 받은 자, 상속채권자, 상속채무자, 상속재산의 분여를 청구할 수 있는 특별연고자 등을 가리킨다. 상속재산관리인은 상속채권자나 유증받은 자의 청구가 있는 때에는 언제든지 상속재산의 목록을 제시하고 그 상황을 보고하여야 한다(민법 제1054조).

(2) 청구서 작성방법

(가) 청구방법

심판청구는 서면 또는 구술로 할 수 있다(가사소송법 제36조 제1항). 서면으로 할 경우

651) 서울가정법원 2006. 09. 18. 선고 2006느단7162 판결.

652) 대법원 1982. 12. 28. 선고 81다452,453 판결.

작성방법은 아래의 [서식]을 참조한다.

[서식] 상속재산관리인선임심판청구서(상속인 없는 재산의 관리인선임)

상속재산관리인선임심판청구

청구인(피상속인의 채권자)

장 ○ 회 (☎)

주민등록번호

주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

사건본인(망) 이 ○ 화

주민등록번호

최후주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

청 구 취 지

피상속인 망 이○화의 상속재산관리인으로 정○호(주민등록번호 : , 주소 : 서울 ○○구 ○○대로 10)를 선임한다.

라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

1. 청구인은 사건본인(피상속인) 이○화에게 20○○. 5. 30.자 금 100,000,000원, 월 2%로 하여 돈을 빌려 준 채권자이고, 상속재산관리인으로 선임되고자 하는 자는 현재 대한변호사협회 소속 변호사로 활동하고 있습니다.
2. 피상속인은 불의의 산업재해로 20○○. 5. 25.자 사망으로 상속이 개시되었으나 재산상속인의 존부를 알 수 없으므로, 그 상속재산의 관리를 위하여 청구취지와 같은 이 건 청구에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

1. 청구인의 주민등록등(초)본 1통
1. 기본증명서, 가족관계증명서 각 1통
1. 제적등본 1통
1. 차용증 및 입금증 각 1통
1. 납부서 1통

20○○. 6. .

위 청구인 장 ○ 회 (인)

서울가정법원 귀중

(나) 청구취지 기재례

피상속인 망 ○○○의 상속인 없는 상속재산관리인으로서 ○○시 ○○구 ○
 ○로 10, 김○동(561234-1234567)을 선임한다.
 라는 심판을 구합니다.

(3) 첨부서류

가족관계증명서(망인, 청구인) 1통, 기본증명서 1통, 기타서류 등이 필요하다.

(4) 청구비용

라류 가사비송사건이므로 인지는 사건본인 1인당 5,000원의 인지를 붙여야 한다. 피상속인마다 1개의 청구로 본다. 따라서 피상속인이 2명이면 10,000원의 인지를 첨부하여야 한다. 인지는 법원 구내우체국에서 구입한다.

라류 가사비송사건의 송달료는 당사자의 수×5,200원×10회분이다. 송달료는 법원 구내 은행에서 송달료예납납부서를 작성하여 납부하면 된다.

(5) 청구서 제출(관할법원)

관할법원은 상속개시시의 가정법원의 관할에 속한다. 즉, 피상속인의 마지막 주소지를

관할하는 가정법원에 제출한다. 그 마지막 주소지가 외국인 경우에는 대법원 소재지의 가정법원에 제출한다. 심판청구서 원본(법원용) 1통을 준비하여 직접 관할 가정법원에 제출하거나, 대리인에 의하여 제출할 수 있고 대리인에 의하여 제출할 경우 위임장 1통을 준비한다. 또한 우편 접수도 가능하다.

(6) 심판청구의 변경·병합, 사전처분

상속의 한정승인의 신고를 상속의 포기신고로, 또는 그 반대로 변경하는 것은 전에 한 신고의 취하와 새로운 신고라 할 수 있으므로 그 수리 전에는 할 수 있다고 할 수 있겠다. 위 청구는 자체가 사전처분적 성질을 가지므로 별도로 사전처분을 인정할 여지가 없다.⁶⁵³⁾

(7) 심리절차

심리는 상속인의 존부가 분명하지 아니한 경우인지의 여부 및 상속재산이 존재하는지의 여부 및 관리의 필요성 유무에 집중된다. 라류 가사비송사건에서는 사건관계인의 심문이 필요한 것이 아니고(가사소송법 제45조), 서면심리에 의하는 것이 보통이다.

(8) 심 판

(가) 심판의 효력발생시기

심판은 이를 받은 자가 고지받음으로써 효력을 발생한다(가사소송법 제40조).

(나) 심판의 효력

청구를 인용하는 재판을 하면 재산관리인을 선임하고 그 재산관리인에게 재산관리에 관한 처분을 명한다. 상속재산관리인은 상속채권자나 유증받은 자의 청구가 있는 때에는 언제든지 상속재산의 목록을 제시하고 그 상황을 보고하여야 한다(민법 제1054조). 심판은 형성력이 있고, 기판력은 없다.

(9) 심판종료 후의 절차

(가) 즉시항고

청구를 기각한 심판에 대하여는 청구인이 즉시항고를 할 수 있고, 청구를 인용한 심판에 대하여는 즉시항고를 할 수 없다.

653) 법원행정처, 법원실무제요[가사(Ⅰ)], 268면.

(나) 상속재산관리인선임의 공고

상속재산관리인을 선임한 가정법원은 지체 없이 이를 공고하여야 한다. 이는 관리인 선임심판에 따른 부수절차로서 별도의 심판을 하여야 하는 것은 아니다. 공고는 가정법원이 직권으로 한다. 공고할 사항은 상속재산관리인을 선임하였다는 것일 뿐 그 재산관리인에게 명한 재산관리에 관한 처분은 공고의 대상이 아니다.

공고의 내용(공고문례)은 아래와 같다.

○○지방법원
상속재산관리인의 선임공고

이 법원 20○○느1234 상속재산관리인선임청구사건에 관하여 이 법원은 민법 제1053조 제1항의 규정에 의한 상속재산관리인을 선임하였으므로 다음과 같이 이를 공고한다.

- 다 음 -

1. 심판청구인 ○ ○ ○
주소 서울 ○○구 ○○대로○○길 ○○(○○동)
대리인 변호사
1. 피상속인 ○ ○ ○
등록기준지 : 서울 ○○구 ○○대로 10
마지막 주소 : 서울 ○○구 ○○대로○○길 ○○(○○동)
직 업 : 회사원
1. 피상속인의 출생장소
생년월일 : 20○○. . .
사망일시 및 장소 : 20○○. . . 오전 11:00
주소 : 서울 ○○구 ○○동 ○○번지 ○○병원에서 사망
1. 상속재산관리인 ○ ○ ○
서울 ○○구 ○○대로○○길 ○○(○○동)

20○○. 8. .

판 사 ○ ○ ○

(다) 상속인의 출현

상속재산의 관리 중에 상속인이 존재한다는 것이 밝혀진 때에는 상속재산관리는 종료하고, 관리인의 대리권도 소멸한다. 민법 제1055조 제1항에서 “관리인의 임무는 그 상속인이 상속의 승인을 한 때에 종료한다.”라고 규정하고 있다.

그리고 상속인이 승인한 때에는 관리인은 상속재산의 관리에 관하여 생긴 일체의 수입과 지출을 계산해서 상속인에게 보고하여야 한다.

(라) 기타 문제

① 상속재산관리인의 선임 청구인에게 상속재산관리인의 보수의 예납을 명할 수 있는지 여부 : 민법 제1053조 제1항 소정의 상속재산관리인의 선임 청구인에게 상속재산관리인의 보수의 예납을 명할 수 있는지 여부 및 그 보수 상당액의 예납명령에 대한 불복방법에 대하여 판례는 법원이 민법 제1053조 제1항에 의하여 선임하는 상속재산관리인의 보수는 가사소송규칙 제4조 제1항에서 규정하고 있는 ‘기타 심판절차의 비용’에 포함된다고 해석함이 상당하므로 위 규정이 준용하는 민사소송법 제106조, 민사소송규칙 제5조 제1항에 의하여, 그 선임을 청구한 청구인에게 이를 예납하게 할 수 있고, 민법 제1053조 제2항, 제26조 제2항 및 가사소송규칙 제78조, 제52조 제1항의 규정들은 상속재산관리인의 보수는 종국적으로 상속재산의 부담으로 한다는 것일 뿐 청구인에게 그 보수를 예납하게 하는 것을 금지한 취지는 아니므로 이러한 규정들이 있다 하여 위와 달리 볼 것은 아니며, 한편 그 보수 상당액의 예납명령에 대하여는 불예납을 이유로 하여 청구인에게 불이익한 심판 등이 이루어질 경우 그에 대한 불복절차에서 그 당부를 다룰 수 있을 뿐 독립하여 불복할 수 없다.⁶⁵⁴⁾

② 상속재산의 관리인의 직위에서 상속재산의 소유권확인을 구할 수 있는지 여부 : 상속재산의 관리인은 그의 지위에서 소를 제기하고 이를 수행할 수 있는 것이므로 상속재산의 소유권확인을 구하는 상속재산의 관리인으로서의 구태여 상속인일 필요는 없다.⁶⁵⁵⁾

③ 재산상속인의 존부가 불분명한 상속재산에 관하여 민법 제1053조의 상속재산 관리인이 제소자가 되는 경우 : 공장에서 공상으로 사망한 갑에 대한 퇴직금을 여러 사람이 위 갑의 유산상속인이라고 주장하여 청구하는 관계로 지불치 못하고 있는 사정이 추지되는 경우에는 구 민법(1990. 1. 13. 법률 제4199호로 개정 전) 제1053조에 의하여 상속재산관

654) 대법원 2001. 08. 22. 자 2000오2 결정.

655) 대법원 1977. 01. 11. 선고 76다184, 76다185 판결.

리인의 선임을 신청한 후 그 절차에서 선임된 관리인이 법정대리인으로부터 소를 제기하여야 하고, 그 관리인의 선임절차를 밟지 않고 직접 민사소송법 제58조의 규정에 따른 경우에 특별대리인선임신청을 하여야 할 긴박한 사정(손해를 받을 염려)에 관한 아무런 소명도 발견되지 아니한다면 그 신청을 기각한 것은 옳다.⁶⁵⁶⁾

제2관 상속인 수색의 공고

[가사소송법 제2조 제1항 2.가.38), 라류 가사비송사건]

1. 의 의

청산의 결과 남은 재산이 있다면 마지막 한 번 더 상속인을 수색하는 공고를 한다. 즉, 앞서 설명한 일반상속채권자와 유증받은 자에 대하여 2월 이상 기간을 정하여 그 채권 또는 수증을 신고할 것을 공고하고 위 기간이 경과하여도 상속인의 존부를 알 수 없는 때에는 법원은 관리인의 청구에 의하여 1년 이상의 기간(2005. 3. 31. 민법개정)을 정하여 상속인이 있으면 그 기간 안에 권리를 주장할 것을 공고하여야 한다(민법 제1057조).

2. 심판청구절차

가. 청구권자

상속재산관리인이 청구한다.

나. 심판청구서 작성방법

(1) 청구방법

심판청구는 서면 또는 구술로 할 수 있다(가사소송법 제36조 제1항). 서면으로 할 경우 작성방법은 아래의 [서식]을 참조한다.

(2) 청구취지 기재례

사건본인 피상속인에게 상속인이 있으면 일정한 기간 내에 그 권리를 주장할 취지의 공고를 한다.

라는 심판을 구합니다.

656) 대법원 1967. 03. 28.자 67마155 결정.

다. 첨부서류

가족관계증명서 1통, 기본증명서 1통, 재산관리인선임심판등본 1통, 상속권주장의 최고 공고서 1통, 기타서류 등이 필요하다.

라. 청구비용

라류 가사비송사건이므로 인지는 사건본인 1인당 5,000원의 인지를 붙여야 한다. 피상속인마다 1개의 청구로 본다. 따라서 피상속인이 2명이면 10,000원의 인지를 첨부하여야 한다. 인지는 법원 구내우체국에서 구입한다.

라류 가사비송사건의 송달료는 당사자의 수×5,200원×10회분이다. 송달료는 법원 구내 은행에서 송달료예납납부서를 작성하여 납부하면 된다.

공고비용은 당사자 3인을 기준으로 서울가정법원에서는 33,000원을 받고 있다.

마. 청구서 제출(관할법원)

가정법원 단독판사의 사물관할에 속한다. 상속재산관리인을 선임한 가정법원에 제출한다.

심판청구서 원본(법원용) 1통을 준비하여 직접 관할 가정법원에 제출하거나, 대리인에 의하여 제출할 수 있고 대리인에 의하여 제출할 경우 위임장 1통을 준비한다. 또한 우편 접수도 가능하다.

[서식] 상속인 수색의 공고청구서

상속인 수색의 공고청구

청구인(피상속인의 채권자)

장 ○ 회 (☎)

주민등록번호

주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

사건본인(망) 이 ○ 화

주민등록번호

최후주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

청 구 취 지

사건본인 피상속인에게 상속인이 있으면 일정한 기간 내에 그 권리를 주장할 취지의 공고를 한다.

라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

1. 청구 외 장○회는 사건본인(피상속인) 이○화에게 20○○. 5. 30.자 금 100,000, 000원, 월 2%로 하여 돈을 빌려 준 채권자이고, 피상속인은 불의의 산업재해로 20○○. 5. 25.자 사망으로 상속이 개시되었으나 재산상속인의 존부를 알 수 없으므로, 그 상속재산의 관리를 위하여 귀원에 상속재산관리인을 변호사로 선임한 바 있습니다.

2. 그런데 귀원에서 한 그 관리인선임의 공고에 따른 상속인의 존부가 불분명하므로 청구인은 관리인으로서 위 상속재산에 관한 모든 상속채권자 및 수증자에 대하여

20〇〇. 10. 30.까지 채권 또는 수증을 신고하도록 공고하였으나, 이 또한 아직까지 상속인이 있음이 분명치 아니합니다.

3. 따라서 민법 제1057조의 규정에 의해 또다시 상속인이 있으면 일정한 기간 내에 그 권리를 주장할 취지의 공고를 구하기 위하여 청구취지와 같이 이 건 청구에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

1. 상속재산관리인선임 심판문 1통
1. 상속권주장의 최고공고서 1통
1. 납부서 1통

20〇〇. 6. .

위 청구인 정 ○ 호 (인)

서울가정법원 귀중

바. 심리절차

라류 가사비송사건에서는 사건관계인의 심문이 필요한 것이 아니고(가사소송법 제45조), 서면심리에 의하는 것이 보통이다.

사. 심 판

공고하는 외에 따로 심판서를 작성할 필요는 없다.

심판은 이를 받은 자가 고지받음으로써 효력을 발생한다(가사소송법 제40조). 심판은 형성력이 있고, 기판력은 없다.

아. 심판종료 후의 절차

청구를 기각한 심판에 대하여는 청구인이 즉시항고를 할 수 있고, 청구를 인용한 심판에 대하여는 즉시항고를 할 수 없다. 공고의 내용(공고문례)은 아래와 같다.

○○지방법원
상속인수색의 공고

이 법원 20○○느1204 상속인재산관리선임청구사건에 관하여 이 법원은 민법 제 1057조의 규정에 의하여 다음과 같이 이를 공고한다.

- 다 음 -

1. 심판청구인 ○ ○ ○

(재산관리인) 서울 ○○구 ○○대로○○길 ○○(○○동)

대리인 변호사 :

1. 피상속인 ○ ○ ○

등록기준지 : 서울 ○○구 ○○동 ○○번지

마지막주소 : 서울 ○○구 ○○대로○○길 ○○(○○동)

직 업 : 회사원

1. 피상속인의 출생장소

생년월일 : 20○○. . .

사망일시 및 장소 : 20○○. . . 오전 11:00

주소 : 서울 ○○구 ○○동 ○○번지 ○○병원에서 사망

1. 위 피상속인의 상속인이 있으면 20○○. 8. 31.까지 그 권리를 주장할 것. 만약 이 기간내에 그 권리를 주장하는 자가 없을 때에는 상속재산은 특별연고자에게 분여되거나 국고에 귀속한다.

20○○. 8. .

판사 ○ ○ ○

제6절 상속재산의 분여(특별연고자에 대한 상속재산의 분여)

[가사소송법 제2조 제1항 2.가.39), 라류 가사비송사건]

1. 의 의

상속재산의 관리·청산을 한 후에도 잔여재산이 있게 되고 또한 상속인 수색을 위한 상속인수색의 공고를 하였으나 소정의 기간 내(1년 이상)에 상속인이 나타나지 않으면 국가에 귀속하지만, 국가에 귀속하기 전에 망인과 생계를 같이 하고 있던 자, 망인을 요양간 호한 자, 기타 망인과 특별한 연고가 있던 자의 청구가 있으면 가정법원은 상속재산의 전부 또는 일부를 분여할 수 있다(민법 제1057조의2).

특별연고자인가를 판단하는 것은 가정법원의 재량이므로 가정법원이 특별연고자라고 인정한 때 비로소 특별연고자가 된다.

2. 심판청구절차

가. 청구방법

민법에 의하면, ①상속인의 존부가 분명하지 아니한 때에는 법원은 피상속인의 친족 기타 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 상속재산관리인을 선임하고 지체 없이 이를 공고한 후에 공고가 있는 날로부터 3월 내에 상속인의 존부를 알 수 없는 때에는 관리인은 지체 없이 일반상속채권자와 유증받은 자에 대하여 2월 이상의 기간을 정하여 그 기간 내에 그 채권 또는 유증받은 사실을 신고할 것을 공고하여야 하며, ②공고기간 내에 상속권을 주장하는 자가 없는 때에는 가정법원은 피상속인과 생계를 같이하고 있던 자, 피상속인의 요양간호를 한 자 기타 피상속인과 특별한 연고가 있던 자의 청구에 의하여 상속재산의 전부 또는 일부를 분여할 수 있는데, 이 청구는 가정법원이 상속인수색의 공고에서 정한 상속권주장의 최고기간이 만료된 후 2월 이내에 하여야 한다(민법 제1053조, 제1056조, 제1057조의2 제2항).

그리고 가정법원에서 분여청구를 인용하는 경우에도 그 분여의 범위는 법원의 자유로운 판단에 의하여 결정될 것이다.

나. 청구권자

청구권자는 피상속인과 특별한 연고가 있는 자이다. 연고자는 자연인에 한정되지 않고, 생계비를 보조한 지방공공단체, 학교법인, 종교법인, 사회복지법인 등 법인이나 권리능력이 없는 사단재단, 양로원·요양소·고아원·동창회 등 단체도 특별연고자가 될 수 있다. 민법 제1057조의2 제1항의 피상속인과 생계를 같이하고 있던 자(사실상 배우자, 사실상의 양친자, 계모자, 적모서자, 인지되지 아니한 혼인 외 출생자, 당숙이나 당질 등 5촌 이상의 방계혈족 등으로서 가족적 공동생활을 하고 있는 자 등이 이에 속한다.), 피상속인의 요양 간호를 한 자 등은 그 예시이다.

특별연고자는 피상속인과 현실적인 관계, 친족관계의 유무 등을 종합적으로 고려하여 가정법원이 판단한다. 피상속인의 사망 후에 상속재산의 관리, 장례절차의 주재, 재산의 주재 등을 실시한 자도 특별연고자에 해당하는지에 관하여는 이를 긍정하는 견해도 있으나 부정설이 우세하다.⁶⁵⁷⁾

다. 심판청구서 작성방법

(1) 청구방법

심판청구는 서면 또는 구술로 할 수 있다(가사소송법 제36조 제1항). 서면으로 할 경우 작성방법은 아래의 [서식]을 참조한다.

(2) 청구취지 기재례

피상속인 망 이○화 소유의 별지 목록 기재 재산은 청구인에게 분여한다.
라는 심판을 구합니다.

사건본인 망○○○의 별지 목록 기재 상속재산 중에서 50,000,000원에 해당
하는 부분은 청구인에게 분여한다.
라는 심판을 구합니다.

657) 법원행정처, 법원실무제요[가사(Ⅱ)], 405면.

1. 상속재산관리인의 보수는 8,000,000원으로 정한다.
 2. 사건본인 망○○○의 별지 목록 기재 상속재산 중에서 위 상속재산 중에서 위 상속재산관리인 보수 8,000,000원을 제외한 나머지 상속재산 분여를 청구인에게 한다.
- 라는 심판을 구합니다.

라. 첨부서류

가족관계증명서 1통, 기본증명서 1통, 상속재산관리인선임청구심판등본 1통, 상속인 수색의 공고서등본 1통, 특별연고관계를 증명하는 서면 1통, 기타서류 등이 필요하다.

마. 청구비용

라류 가사비송사건이므로 인지는 사건본인 1인당 5,000원의 인지를 붙여야 한다. 청구인마다 1개의 청구로 본다. 따라서 청구인이 2명이면 10,000원의 인지를 첨부하여야 한다. 인지는 법원 구내우체국에서 구입한다.

라류 가사비송사건의 송달료는 당사자의 수×5,200원×10회분이다. 송달료는 법원 구내 은행에서 송달료예납납부서를 작성하여 납부하면 된다.

바. 청구서 제출(관할법원)

상속개시 시의 가정법원이 관할한다. 상속개시 시는 피상속인의 마지막 주소지를 가리킨다.

상속재산분여 청구는 가정법원이 상속인 수색의 공고에서 정한 상속권 주장의 최고기간이 만료된 후 2월 이내에 하여야 한다(민법 제1057조의2 제2항).

가정법원 단독판사의 사물관할에 속한다.

심판청구서 원본(법원용) 1통을 준비하여 직접 관할 가정법원에 제출하거나, 대리인에 의하여 제출할 수 있고 대리인에 의하여 제출할 경우 위임장 1통을 준비한다. 또한 우편 접수도 가능하다.

[서식] 상속재산의 분여심판청구서

상속재산의 분여심판청구

청구인(특별연고자)

장 ○ 호 (☎)

주민등록번호

주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

사건본인(망) 이 ○ 화

주민등록번호

최후주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

상속재산의 표시

별지 목록 기재와 같습니다.

청 구 취 지

피상속인 망 이○화 소유의 별지 목록 기재 재산은 청구인에게 분여한다.
라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

1. 피상속인은 불의의 산업재해로 20○○. 5. 25.자 사망으로 상속이 개시되었으나 재산상속인의 존부를 알 수 없으므로, 그 상속재산의 관리를 위하여 귀원에 상속재산관리인을 변호사로 선임한 바 있습니다.
2. 또한 귀원에서 한 그 관리인선임의 공고에 따른 상속인의 존부가 불분명하므로 재산관리인이 위 상속재산에 관한 모든 상속채권자 및 수증자에 대하여 20○○. 10. 30.까지 채권 또는 수증을 신고하도록 공고하였으나, 이 또한 아직까지 상속인이 있음이 분명치 않으므로, 민법 제1057조의 규정에 의해 또다시 상속인이 있으면 일정한 기간 내에 그 권리를 주장할 취지의 공고도 하였습니다.

3. 위와 같이 상속인수색의 공고까지 하였으나 공고기간이 지났음에도 상속인을 찾을 길이 없었고, 마침 피상속인이 사망하기 전 약 3개월 동안 동거한 사실이 있고, 병원에 치료를 받은 약 5개월 동안 간호를 하였으며, 또한 사망 후에도 상속재산의 관리 및 장례절차의 주재 등 모든 전반적인 일을 도맡아 하였습니다.
4. 따라서 청구인은 민법 제1057조의2의 규정에 의하여 특별연고자로서 상속재산의 분여를 받기 위하여 청구취지 기재와 같은 심판을 구하기 위하여 이 건 청구에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

1. 피상속인의 가족관계증명서, 주민등록등(초)본 각 1통
1. 청구인의 주민등록등(초)본 1통
1. 재산관리인선임심판등본 1통
1. 상속인수색의 공고서등본 1통
1. 특별연고관계 확인서 및 인감증명서 각 1통
1. 부동산등기사항전부증명서 1통
1. 별지목록 1통
1. 납부서 1통

20〇〇. 6. .

위 청구인 정 ○ 호 (인)

서울가정법원 귀중

사. 심리절차

가정법원은 상속재산을 분여하는 것이 상당한지 및 어느 정도를 분여 할 것인지의 여부는 특별연고의 내용, 정도, 특별연고자의 성별, 연령, 직업, 교육정도, 상속재산의 종류와 수액 등 일체의 사정을 조사하여 심리한다.⁶⁵⁸⁾

분여의 대상으로 되는 것은 상속재산에서 상속채권자, 유증을 받은 자 등에게 청산을

⁶⁵⁸⁾ 대법원 2005. 12. 28. 자 2005스78, 2005스79 결정.

하고 남은 잔존재산이다.

라류 가사비송사건에서는 사건관계인의 심문이 필요한 것이 아니고(가사소송법 제45조), 서면심리에 의하는 것이 보통이다.

특별연고자가 분여를 청구한 후 심판 전에 사망한 때에는, 분여청구권은 엄밀한 의미에서 권리라고 할 수 없고 상속되지 아니하므로 절차가 종료된다는 견해도 있으나, 분여청구권을 기대권의 일종으로 보아 상속의 대상으로 되고 따라서 그 상속인이 절차를 승계하여야 한다는 견해가 타당하다.⁶⁵⁹⁾

아. 심 판

청구를 인용한 심판을 할 경우에는 청구인 외에 상속재산관리인에게도 고지하여야 한다. 심판은 이를 받은 자가 고지받음으로써 효력을 발생한다(가사소송법 제40조).

청구인의 청구취지에 구속력이 있는 것은 아니다. 그러나 이혼 시의 재산분할 등에 준하여 청구취지를 넘어서까지 분여할 것은 아니라고 할 것이다. 심판은 형성력이 있고, 기판력은 없다.

자. 심판종료 후의 절차

(1) 불 복

청구를 기각한 심판에 대하여 청구인은 즉시항고를 할 수 있고, 청구를 인용한 심판에 대하여 불복이 있는 자도 즉시항고를 할 수 있다.

(2) 분여 심판 후 특별연고자에게 재산을 주지 않는 경우의 조치

특별연고자는 가사소송규칙 제97조의 규정이 준용되지 않으므로 이행명령은 할 수 없다. 따라서 상속재산관리인 등을 상대로 별도의 소를 제기(민사소송)할 수밖에 없다.

659) 법원행정처, 법원실무제요[가사(Ⅱ)], 406~407면.

제7절 상속인이 존재하지 않을 경우 상속재산

상속인의 존부가 명확하지 않으면 앞서 설명한 절차에 의해 가정법원에 의한 상속인 수색공고에서 명시된 1년 이상의 기간 내에 상속권을 주장하는 자가 없으면 특별연고자에 대한 분여 등을 고려한 후 남은 상속 재산은 국가에 귀속한다. 따라서 일단 국가에 귀속되면 상속재산으로 변제 받지 못한 상속채권자나 유증을 받을 자가 있더라도 국가에 대하여 그 변제를 청구하지 못한다. 따라서 공고기간 내에 신고하여 불이익을 받지 않도록 해야 한다.

국가는 적극재산만 취득하며 채무는 부담하지 않는다. 적극재산이라도 무체재산권(특허권, 저작권) 등은 상속인이 없이 사망하면 소멸하므로 국가에 귀속되지 않는다(특허법 제124조, 저작권법 제6조). 국가귀속 시기는 상속재산관리인이 잔여재산을 인계하는 때로 보자는 견해⁶⁶⁰⁾가 있지만, 상속이 개시된 때⁶⁶¹⁾에 국가에 귀속되는 것으로 보는 것이 민법 제1059조에 비추어 타당하다.

민법에 규정된 재산상속인이 존재하지 아니한 경우의 상속재산의 귀속에 대하여 판례는 민법 제5편 제2장에는 재산상속에 관한 규정이 있으며, 거기에 열거되어 있는 재산상속인이 존재하지 아니한 경우에는 민법 제1058조에 의하여 상속재산이 국가에 귀속한다고 보아야지 다른 최근친자에게 귀속된다고 할 수 없다고 판시하고 있다.⁶⁶²⁾

부동산 소유자가 행방불명된 경우, 그의 사망 및 상속인의 부존재에 대한 입증이나 앞서 설명한 국가귀속절차 없이 단순히 국유재산법 제83조에 따른 무주부동산의 공고절차만을 거쳐 그 부동산을 국유화 할 수 없다. 즉, 판례는 특정인 명의로 사정된 토지는 특별한 사정이 없는 한 사정명의자나 그 상속인의 소유로 추정되고, 토지의 소유자가 행방불명되어 생사 여부를 알 수 없다 하더라도 그가 사망하고 상속인도 없다는 점이 입증되거나 그 토지에 대하여 민법 제1053조 내지 제1058조에 의한 국가귀속 절차가 이루어지지 아니한 이상 그 토지가 바로 무주부동산이 되어 국가 소유로 귀속되는 것이 아니며, 무주부동산이 아닌 한 국유재산법 제8조에 의한 무주부동산의 처리절차를 밟아 국유재산으로 등록되

660) 김주수·김상용, 앞의 책, 671면.

661) 박윤직, 앞의 책(상속법), 215면; 이경희, 앞의 책, 370면.

662) 대법원 1990. 11. 13. 선고, 90다카26867 판결.

었다 하여 국가 소유로 되는 것도 아니다.⁶⁶³⁾

다만, 무주의 토지는 민법 제252조 제2항에 의하여 국유로 되는 것이고, 토지 소유자가 존재하였으나 그의 상속인의 존부가 분명하지 아니한 경우에 적용되는 민법 제1053조 내지 제1058조 소정의 절차를 밟아야만 국유로 되는 것은 아니므로, 무주의 토지라고 인정을 한 이상 그 토지를 국유라고 하기 위하여 상속인 부존재의 경우에 필요한 절차를 밟았는지를 별도로 심리할 필요는 없다.⁶⁶⁴⁾

663) 대법원 1999. 02. 23. 선고 98다59132 판결.

664) 대법원 1997. 11. 28. 선고 96다30199 판결.

저자 프로필

❖ 저자 김 현 선

건국대학교 일반대학원(법학과, 법학박사)

전) 건국대학교(서울), 전주대학교, 용인송담대학교, 영동대학교 강사

호서대학교 법학과 겸임교수

원광대학교 법학전문대학원(물권법) 외래교수

한국표준협회 전문위원(교수요원)

한국저작권위원회, 서울지방변호사협회(사무원양성교육), 우정공무원교육원 외래교수

법무부 상가건물임대차시행령개정 T/F위원

성남시 평생학습원(부동산공인중개사, 민법) 외래교수

성남시 여성복지회관(부동산공인중개사, 민법) 외래교수

한국생산성본부, 근로복지공단 외래교수

새롬 행정고시학원 민법 및 민사특별법 전임교수

현) 경기도청 법무담당관 법률자문관

한국열린사이버대학교 겸임교수

한국신용정보협회 전문위원(‘신용관리사’, ‘마이데이터관리사’ 자격시험 출제위원)

경찰수사연수원 외래교수

□ 저 서

- 민사소송에서 강제집행까지 사례 보면서 따라 하기(백영사, 2000)
- 가사(이혼)소송 사례 보면서 따라 하기(백영사, 2001)
- 상가건물·주택임대차보호법실무(백영사, 2003)
- 민법 및 민사특별법(백영사, 2004)
- 보전처분·공탁실무(중앙법률사무교육원, 2007)
- 친족·상속·가사실무(백영사, 2007)
- 가족관계 법률 등록에 관한 실무(백영사, 2008)
- 채권실무총론(상, 하), 중앙법률사무교육원(2009)
- 친족상속법(백영사 2010)
- 민사소송법(백영사 2011)
- 민사실무대전(Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ·Ⅳ)(백영사, 2010)
- 동산 채권담보실무(백영사 2012)
- 개인파산·회생실무 가이드(상, 하), (백영사, 2012)
- 형사실무 사례 보면서 익히기(백영사, 2013)
- 가사소송실무대전(상권, 하권) (로복스, 2015. 1)
- 외국인·재외동포에 관한 법률실무(상권, 하권, 2015. 1)
- 상가권리금 임대차보호법(백영사, 2015. 5)
- 주택임대차보호법 실무(백영사, 2016. 9)
- 상가건물임대차보호법 실무(백영사, 2016. 9)
- 상가건물임대차 계약에서 회수까지 사례 보면서 따라 하기(백영사, 2017. 7)
- 상속재산파산, 개인파산 실무(백영사, 2019. 7)
- 행정절차법 청문실무(백영사, 2020. 7)

□ 논 문

- 소액사건심판제도의 현황과 그 개선방안에 관한 연구(석사논문)
- 제3자에 의한 채권침해에 관한 연구(박사논문)
- 행정절차법상 청문주재자의 의견서 공개여부에 관한 고찰, 일감법학(제50호), 건국대학교법학연구소, 2021. 12.
- 부동산명의신탁의 유형에 따른 처분행위와 사해행위-대법원 2013. 9. 12. 선고 2011다89903판결을 중심으로-, 일감법학(제33호), 건국대학교법학연구소, 2016. 2.
- 상가건물임대차보호법상 권리금 법제화에 대한 소고-임대인의 방해행위에 따른 손해배상과 관련하여-, 안암법학(제48권), 안암법학회, 2015. 9.
- 임대차보증금반환채권의 가압류와 임차주택의 양도 -대법원 2013. 01. 17. 선고 2011다49523 전원합의체 판결을 중심으로-, 일감법학(제28호), 건국대학교법연구소, 2014. 6.
- 학교법인의 이사회 의결권 위임에 관한 효력-민법 제62조와 사립학교법 제19조 제3항과의 관계-, 법률실무연구(제2권 2호), 한국법률실무학회, 2014. 9.
- 대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인이 강제경매를 신청한 경우 배당요구를 하지 않아도 일반 채권자보다 우선하여 배당을 받을 수 있는지 여부 -대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결을 중심으로-, 홍익법학(제15권제1호), 홍익대학교법학연구소, 2014. 2.
- 분업적 의료행위에 대한 민사책임제한으로 신뢰원칙의 적용 여부-대법원 2011. 07. 14. 선고 2009다65416 판결을 중심으로-, 한국의료법학회지(제21권제2호), 한국의료법학회, 2013. 12.
- 제3자의 채권침해로 인한 구제수단, 법률실무연구(제1권2호), 한국법률실무학회, 2013. 10.
- 타인의 불법행위로 태아가 사망한 경우 가해자의 민법상 책임여부, 법학연구(52집), 한국법학회, 2013. 12.
- 동산채권 등의 담보에 관한 법률상 채권담보권의 제문제, 법률실무연구, 창간호, 한국법률실무학회, 2013. 4.
- 사실혼관계에서 혼인신고 시 상대방이 의사무능력 상태인 경우 그 혼인의 효력 -대법원 2012. 11. 29. 선고 2012므2451 판결의 의미-, 가족법연구, 제27권 1호(통권 제46호), 한국가족법연구, 2013. 2.
- 예금주가 사망한 경우 상속예금에 대한 법률관계(공동상속인 1인이 자기 법정상속지분만큼 단독청구 할 수 있는지 여부), 금융법연구(제9권 제2호), 한국금융법학회, 2012. 12.
- 제3자에 의한 채권침해의 입법화 방안, 성균관법학(제24권 제4호), 성균관대학교법학연구소, 2012. 12.
- 과실에 의한 제3자의 채권침해와 불법행위의 성립 여부, 법학연구(제15집 제3호), 인하대학교법학연구소, 2012. 11.
- 나대지에 저장권을 설정한 후 저장목적물의 담보가치를 확보하기 위한 지상권의 효력(담보지상권의 유효 여부와 토지저당권자의 보호 방안을 중심으로), 중앙법학(제14집 제3호), 중앙법학회, 2012. 9.
- 사실혼배우자 한쪽이 일방적으로 한 혼인신고의 효력(혼인신고 당시 상대방이 의사무능력 상태인 경우 추인이론 적용여부), 한양법학(제23권 제3집), 한양법학회, 2012. 8.
- 경매절차상 전세권자와 전세권저당권자의 보호방안, 법학논총(제32집 제1호), 전남대학교법학연구소, 2012. 4.
- 제3자에 의한 채권침해의 유형적 고찰, 외법논집(제35권 제4호), 한국외국어대학교 법학연구소, 2011. 11.
- 일본 민법상의 제3자에 의한 채권침해(학설의 발전과정과 새로운 유형화의 논의를 중심으로), 동아법학 제52호, 동아대학교 법학연구소, 2011. 8.
- 전자계약의 성립(한국온라인경영연구 제1집 제1호 2010. 12. 한국온라인경영학회)
- 법정지상권의 성립(법정지상권의 유형확대의 문제와 관련하여), 경영법무(2009. 여름호)

저자 프로필

전 페이지 참조

상속과 포기
한정승인과 청산
상속재산파산 실무

2023년 1월 10일 초판인쇄

2023년 1월 15일 초판발행

저 자 : 김현선

발행인 : 임중대

발행처 : 법률지식

서울특별시 노원구 동일로232길 16, 206호

전화 (02)992-1577, 전송 (02)997-5056

신고번호: 제25100-2016-000033호

ISBN 979-11-970634-6-6-93360

값 95,000원